

GABRIELA MARQUES

IVAN MARQUES

A NOVA LEI DE

ABUSO DE AUTORIDADE

Lei 13.869/2019 – Comentada artigo por artigo

Prefácio

GUILHERME MADEIRA DEZEM

Apresentação

JOÃO MARCOS BUCH

THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS™



A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Primeiras páginas

A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

LEI 13.869/2019 - COMENTADA ARTIGO POR ARTIGO

Autores

Ivan Luís Marques da Silva

Gabriela Alves Campos Marques

© desta edição [2020]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono
Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450
CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal) com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

Os autores gozam da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhe a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seu trabalho.

Central de Relacionamento Thomson Reuters Selo Revista dos Tribunais
(atendimento, em dias úteis, das 09h às 18h)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sacrt@thomsonreuters.com

e-mail para submissão dos originais: aval.livro@thomsonreuters.com

Conheça mais sobre Thomson Reuters: www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso *eComm*

www.livrariart.com.br

Fechamento desta edição [13.09.2019]



ISBN 978-85-5321-902-5

© desta edição [2020]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Expediente

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Gerente de Conteúdo

Milisa Cristine Romera

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Marcella Pâmela da Costa Silva

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Analista de Conteúdo Editorial: Quenia Becker

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiárias: Bárbara Baraldi Sabino e Stefanie Lopes Pereira

Produção Editorial

Coordenação

Andréia R. Schneider Nunes Carvalhaes

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Rafael Ribeiro e Thaís Pereira

Estagiárias: Beatriz Fialho, Tainá Luz Carvalho e Victória Menezes Pereira

Capa: Linotec

Adaptação da Capa: Linotec

Controle de Qualidade da Diagramação: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Jonatan Souza, Luciano Guimarães, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

Analista de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

© desta edição [2020]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Ficha Catalográfica

Ficha Catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Silva, Ivan Luís Marques da

A nova lei de abuso de autoridade [livro eletrônico] / Ivan Luís Marques da Silva e Gabriela

Alves Campos Marques. -- 1. ed. -- São Paulo :

Thomson Reuters Brasil, 2019.

6 Mb ; ePub

1. ed. e-book baseada na 1. ed. impressa.

Bibliografia.

ISBN 978-85-5321-902-5

1. Abuso de autoridade 2. Abuso de poder - Leis e legislação - Brasil 3. Lei 13.869, de 2019 - Comentários I. Marques, Gabriela Alves Campos.

II. Título.

19-30094 CDU-343.353(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Abuso de autoridade : Crimes : Direito penal 343.353(81)

Maria Paula C. Riyuzo - Bibliotecária - CRB-8/7639

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Dedicatória

Dedicatória

Dedico ao meu grande e único amor, Ivan Marques, que deu novo sentido à minha vida, que desde o primeiro encontro desperta o que há de melhor em mim e me faz crer que não há limite para os nossos sonhos.

Gabriela Marques

Trabalhar com o que amamos, realiza o profissional. Trabalhar com quem amamos, faz a vida ser especial. Te amo, minha pequena Gabriela Marques. Obrigado pela parceria de vida.

Ivan Marques

Ao nosso filho, Miguel, fruto do maior amor do mundo.

Os autores

“Quem, em geral, vai denunciar é o Ministério Público e quem vai julgar é o juiz, por isso não cabe dizer que está havendo uma perseguição a esses agentes públicos.”

Deputado Ricardo Barros (PP-PR) – Relator do Projeto da nova Lei

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Epígrafe

Epígrafe

“Quem, em geral, vai denunciar é o Ministério Público e quem vai julgar é o juiz, por isso não cabe dizer que está havendo uma perseguição a esses agentes públicos.”

Deputado Ricardo Barros (PP-PR) –

Relator do Projeto da nova Lei

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Prefácio

PREFÁCIO

Em 05 de abril de 1887, John Emerich Edward Dalberg-Acton, mais conhecido como Lord Acton, escreveu em uma carta ao Bispo Mandell Creighton aquela que seria uma das principais frases contra o abuso de poder: “O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus”.

Em parte, a história das Leis de Abuso de Autoridade no país é uma história de múltiplos interesses envolvidos, dos mais legítimos aos menos republicanos.

De um lado há aqueles que, genuinamente, entendem que este tipo de legislação é necessária para a proteção dos indivíduos contra o abuso dos agentes estatais. De outro, há aqueles que buscam intimidar a atividade dos agentes de Estado. Além disso, há interesses também pouco republicanos de forma a manterem intocadas algumas práticas pouco republicanas.

A nova Lei de Abuso de Autoridade entra em nosso ordenamento com todo este caldeirão de influências e visões, das mais às menos republicanas, da inocência ao cinismo deslavado e com tudo o que há no meio disso.

A tarefa interpretativa mostra-se das mais difíceis. Em ambiente especialmente polarizado como se mostra o Brasil deste ano de 2019, o intérprete deve ser sereno de forma a evitar revanchismos, de forma a evitar corporativismos e de forma a evitar excessos no resultado da atividade interpretativa, seja tornando a lei hiperbólica, seja tornando a lei estéril.

E justamente nesta perspectiva encontra-se o trabalho dos autores Gabriela Marques e Ivan Marques, autores da mais alta competência e, cada um à sua maneira, conheço-os há vários anos.

Ivan foi meu colega no mestrado na Universidade de São Paulo. Desde então se notabilizou como excepcional advogado e profundo pensador do sistema de justiça penal. Gabriela foi minha aluna na graduação e na pós-graduação, também desponta como profunda pensadora do sistema de justiça e talentosa advogada.

Ambos produziram nestas páginas reflexões profundas e conclusões ponderadas sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade. Tenho certeza que será muito útil para estudantes e profissionais do direito, dada a profundidade e cuidado com que os autores cuidaram do tema. Desejo excelentes leitura e debates a todos.

São Paulo, 09.09.2019.

GUILHERME MADEIRA DEZEM

Possui graduação em Faculdade de Direito pela Universidade de São Paulo (1997) e mestrado em Faculdade de Direito pela Universidade de São Paulo (2008), bem como doutorado pela Universidade de São Paulo (2013). Atualmente é professor do curso de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e juiz de direito.

Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Penal, atuando principalmente nos seguintes temas: devido processo legal, eficiência, garantismo, pós-

modernidade, virtual.

© desta edição [2020]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Apresentação

APRESENTAÇÃO

Tive a oportunidade de conhecer Gabriela Marques e Ivan Marques pessoalmente em um programa de debates na TV, onde dividi com Ivan temas sobre violência, sistema prisional e direitos humanos. A fama que os precedia confirmou-se. São pensadores do direito cujo elevado conceito nutre não só a academia, mas também o mundo real, onde parcela considerável de cidadãos estão diariamente a enfrentar um injusto e opressor sistema de justiça criminal. Por isso, quando convidado para contribuir com esta Apresentação a respeito da obra *A nova Lei de Abuso de Autoridade: Lei 13.869/2019 – comentada artigo por artigo*, fiquei honrado e feliz. Não é sempre que se pode fazer parte de tão importantes estudos, ainda que, de minha parte, de maneira singela.

A República Federativa do Brasil é fundada na “Separação dos Poderes”. Este modelo é resultado de um processo histórico, que dentre outros nomes partiu de Aristóteles, passou por John Locke e continuou em Montesquieu. A preocupação sempre foi organizar um poder político com limites, sem tiranias, não absoluto. Por isso, em nosso país, como cláusula pétrea, o art. 2º da Constituição Federal estabelece que “são Poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Quando se dispôs essa independência e harmonia, consolidou-se a teoria da Separação dos Poderes e o sistema de “freios e contrapesos”, garantindo-se assim o equilíbrio.

Com a volta da democracia na década de 1980 e o restabelecimento das liberdades públicas, dentre elas a liberdade de imprensa, houve um descortinamento de atos de improbidade, corrupção, desvios. Essas coisas, nos tempos da ditadura militar, ficavam escondidas em quartos escuros. Com a democratização, esses quartos foram iluminados e vimos todos seus cantos. Assim o Poder Judiciário passou a ser demandado e precisou trazer respostas a denúncias, numa espécie de depuração da coisa pública. Correspondendo aos anseios, logo ele foi identificado como “salvador da pátria” e finalmente acabou por ter nome e endereço certos: a Lava Jato na República de Curitiba.

Em caráter geral, o que se viu é que, sob o fundamento de combate à corrupção, houve mitigação do devido processo legal, das garantias fundamentais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Era preciso obter o omelete e para isso os ovos deviam ser quebrados, a qualquer custo. Árbitro e jogador começavam a ser identificados numa só pessoa. Isso fez com que a harmonia e independência entre os três Poderes fosse posta em xeque, trazendo fragilização às instituições, desestabilização do país e um namoro com algo próximo do estado de exceção.

A nova lei de abuso de autoridade (Lei 13.869/2019), além das idas e vindas de vetos, foi pautada em regime de urgência e, ao que parece, assim o foi como contraposição a todo esse estado de coisas. Há quem diga que foi um ataque direto à Lava Jato. Aqui, portanto, a importância deste livro, cujos substratos nos auxiliam a compreender a atualidade que por vezes se mostra distópica.

O fato é que os abusos de autoridade sempre foram comuns perante as populações periféricas, econômica e socialmente vulneráveis, com pouca ou nenhuma atenção do Estado sobre essas violações. Agora, com o lastro do Leviatã estendido a autoridades e grandes empresários, nada

obstante tenham ficado de fora bancos e banqueiros e tenha sido feita uma seletividade clara sobre quais políticos seriam objeto de ações, respostas começaram a nascer, uma delas a lei em questão.

Precisamos manter o eixo constitucional. O Estado Democrático de Direito não sobrevive com o enxovalhamento do Poder Legislativo, aviltamento do Poder Executivo e desconstituição do Poder Judiciário. Os três Poderes devem ser fortalecidos, valorizados e legitimados, os dois primeiros especialmente pelo sufrágio universal e o último pela submissão aos valores e princípios constitucionais. Nenhum Poder está acima de outro. Essa lição é antiga.

Assim, nada melhor do que ver juristas como Gabriela e Ivan debruçados sobre esse espinhoso terreno e fazendo um trabalho brilhante. A análise de artigo por artigo da nova lei é aprofundada, sem generalizações e superficialidades, cada ponto é submetido a consistentes reflexões, além do que, como se observa, os autores não pouparam críticas às zonas nebulosas e despidas de taxatividade que pululam por todos os lados do diploma, o que pode inclusive inviabilizar sua eficácia.

Se o novo ordenamento conseguirá refrear a onda de violações constitucionais ou se cairá no vazio ou se até mesmo alimentará polarizações e sectarismos não temos como saber nesta etapa, mas Gabriela e Ivan, com esta grande obra, *A nova Lei de Abuso de Autoridade: Lei 13.869/2019 – comentada artigo por artigo*, trazem-nos pistas fundamentais e concretas de onde, como cidadãos ou como bárbaros, poderemos chegar.

JOÃO MARCOS BUCH

Mestre em Ciência Jurídica, área de concentração Hermenêutica e Principiologia Constitucional. Graduado em direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (1992). Atualmente é juiz de direito – Poder Judiciário de Santa Catarina, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, criminologia, princípios constitucionais, eficiência e pena.

Membro do Conselho Executivo da Associação Juízes Para Democracia. Formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Especializado em Criminologia e Política Criminal e Especializado em Direito Contemporâneo.

Autor da obra jurídica *O Novo Regime da Prisão Cautelar a Partir da Lei n. 12.403/2011* e da obra jurídica *Execução Penal e Dignidade da Pessoa Humana*. Autor do romance *Encontre-me no Café em Paris*; do livro *Crônicas Relatos Vivências*; do livro *Diário de Bordo de um Juiz das Causas Humanas*; do livro *Retroceder Jamais*; do livro *Juiz de Si Juiz do Mundo: a esperança persiste* e do livro *Juiz Achado na Rua*; do livro *Crônicas de um juiz que solta*; do livro *Execução Penal Aplicada: anotações para a redução de danos*.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Nota dos Autores

NOTA DOS AUTORES

A autoridade envenena todo aquele que a toma para si (Golda Meir)

Foi sancionada, em 05 de setembro de 2019, a nova lei de abuso de autoridade – Lei 13.869/2019, que revogou expressamente a antiga Lei 4.898/1965, além de alterações relevantes na Lei de Prisão Temporária, na Lei das Interceptações Telefônicas, no Código Penal e no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Nem se poderia questionar se é necessária ou não a tutela penal das condutas de agentes públicos que se valem de seus cargos, funções e mandatos para constranger ilegalmente os cidadãos, por motivos pessoais, egoísticos, por mero capricho, para prejudicar terceiros ou, ainda, para benefício próprio ou alheio.

Tendo em vista os inúmeros casos que são veiculados na mídia, além de situações não apresentadas ao público, pela falta de informação ou comunicação dos fatos em um País com dimensões continentais, o filtro do Direito Penal ainda nos parece certo, quando corretamente desenhado e aplicado.

A tutela penal mostra-se necessária para devolver à coletividade a segurança de somente serem abordados pelos agentes da área criminal após a prática de algum injusto penal e por força da prática desse ato, evitando-se uma caça às bruxas pobres, com prisões sem justa causa para a ditatorial “averiguação”.

Além da relevância da existência de condutas típicas de abuso de autoridade, questões referentes à aprovação da presente lei merecem alguns apontamentos.

O primeiro ponto a ser abordado é: qual o motivo de se pautar, em regime de urgência e com votação simbólica, não nominal, um tema tão importante e sensível, após ter ficado dois anos parado no Congresso Nacional?

Na tarde de 14 de agosto, foi aprovado o requerimento de urgência e, nesta mesma data, o Plenário da Câmara dos Deputados votou a matéria através de procedimento simbólico, sequer possibilitando aos deputados federais a votação nominal do tema ou a apresentação de emendas ou críticas. O texto foi elaborado em mandato anterior do Congresso Nacional e não pela maioria dos parlamentares da nova legislatura.

Com o aval dos líderes partidários, o projeto foi aprovado e encaminhado à sanção presidencial, ato que depende da avaliação do Ministro da Justiça para verificar se existem pontos a serem vetados e suas respectivas justificativas.

A nova lei criminalizou 30 condutas de agentes públicos, tendo como foco principal a atuação de policiais, representantes do Ministério Público e magistrados, inclusive no plano colegiado; além do tipo penal aberto de violação às prerrogativas dos advogados.

A grande crítica dessa Lei, feita por policiais, representantes do Ministério Público e da Magistratura, reside em suposto ataque parlamentar a essas Instituições, criminalizando boa parte de sua atuação cotidiana, como forma de retaliação política pela prisão de grande parte do

Parlamento na Operação Lava Jato.

Em julho de 2019, a Operação Lava Jato já possuía tais números alarmantes: a) 2.476 procedimentos instaurados; b) 1.237 mandados de busca e apreensões; c) 227 mandados de condução coercitiva; d) 161 mandados de prisão preventivas; e) 155 mandados de prisões temporárias; f) 6 prisões em flagrante; g) 754 pedidos de cooperação internacional; h) 184 acordos de colaboração premiada firmados com pessoas físicas; i) 11 acordos de leniência; j) 1 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; k) 244 condenações contra 159 pessoas; l) 2.249 anos de pena privativa de prisão; m) 3,2 bilhões de reais em bens de réus bloqueados. (Fonte: Infográfico do MPF – Dados atualizados até 05.07.2019 – Acesso em 01.09.2019).

A nova Lei de Abuso de Autoridade não foi muito bem construída e traz zonas nebulosas de ausência de taxatividade. Essa carência de taxatividade poderá, em tese, na prática, dificultar o trabalho da Polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Entretanto, a sua construção terá pouca eficácia, seja pela necessidade de comprovar o dolo específico exposto logo no artigo 1º, seja pelo patamar dos preceitos secundários, como demonstraremos no caminhar de nosso trabalho editorial.

Afirma-se, pelos corredores do Congresso Nacional, que esta lei teve como objetivo esvaziar os poderes de investigação da Operação Lava Jato, blindando os parlamentares que ainda não foram objeto de investigações.

De outro lado, o objetivo da lei – tutela da coletividade contra abusos de agentes públicos – será atingido se os novos tipos penais inibirem os abusos praticados ou punirem, com efetividade, os agentes que agirem com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, valendo-se de seu cargo, emprego, função ou mandato eletivo.

Com a exposição constante de casos envolvendo corrupção de agentes públicos, criou-se um interesse social pelo Judiciário, Executivo, Legislativo e direito penal e processual penal. A atenção popular para as novidades legislativas é muito importante, pois informa a sociedade a respeito dos novos crimes, viabilizando a sua defesa em eventual situação de abuso, cumprindo o papel de tutela jurídica dos tipos penais na prática.

São Paulo, 9 de setembro de 2019.

OS AUTORES.

GABRIELA MARQUES

Advogada criminalista.

Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

@gabcmarques

IVAN MARQUES

Advogado criminalista.

Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Professor.

@prof.ivanmarques

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

O Caminho da Lei

O Caminho da Lei. O CAMINHO DA LEI

Toda lei que cria crimes e comina penas precisa ser Lei Federal, aprovada no Congresso Nacional, nas duas casas, por maioria simples.

Precisa, também, possuir lastro constitucional para legitimar a opção da criminalização de condutas para a proteção de bens jurídicos.

Inclui-se, na preocupação da elaboração legislativa, a racionalidade das leis penais para fugir do mero simbolismo e dos gestores atípicos da moral (RIPOLLÉS, 2015, p. 7).

A Lei de Abuso de Autoridade seguiu esse trâmite, apesar de ser aprovada por acordo de lideranças partidárias.

Após a sua aprovação nas duas Casas do Parlamento, é encaminhada para a sanção do Presidente da República, que, para analisar a viabilidade constitucional da norma, regularmente pede apoio do Ministério da Justiça.

Após a sanção e os vetos presidenciais, a lei é publicada no Diário Oficial da União e passará a ter vigência após a sua *vacatio legis*.

O período de *vacatio* regular, previsto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro – LINDB, é de 45 dias. Nada impede que o Parlamento escolha outro período de *vacatio*, inclusive nenhum, fazendo a lei entrar em vigor na data de sua publicação.

A nova Lei de Abuso de Autoridade possui *vacatio legis* de 120 dias após publicada, prazo que já está correndo.

Publicada a lei, seu texto oficial sancionado e vetado volta para o Congresso Nacional, para que os vetos presidenciais sejam avaliados pelo Parlamento.

O veto é a discordância do Presidente da República com determinado projeto de lei aprovado pelas Casas Legislativas do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal). A Constituição determina que ele seja apreciado pelos parlamentares em sessão conjunta, sendo necessária a maioria absoluta dos votos de Deputados e Senadores para sua rejeição. O veto não apreciado, após 30 dias do seu recebimento, é incluído automaticamente na pauta do Congresso Nacional, sobrestando as demais deliberações até que seja ultimada sua votação.

Após o aceite ou a rejeição dos vetos, o texto da lei torna-se imutável até que seja revogado futuramente ou declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário.

A representação visual do caminho da lei pode ser vista no Anexo VI deste livro.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Tabela Comparativa entre as Leis 4.898/1965 e 13.869/2019

Tabela Comparativa entre as Leis 4.898/1965 e 13.869/2019

Nova Lei 13.869/19	Lei Revogada 4.898/65
Art. 9º, <i>caput</i>	Art. 3º, <i>a</i> e 4º, <i>a</i>
Art. 9º, I	Art. 4º, <i>d</i>
Art. 9º, II	Art. 4º, <i>e</i>
Art. 9º, III	S/Correspondência
Art. 10º	S/Correspondência
Art. 11	S/Correspondência
Art. 12	Art. 4º, <i>c</i>
Art. 12, IV	Art. 4º, <i>i</i>
Art. 13, I	Art. 4º, <i>b</i>
Art. 13, II	Art. 4º, <i>b</i>
Art. 13, III	S/Correspondência
Art. 14	S/Correspondência
Art. 15	Art. 3º, <i>j</i>
Art. 16	S/Correspondência
Art. 17	S/Correspondência
Art. 18	S/Correspondência
Art. 19	S/Correspondência
Art. 20	Art. 3º, <i>j</i>
Art. 21	S/Correspondência

Art. 22	Art. 3º, <i>b</i>
Art. 23	S/Correspondência
Art. 24	S/Correspondência
Art. 25	S/Correspondência
Art. 26	S/Correspondência
Art. 27	S/Correspondência
Art. 28	S/Correspondência
Art. 29	S/Correspondência
Art. 30	S/Correspondência
Art. 31	S/Correspondência
Art. 32	Art. 3º, <i>j</i>
Art. 33	S/Correspondência
Art. 34	S/Correspondência
Art. 35	Art. 3º, <i>h</i>
Art. 36	S/Correspondência
Art. 37	S/Correspondência
Art. 38	S/Correspondência

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS – ART. 1º

Art. 1º

Art. 1º

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º. As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

COMENTÁRIOS

Os novos tipos penais

“A nova lei cria tipos penais para punir na esfera criminal os agentes públicos, com o conceito específico redefinido por essa lei em seu artigo 2º (*vide* comentários específicos).”

Os 5 elementos subjetivos do injusto – Dolos específicos alternativos (elementos subjetivos especiais)

Importante destacar, apesar de todo o alarde em torno da lei, que o ato criminal de abuso de autoridade demanda, para a sua caracterização, finalidades muito específicas que, sem elas, não caracterizam nenhum dos novos delitos.

São finalidades específicas previstas na lei, alternativas, as seguintes:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Caso, na prática, não sejam comprovados esses elementos subjetivos, que consistem no dolo específico, os fatos serão atípicos por ausência de conduta penalmente relevante, não sendo configurados os crimes dessa lei.

A principiologia

Apesar de a lei punir de forma ampla os agentes públicos que atuem com essas finalidades

além do dolo direto das condutas selecionadas pelo legislador, a análise subjetiva da presença desses dolos está vinculada aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da livre investigação e valoração das provas, da livre convicção, da necessidade da motivação das decisões judiciais e de comprovação por parte da acusação.

A persecução penal dependerá de análise jurisdicional para receber a denúncia ministerial, pois todos os delitos são de ação penal pública incondicionada, e para sentenciar nos termos da imputação inicial. Além do posicionamento do magistrado de primeira instância, ainda há a possibilidade do duplo grau de jurisdição.

O foro de prerrogativa de função

Muitos dos agentes públicos elencados no art. 2º possuem foro de prerrogativa de função mantido nesta *novatio legis*, para a prática de crimes comuns.

A hermenêutica como figura típica?

O § 2º traz norma penal explicativa afastando da tipificação de crime de abuso de autoridade mera atividade jurisdicional interpretativa. Interpretar não pode ser caracterizado como *crime de hermenêutica*. Dessa forma, não poderá a pessoa que se sentir prejudicada com a decisão funcional alegar abuso de autoridade, se for apenas o posicionamento do servidor diante da norma e de sua interpretação.

Rui Barbosa alertava para o absurdo de tipificar a interpretação jurisdicional, porém, a constante preocupação com a uniformização da jurisprudência e os enunciados vinculantes do STF demonstram a carência jurisdicional por coerência, expondo os jurisdicionados ao alvedrio de quem age de maneira coercitiva.

A avaliação dos fatos

Os agentes públicos somente podem agir no estrito cumprimento do dever legal, ao contrário dos particulares que têm a faculdade do exercício regular de direito.

Cumprindo determinação legal, não há que se falar em abuso de autoridade pela leitura circunstancial do agente, que, por exemplo, ao invadir um domicílio em situação de aparente flagrância, não pode ser rotulado como um criminoso por acreditar, por razões fáticas, estar sendo praticado no interior da residência um crime.

Se, após o ingresso, fica constatada uma má avaliação do agente, a própria lei de abuso de autoridade afasta a tipicidade formal diante dessa situação *in casu*.

A avaliação das provas

No Brasil, vige o sistema da livre apreciação da prova pelo magistrado para a maioria dos ritos, e a livre convicção para os julgamentos feitos pelos jurados.

Em qualquer uma dessas situações, a leitura das provas, o valor atribuído a qualquer uma delas, não pode levar à conclusão de abuso, por ser o simples exercício funcional.

Nessa aparente situação, o que irá caracterizar o crime é o dolo direto do tipo específico acrescido do dolo específico aqui especificado.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS – ART. 2º

Art. 2º

Art. 2º

[...]

CAPÍTULO II

DOS SUJEITOS DO CRIME

Art. 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II - membros do Poder Legislativo;

III - membros do Poder Executivo;

IV - membros do Poder Judiciário;

V - membros do Ministério Público;

VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.

COMENTÁRIOS

Para que exista punição por abuso de autoridade, no plano penal, urge que seja especificado o conceito de agente público como sujeito ativo dos crimes dessa lei.

Temos, hoje, em vigor, alguns conceitos a respeito de quem seriam os agentes públicos, passíveis de punição criminal.

O art. 84 da Lei de Licitações apresenta um conceito próprio para os agentes delitivos que praticam os crimes dessa Lei n. 8666/93 (Cezar Roberto Bitencourt, p. 104):

Lei de Licitações e contratos administrativos

Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.

§ 1º Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.

§ 2º A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

Além do conceito específico da Lei de Licitações, temos ainda o clássico conceito do nosso Código Penal:

Art. 327 – Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º – Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º – A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

A Lei 8666/93 traz sua própria definição de servidor público. Passa a adotar a terminologia servidor público, mas é praticamente a mesma definição disposta no artigo 327 do Código Penal. A diferença entre os dois artigos está relacionada à figura equiparada dos funcionários e servidores públicos.

Para o Código Penal, equipara-se a funcionário público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. Já a Lei 8666/93 traz que a figura equiparada seria entidades sob controle, direito ou indireto, do Poder Público.

O Código Penal adotou uma postura extensiva em relação ao conceito de funcionário público.

Nota-se que a definição de servidor público dada pela Lei 8666/93 é a mesma da inculpada no art. 327 do Código Penal, ou seja, abrange todas as hipóteses em que o autor dos fatos apresenta algum vínculo com o Estado, ainda que de forma temporária e sem remuneração.

Por outro lado, o conceito de funcionário público por equiparação previsto no art. 84, § 1º, da Lei 8666/93 é mais amplo quando cotejado com o art. 327, § 1º, do CP, porquanto a lei especial fez questão de ressaltar expressamente a fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista e as demais entidades controladas pelo Poder Público. De tal sorte, num eventual conflito aparente de normas, aplica-se a máxima *lex specialis derogat legi generali*, ou seja, a lei especial (Lei 8666/93) afasta a aplicação da regra geral (Código Penal).

Os principais órgãos do Poder Legislativo brasileiro são:

Órgãos federais. Congresso Nacional – Senado Federal e Câmara dos Deputados.

Órgãos estaduais. Assembleias legislativas: representadas pelos deputados estaduais.

Órgãos municipais. Câmaras municipais: representadas pelos vereadores.

As autoridades civis do Poder Executivo são:

Autoridades federais. Presidente e Vice; Ministros.

Autoridades estaduais. Governadores e Vices; Secretários Estaduais.

Autoridades municipais. Prefeitos e Vices; Secretariado.

O Poder Judiciário ou Poder Judicial é constituído de ministros, desembargadores e juízes.

As funções essenciais da Justiça, em sentido amplo, passaram a se dividir em três:

Procuratura da sociedade: Ministério Público em sentido estrito (artigos 127 a 130-A da Constituição);

Procuratura do Estado: Advocacia Pública (artigos 131 e 132 da Constituição);

Procuratura dos hipossuficientes: Defensoria Pública (artigos 134 e 135 da Constituição).

Quem são os membros dos Tribunais de Contas?

Conhecido também como Corte de Contas, o TCU é órgão colegiado. Compõe-se de nove ministros. Seis deles são indicados pelo Congresso Nacional, um, pelo presidente da República, e dois, escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público que funciona junto ao Tribunal.

Agentes públicos para a nova Lei de Abuso de Autoridade

O artigo 2º da lei de abuso de autoridade traz o conceito de agente público ou servidor público, aquele disposto no artigo 327 do CP e do 84 da Lei 8666/93. Mas, como se observa, ele traz um rol extensivo, pois no *caput* dispõe que não se limita ao rol ali elencado nos parágrafos.

No parágrafo único, ele traz o que está descrito no tipo penal previsto no *caput* do 327 do CP, bem como em seus incisos.

O artigo 2º tem o intuito de cercar a definição de agente/servidor público, para que realmente possa se reprimir excessos cometidos por autoridades, como policiais, juízes, promotores de justiça, cartorários, entre outros.

O que mudou

A revogada Lei 4.898/65, em seu artigo 5º, dispunha que:

Art. 5º Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.

Pode-se observar que a nova lei procura punir mais autoridades, pois ela amplia o conceito de autoridade para agente público, traz um rol que não é taxativo, e sim exemplificativo.

A mudança é clara e tem a intenção de inibir excessos cometidos por autoridades, punindo todo aquele que está investido em cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo.

Novo conceito de agente público

Portanto, será sujeito ativo do crime de abuso de autoridade:

- qualquer agente público
- servidor público ou não
- da administração direta, indireta ou fundacional
- de qualquer dos 3 Poderes da República
- da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e de Território.

E, para os efeitos dessa lei, reputa-se agente público:

- todo aquele que exerce,
- ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
- por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
- mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da Administração Pública.

Rol exemplificativo

O artigo 2.º nos apresenta um rol exemplificativo de agentes públicos aptos a praticarem atos de abuso de autoridade:

- I – servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;
- II – membros do Poder Legislativo;
- III – membros do Poder Executivo;
- IV – membros do Poder Judiciário;
- V – membros do Ministério Público;
- VI – membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Insta ressaltar que a própria lei afirma – compreendendo, mas não se limitando a ela – ou seja, outras pessoas poderão ser responsabilizadas por crimes de abuso de autoridade, mesmo ficando de fora desse rol exemplificativo, como, por exemplo, os advogados conveniados na Defensoria Pública, enquanto atuam em nome dos hipossuficientes, por força de convênio.

Advogados dativos são agentes públicos

No RHC 33.133-SC, decidiu-se que advogados dativos, ao exercerem essa função pública, agem como agentes públicos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL). DEFENSOR DATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 327 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. De acordo com o artigo 134 da Constituição Federal, a defesa em juízo das pessoas necessitadas é incumbência da Defensoria Pública, considerada instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Trata-se, portanto, de função eminentemente pública, pois destinada a garantir a ampla defesa constitucionalmente prevista em favor de todos os acusados em processo penal, independentemente da capacidade financeira de contratação de um profissional habilitado. 2. Embora não sejam servidores públicos propriamente ditos, pois não são membros da Defensoria Pública, os advogados dativos, nomeados para exercer a defesa de acusado necessitado nos locais onde o referido órgão não se encontra instituído, são considerados funcionários públicos para fins penais, nos termos do artigo 327 do Código Penal Doutrina. 3. Tendo o recorrente, na qualidade de advogado dativo, exigido para si vantagem indevida da vítima, impossível considerar a sua conduta atípica como pretendido no reclamo. 4. A simples ausência de juntada aos autos da nota promissória que comprovaria a exigência indevida feita pelo recorrente não conduz à falta de justa causa para a persecução criminal, uma vez que o referido documento pode ser anexado ao processo até a conclusão da instrução criminal, sem prejuízo de que a materialidade delitiva seja comprovada por outros meios de prova admitidos. 5. Recurso improvido (RHC 33.133/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013).

Coautoria e participação

Seguindo a regra do Código Penal, em especial o artigo 30, os crimes de abuso de autoridade, mesmo sendo próprios, admitem coautoria e participação.

Art. 30 – Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Ser agente público é elementar de todos os crimes desta lei e, portanto, comunicam-se aos demais agentes delitivos quando praticam o crime em concurso de pessoas, desde que a condição de agente público seja conhecida pelo coautor ou partícipe.

Assim, será possível um particular responder pelos crimes dessa lei como se autoridade fosse.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO III – DA AÇÃO PENAL – ART. 3º

Art. 3º

Art. 3º

[...]

CAPÍTULO III DA AÇÃO PENAL

Art. 3º. Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.

§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Ação penal pública incondicionada

Sempre criticamos os dispositivos legais que assim diziam:

“os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada.”

Mas, qual é o problema em fazer essa afirmação no plano normativo?

O problema reside no fato de a ação penal pública incondicionada ser a regra geral dos crimes e, sendo a regra geral, dispensa a informação expressa nos tipos penais. Assim, basta a lei ficar em silêncio e, automaticamente, o crime será de ação penal pública incondicionada.

Assim nos ensina o Código Penal:

Art. 100. – A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

As razões de veto foram feitas nesse sentido, pela total desnecessidade da regra.

No silêncio da nova lei, que é uma legislação especial, utiliza-se o Código de Processo Penal, conforme já previsto no artigo 3º do CPP:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. O artigo 3º da nova lei é uma mescla dos artigos do Código de

Ação penal privada subsidiária da pública

O § 1º desse artigo 3º apresentou uma preocupação explícita com um dos prováveis riscos da nova Lei de Abuso de Autoridade – a complacência interpretativa dos membros do *Parquet*.

Ora, se todos os tipos penais são de ação penal pública incondicionada, e se todos demandam provas pré-constituídas de materialidade, autoria e a comprovação de um dos 5 dolos específicos do art. 1º, existe grande chance de o titular da ação penal interpretar pela ausência de tipicidade, seja pela inexistência das finalidades específicas das condutas, seja pela falta de justa causa.

De qualquer forma, diante dessas situações, o representante do *Parquet* não irá permanecer inerte. Ele irá requerer o arquivamento das peças de investigação, seja inquérito policial, procedimento de investigação criminal, seja relatório de CPI.

Apenas na omissão do promotor ou procurador, total inércia, é que surgirá a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública, novamente, como previsto desde 1988.

Enfrentemos, agora, todos os dispositivos legais necessários para a compreensão da norma:

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; (grifos nossos)

Código Penal

Art. 100. (...) § 3º – A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. (grifos nossos)

Código de Processo Penal

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. (grifos nossos)

Fica óbvio perceber que a mesma regra já está positivada em 3 (três) diplomas normativos diferentes.

Assim, não há necessidade de fazê-lo novamente. Isso, por si só, já justificaria o veto presidencial.

Mas a razão de veto foi além

“devendo ser observado o princípio segundo o qual o mesmo assunto não poderá ser disciplinado em mais de uma lei, nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei Complementar 95, de 1998”.

A Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. É uma lei que tem por objeto a criação e organização das demais leis do País.

Entre as suas regras, está o dispositivo mencionado na razão de veto:

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

(...)

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.

Agiu muito bem a equipe ministerial e presidencial em vetar esse artigo pois, além de desnecessário, descumpre a legislação repetindo texto que já existe. Não houve inovação, sequer, no prazo de 6 meses da ação penal privada subsidiária, da data de início dessa contagem ou as atribuições do MP após o oferecimento da queixa-crime subsidiária, também já regulamentados pela lei:

Código de Processo Penal

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

(...)

§ 2º O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Razões do veto

“A ação penal será sempre pública incondicionada, salvo quando a lei expressamente declarar o contrário, nos termos do art. 100 do Código Penal, logo, é desnecessária a previsão do caput do dispositivo proposto. Ademais, a matéria, quanto à admissão de ação penal privada, já é suficientemente tratada na codificação penal vigente, devendo ser observado o princípio segundo o qual o mesmo assunto não poderá ser disciplinado em mais de uma lei, nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei Complementar 95, de 1998. Ressalta-se, ainda, que nos crimes que se procedam mediante ação pública incondicionada não há risco de extinção da punibilidade pela decadência prevista no art. 103 cumulada com o inciso IV do art. 107 do CP, conforme precedentes do STF (v.g. STF. RHC 108.382/SC. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. T1, j. 21/06/2011).”

Críticas ao veto presidencial

A intenção do legislador

Entendemos que a repetição dos textos legais nessa lei não foi mero acaso, e sim algo proposital, como um mecanismo de segurança para que se possa realmente apurar os casos de abuso de autoridade existentes, mandando um recado para o único titular da ação penal de que não serão aceitos engavetamentos de investigações sem um posicionamento oficial do Ministério Público: denunciar, requerer arquivamento ou requisitar novas diligências. O que causa medo no legislador é a simples omissão, viabilizando o decurso do tempo sem nenhuma atitude.

Com essa possibilidade da queixa subsidiária, evita-se que a lei de abuso de autoridade seja inócua e mesmo que com ou sem dolo específico da inércia por parte da autoridade o ofendido consiga acesso ao Poder Judiciário.

Mas, diante das regras já em vigor, desnecessário o recado legislativo para os agentes públicos que optarem, deliberadamente, pela prática de abuso de autoridade.

O artigo 28 do Código de Processo Penal

Se o MP requerer arquivamento e o juiz discordar caberá o artigo 28 do Código de Processo Penal, remeterá os autos de investigação preliminar ao chefe do Ministério Público (PGJ ou PGR, a depender da competência criminal).

O Procurador-Geral poderá oferecer a denúncia diretamente, designar outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistir no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Em resumo, diante da fragilidade normativa dos tipos penais de abuso de autoridade e da dificuldade de comprovação das finalidades específicas da nova Lei de Abuso de Autoridade, quem dará a última palavra a respeito será o Ministério Público, único titular da ação penal dos crimes de abuso de autoridade.

O veto do § 2º

O § 2º também foi vetado por duas razões:

- a) já possui previsão legal idêntica, já explicado por nós anteriormente;
- b) inexistência de risco de extinção de punibilidade pela decadência.

A ação penal privada propriamente dita (exclusiva) ou personalíssima, se não oferecida a queixa-crime respectiva em 6 meses contados da ciência da autoria – prazo penal –, acarreta a extinção da punibilidade do fato praticado pelo agente.

Ou seja, o Estado perderá o direito de investigar, processar e punir um agente delitivo pela omissão de iniciativa do ofendido ou de seus representantes legais (art. 31 do CPP).

Entretanto, não existe essa preocupação em relação à ação penal privada subsidiária da pública, expressa no § 2º em comento.

A natureza da ação penal é pública e, mesmo diante da omissão ministerial e do surgimento paralelo da dupla titularidade – MP e ofendido –, a ação continua sendo pública.

Dessa forma, sendo a ação pública e continuando pública, a omissão do ofendido em oferecer queixa-crime subsidiária em 6 meses não terá como consequência a decadência. Não existe decadência em ação pública, conforme posição consolidada jurisprudencialmente:

V.g. STF. RHC 108.382/SC. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. T1, j. 21/06/2011.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO IV – DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

- ARTS. 4º E 5º

Art. 4º

Art. 4º

[...]

CAPÍTULO IV

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Seção I

Dos Efeitos da Condenação

Art. 4º. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO IV – DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

- ARTS. 4º E 5º

Art. 5º

Art. 5º

[...]

CAPÍTULO IV

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

[...]

Seção II

Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:

I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

III - (VETADO).

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

=> Inciso III vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS

Os efeitos da condenação

Na Lei de 1965, tínhamos disposições gerais e muito específicas para determinadas carreiras, com prazos e situações muito característicos.

A nova lei unificou o tratamento dos efeitos da condenação para os crimes de abuso de autoridade para todos os agentes públicos que figuram no conceito do art. 2º da Lei.

Os efeitos da condenação no Código Penal contra agentes públicos

Temos, no Código Penal, no artigo 92, os efeitos da condenação criminal para os agentes públicos pela prática de delitos que atingiam a Administração Pública.

Reza o texto do Código Penal:

Art. 92 – São também efeitos da condenação:

I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

A Lei 4.898/65 tratava os efeitos da condenação pela prática de abuso de autoridade em seu artigo 6º, nos seguintes termos:

Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal.

(...)

§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em:

a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;

b) detenção por dez dias a seis meses;

c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até três anos.

Os efeitos da condenação na nova Lei de Abuso de Autoridade

A nova Lei de Abuso de Autoridade trouxe regramento inédito e específico sobre o tema – efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade.

Assim nos foi apresentado o tema:

Art. 4º São efeitos da condenação:

I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II – a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III – a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Reincidência como condição para efeitos da condenação

Agentes primários, mesmo os tecnicamente primários (art. 64 do CP), que é justamente o oposto da situação de reincidência, não sofrerão as mazelas da perda do cargo, mandato eletivo ou função, sendo condenados criminalmente por crimes funcionais ou relacionados com o uso do cargo, emprego ou função pública.

O instituto penal da reincidência busca punir com mais rigor o agente que, mesmo já tendo sido condenado de maneira definitiva por crime anterior, opta por praticar novo delito após o trânsito em julgado da condenação pretérita, demonstrando alta reprovabilidade.

Em relação à reincidência, o Código Penal assim a trata:

Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Trata-se de circunstância agravante genérica de caráter subjetivo ou pessoal. Sendo circunstância subjetiva, não se comunica ao partícipe ou coautor.

Vale ressaltar que a natureza dos delitos é indiferente para fins de caracterização da reincidência: a reincidência pode dar-se:

- (a) entre dois crimes dolosos;
- (b) entre dois crimes culposos;
- (c) entre crime doloso e culposo;
- (d) entre crime culposo e doloso;
- (e) entre crime consumado e tentado;
- (f) entre crime tentado e consumado;
- (g) entre crimes tentados;
- (h) entre crimes consumados.

O parágrafo único deste artigo condiciona os efeitos nefastos da condenação para o agente público à reincidência específica em delitos de abuso de autoridade previstos nesta lei.

Efeitos não automáticos

Havia discussão a respeito da necessidade de fundamentar a escolha dos efeitos da condenação para os agentes públicos desde que amparados com a situação fático-normativa do delito imputado ao agente com a respectiva condenação.

Agora, para os crimes de abuso de autoridade expressos nesta lei, criou-se condicionamento objetivo de imposição dos efeitos da condenação – a reincidência específica.

A lei também esclarece que os efeitos da condenação não são automáticos e dependem de motivação declarada na sentença, ou seja, cabe ao magistrado, no momento da condenação, de preferência na fundamentação, justificar a sua opção de acordo com o delito praticado e com as finalidades das sanções penais.

Como conclusão, mesmo um agente público sendo reincidente em crime de abuso de autoridade, pode o magistrado entender que não aplicará para ele o efeito da condenação de perda do cargo, do mandato ou da função pública, caso não encontre fundamentação idônea para fazê-lo.

O dever de indenizar a vítima na esfera criminal para reparação dos danos efetivamente sofridos

Seguindo o dispositivo da fixação do valor mínimo para indenização na esfera penal (387, IV, do CPP), incluído em 2008, a nova Lei de Abuso de Autoridade também trouxe previsão nesse sentido, porém, condiciona, expressamente, a fixação de valor de indenização, ao pedido da vítima.

Ora, se todos os crimes se processam mediante ação pública incondicionada, ou o pedido de indenização deverá ser feito pelo Ministério Público, ou surge a situação de oitiva obrigatória da vítima de abuso para que possa, nos autos, apresentar argumentos e elementos quantitativos de eventual dano para viabilizar a sua fixação pelo magistrado.

Período de inabilitação

Na Lei de 1965, havia o teto de prazo de inabilitação de até 3 anos, sem a fixação de um patamar mínimo.

Hoje, com a nova lei, há prazo mínimo e máximo, este ampliado: de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

A perda do cargo, mandato ou função pública pela reincidência

A reincidência específica tornou-se condição objetiva para a aplicação dos efeitos da condenação previstos nos incisos II e III.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, é reincidente aquele que comete novo crime **após** o trânsito em julgado da primeira condenação.

Só o agente público que já possui uma condenação criminal prévia, com trânsito em julgado, adquire maus antecedentes.

E, um dos requisitos da reincidência, é o agente já possuir maus antecedentes no exato momento da prática delitiva, seja ela comissiva, seja omissiva.

A falta de reincidência específica, exigida nesta lei, *não impede a condenação criminal*, sendo condição *apenas* para a perda do cargo, função ou mandato eletivo pelo abuso de autoridade.

Fato interessante será a hipótese da reincidência vencida, nos termos do artigo 64 do Código Penal, em que o agente volta a ser tecnicamente primário, mas continua com seus maus antecedentes, que nunca zeram. Todo e qualquer novo delito praticado com base nessa lei sujeitará o agente público a novo efeito da condenação, tendo em vista a manutenção constante dos maus antecedentes e o conceito de reincidência.

As penas restritivas de direito para os crimes de abuso de autoridade

Penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, na Parte Geral do Código Penal, nos termos do art. 44, ou seja, quando os seguintes requisitos estão presentes:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

A nova Lei de Abuso de Autoridade especificou três penas restritivas de direito para os condenados por crime de abuso de autoridade, tendo sido o inciso III vetado:

I – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

II – suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

III – proibição de exercer funções de natureza policial ou militar no Município em que tiver sido praticado o crime e naquele em que residir ou trabalhar a vítima, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) anos.

=> Inciso III vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

Importante destacar que os requisitos de cabimento não foram especificados nessa lei, logo, devemos utilizar os do art. 44 do Código Penal.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº

9.714, de 1998)

§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Após a avaliação do preenchimento dos requisitos de cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve-se permanecer na nova Lei de Abuso de Autoridade, pois as penas restritivas de direito aqui fixadas *são especiais* em relação às demais restritivas da Parte Geral do Código Penal.

Pena restritiva do inciso I

I – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

Nada mais coerente do que impor a um agente público servir ao público.

A diferença maior entre os seus afazeres e o cumprimento dessa pena é o momento de sua realização – nos finais de semana e períodos de folga; e a ausência de remuneração, já que se trata de uma sanção penal.

Importante destacar que o descumprimento injustificado dessa pena acarretará sua revogação e voltará para o agente público a obrigação de cumprir sua pena privativa de liberdade, provavelmente em regime aberto, nos termos do art. 33 do CP.

Novamente, no silêncio da nova Lei de Abuso de Autoridade, devemos seguir as regras da Parte Geral do Código Penal, para a operacionalização dessa pena:

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

§ 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

§ 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

§ 4º Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

Pena restritiva do inciso II

II – suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

Trata-se de pena restritiva com efeitos muito mais nefastos do que uma pena privativa de liberdade em regime aberto cumprida em casa.

O agente público ficará até 6 meses sem os seus vencimentos e vantagens, podendo sofrer prejuízos sociais e familiares muito sérios.

Como última observação, essa atual pena restritiva era apenas uma sanção administrativa na antiga Lei 4.898/65, expressamente prevista no art. 6º, alínea “c” e hoje foi erigida à pena restritiva.

INCISO III

O inciso III, que já estava previsto na Lei 4.898 e foi repetido, *ipsis literis*, na nova lei, foi vetado.

Apresentou-se a seguinte razão para esse veto presidencial:

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever a proibição apenas àqueles que exercem atividades de natureza policial ou militar no município da prática do crime e na residência ou trabalho da vítima, **fere o princípio constitucional da isonomia**. Podendo, inclusive, **prejudicar as forças de segurança de determinada localidade**, a exemplo do Distrito Federal, pela proibição do exercício de natureza policial ou militar.”

Críticas ao veto presidencial

Entendemos os argumentos apresentados em relação à isonomia, com transferência forçada do agente policial para outra localidade durante o cumprimento dessa pena restritiva, e o argumento da fragilidade na segurança pública, pelo risco de diversos agentes públicos serem condenados por esse crime e recebendo essa pena, desfalcando o efetivo local de segurança.

Há outras formas de punir via pena restritiva de direitos, como os incisos I e II deste artigo, com carga suficiente de punibilidade para atender à finalidade da pena fixada.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO V – DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA – ARTS. 6º A 8º

Art. 6º

Art. 6º

[...]

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

Art. 6º. As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO V – DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA – ARTS. 6º A 8º

Art. 7º

Art. 7º

[...]

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

[...]

Art. 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO V – DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA – ARTS. 6º A 8º

Art. 8º

Art. 8º

[...]

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

[...]

Art. 8º. Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

COMENTÁRIOS

Independência das instâncias penal, civil e administrativa

As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

Essa regra possui ressalvas, todas elas muito bem especificadas na lei.

Antes de apresentar as exceções, as faltas funcionais serão informadas pelo juiz criminal à autoridade competente para apurar eventual falta funcional do agente público, seja via sindicância, seja via processo administrativo disciplinar, a depender da falta.

Quando, no juízo criminal, ficar definido de maneira categórica que o fato narrado na denúncia nunca existiu ou, caso exista o fato, está comprovada a inexistência da autoria, não se poderá mais questionar o funcionário sobre tais acusações, ficando isento de responsabilidades civil, administrativa e penal.

Ainda, repetindo o regramento já conhecido, a lei prevê a comunicabilidade, entre instâncias, pelo reconhecimento de excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.

Quem age amparado pelo Direito não pode sofrer consequência de comportamentos ilícitos.

Não pode o Direito permitir e, ao mesmo tempo, proibir. Não se admite essa insegurança jurídica causada pela bipolaridade normativa da desatenção do legislador.

Por exemplo, o agente que decide algemar a pessoa que recebeu voz de prisão após ela iniciar atos de resistência, agredindo o policial, age amparado pelas hipóteses da súmula vinculante n. 11, das algemas, não se podendo falar de crime de abuso de autoridade.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 9º

Art. 9º

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

A nova Lei de Abuso de Autoridade é simbólica.

Para nós, advogados criminalistas, atuantes há décadas (somado o tempo de trabalho dos dois coautores), cristalina é a construção da lei para não funcionar, desde a escolha dos complexos elementos subjetivos que dependerão de prova produzida pelo Ministério Público, titular da ação penal pública para todos os tipos penais, até o preceito secundário, com penas baixas e de leve potencial ofensivo.

Explicamos:

Todos os crimes da lei são de ação penal pública incondicionada, ou seja, dependem da análise do Ministério Público para verificar se o agente público agiu, ou não, com os dolos específicos do art. 1º, ou seja: – prejudicar outrem; – beneficiar a si mesmo; – beneficiar terceiro; – por mero capricho; ou – por satisfação pessoal.

Convenhamos ser muito difícil comprovar tais intenções no plano concreto, pois existe a presunção de que os agentes públicos só podem fazer o que a lei determina (seus atos possuem fé pública). Junto com a dificuldade em comprovar os dolos específicos, há ainda as reais e boas intenções por trás de seus atos (segurança pública, fazer justiça ou busca pela verdade processual). A intenção que move o agente para a prática do ato habita o plano subjetivo, sendo de complexa comprovação.

Além disso, os inquéritos policiais, mesmo antes dessa lei, só poderiam ser instaurados se já houvesse comprovação mínima de materialidade, o que, na prática e para esse tipo de crime que depende desse dolo específico, mostra-se muito improvável.

Se o caminhar da persecução penal entre as fases de investigação e o processo penal é truncado, pior é a situação da custódia penal e cautelar.

A lei não foi feita para prender ninguém.

Em todos os crimes, a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, o que viabiliza, preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95, a suspensão condicional do processo que, se não revogada e cumprida na íntegra, extingue a punibilidade do agente, que continuará primário de bons antecedentes.

Se não for hipótese de *sursis* processual, o agente será processado criminalmente.

Nenhuma pena dos novos tipos penais é superior a 4 anos e, sendo o agente primário, será proibido prendê-lo preventivamente, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Se não será preso durante o processo, também não será preso em relação à pena privativa de liberdade. Os crimes possuem pena máxima de 4 anos, ou seja, todos os agentes condenados, se primários, receberão o regime aberto de cumprimento de pena. Ou seja, nada de prisão.

Após a condenação em primeira instância, surge outro desafio para que a punição efetiva aconteça: a prescrição intercorrente ou superveniente. Com base na pena mínima fixada na sentença, teremos prazos prescricionais de 3 anos ou 4 anos, pelas penas da lei. Pergunto a você que está lendo este livro: você acha, realmente, que será possível esgotar todos os recursos da segunda instância, do STJ e do STF antes de 3 ou 4 anos? Óbvio que não. Assim, a chance de os processos por abuso de autoridade prescreverem é quase total. Apenas não irá se beneficiar da prescrição intercorrente os agentes que possuem prerrogativa de foro.

Lembrando que a execução provisória da pena acontece para penas privativas de liberdade, *apenas*. Quando for possível substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, sequer existirá o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado do acórdão do último Tribunal Superior.

E pasmem, pela fragilidade normativa da lei, será possível questionar negativa de vigência de lei federal e divergência de Tribunais de segunda instância, hipóteses factíveis de cabimento dos recursos especiais, garantindo a subida para Brasília (STJ).

E, para coroar a dificuldade de alguém ser punido por essa lei no Brasil, a redação dos tipos penais é muito vaga, ferindo o princípio constitucional da legalidade, o que viabiliza a subida dos autos para o STF, por motivação constitucional com repercussão geral.

Sendo praticamente impossível alguém ser condenado definitivamente por essa lei, nunca os agentes públicos perderão o seu cargo por motivo criminal, pois se criou a necessidade da reincidência específica como condição objetiva de aplicação dos efeitos da condenação. Pronto. O simbolismo está montado.

Ausência de crimes culposos

Não há previsão de condutas culposas, pois incompatíveis com o desvio de finalidade da função pública e o excesso de poder dos agentes públicos, quando o agente público atuar além de sua competência e no campo dos dolos específicos indicados no art. 1º:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Não faz sentido praticar ato de abuso de autoridade, por mero capricho, de forma culposa.

Dupla subjetividade passiva

As vítimas dos crimes de abuso de autoridade serão, pelo próprio interesse público envolvendo a lisura da conduta de seus agentes públicos, o Poder Público e a pessoa que sofre com o crime de abuso de autoridade.

Ação Penal

As condutas ilícitas aqui indicadas ultrapassam a esfera individual do cidadão, por essa razão, todos os tipos penais serão de ação penal pública incondicionada. Porém, há menção expressa à ação penal privada subsidiária da pública, para suprir eventual omissão por parte do titular da ação penal, em cumprir os prazos designados no Código de Processo Penal para o oferecimento da denúncia.

Estudo analítico dos novos tipos penais

Seguimos, agora, para o estudo pontual de cada uma das figuras típicas de abuso de autoridade da nova lei.

Art. 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de:

I - relaxar a prisão manifestamente ilegal;

II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;

III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Decretar – ordenar, determinar, mandar.

Objeto material do delito

Medida de privação da liberdade

Elemento normativo do tipo

Em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por magistrado que decreta a medida de privação da liberdade.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa com a liberdade restringida e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Condutas omissivas próprias equiparadas

Continuam atreladas ao magistrado que deixar de:

* relaxar a prisão ilegal, quando manifestamente cabível o relaxamento;

* substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;

Medidas cautelares diversas da prisão

Temos 10 (dez) medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII – fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX – monitoração eletrônica.

(...)

§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).

Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Liminar ou ordem de *habeas corpus* , quando manifestamente cabível

Se o magistrado deixar de conceder liminar ou o mérito de ordem de *habeas corpus*, quando manifestamente cabível, responderá por esse crime SE agir com os dolos específicos do art. 1º desta lei.

O pedido LIMINAR não tem fundamento legal. Tem base no perigo do provimento jurisdicional demorar e na urgência da medida, além da patente ilegalidade.

Admite-se, portanto, o pedido liminar quando estiver patente que a demora no julgamento do *writ* irá incrementar ainda mais a coação imposta ao paciente:

- a) Quando o réu já estiver preso;
- b) Quando tiver sido expedido mandado de prisão ainda não cumprido;
- c) Quando, no processo, estiver marcado ato ao qual deva comparecer o réu.

São hipóteses de cabimento que irão configurar o delito de abuso de autoridade, a patente ilegalidade da situação fático-jurídica, como:

- a punibilidade já estiver extinta;

- estivermos diante de um caso de nulidade absoluta;
- esgotado o prazo da prisão cautelar ou penal.

Em casos evidentes como esses, a negativa jurisdicional caracterizaria crime se não tivesse havido veto.

Decretação ou manutenção de prisão ilegal

Esse seria o primeiro dos novos crimes de abuso de autoridade.

Tem relação direta com a privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais.

Diante do silêncio da lei, é possível concluir que o legislador quis abarcar as quatro modalidades de prisão: a prisão penal (pena privativa de liberdade) e as prisões processuais (flagrante, temporária e preventiva).

Qualquer uma delas seria objeto material desse crime quando decretadas ou mantidas fora das hipóteses legais.

E quais são as hipóteses legais e ilegais de prisão? Vamos estruturá-las para expor a relevância do tipo penal.

1.1 PRISÃO EM FLAGRANTE

Quando o infrator está cometendo o crime (flagrante próprio), acabou de cometer (flagrante impróprio), é perseguido logo após a consumação do delito ou, ainda, é encontrado com objetos ou proveito da infração (flagrante presumido ou ficto), estaremos diante de situações de flagrante delito. Com isso, o Estado está autorizado a prender essa pessoa, conduzi-la até o Distrito Policial e formalizar tal prisão com o Auto de Prisão em Flagrante.

Trata-se de medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independentemente de ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo, ou logo após ter cometido, um crime.

A Lei n. 12.403/2011 introduziu o art. 310, II, do CPP, suprimiu a possibilidade de a prisão em flagrante prender por si só, na medida em que, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequada ou insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, abre espaço para o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Logo, forçoso concluir que a prisão em flagrante passou a assumir natureza precautelar, com duração limitada até a adoção pelo juiz de uma das providências do art. 310 do CPP (relaxar a prisão em flagrante, convertê-la em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória).

Espécies lícitas de flagrante

Nos termos do art. 302 do CPP, tem-se as seguintes espécies ou modalidades de flagrante:

a) Flagrante próprio – art. 302, I e II, do CPP

O flagrante próprio ou verdadeiro se dá quando o crime está ocorrendo ou quando acaba de acontecer. Também é próprio o flagrante em crime permanente.

Trata-se de prisão efetivada quando o sujeito está praticando uma infração penal, ou quando acabou de cometê-la.

É, pois, aquela prisão em que o agente é surpreendido cometendo uma infração penal ou quando acaba de cometê-la. Aqui o agente ainda está no local do crime.

Ex.: prisão em flagrante no exato instante em que agentes criminosos buscam sair da agência

bancária onde praticavam o delito de roubo.

b) Flagrante impróprio (quase flagrante) – art. 302, III, do CPP

O flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante, ocorre quando o agente é perseguido logo após a prática do delito e é alcançado e preso. Essa perseguição deve ser ininterrupta. Não há limite temporal, desde que não pare a perseguição.

A definição da expressão “logo após” traduz uma relação de imediatidade, com perseguição iniciada em momento bem próximo da infração. Aqui o agente já deixou o local do crime.

É o tempo que decorre entre a prática do delito e as primeiras coletas de informações a respeito da identificação do autor, iniciando-se, logo após, imediatamente a perseguição. Uma vez cessada a perseguição, cessa a situação de flagrância. Ou seja, a perseguição deve ser contínua, sem interrupções.

A concepção de perseguição pode ser extraída do art. 290 do CPP, notadamente das alíneas a e b do § 1º.

Não confundir início com duração da perseguição. O início da perseguição deve ser logo após o fato; a perseguição, no entanto, pode perdurar por muitas horas e até dias, como em crime de roubo a banco, em que a polícia chega imediatamente ao local, faz o primeiro levantamento e, de imediato, sai em perseguição aos suspeitos, que se embrenharam numa mata por dias, até serem presos em flagrante.

Se o agente for preso após a cessação da perseguição, a prisão em flagrante será ilegal, devendo, pois, ser relaxada.

A perseguição deve ser ininterrupta. Uma vez cessada a perseguição, não há mais situação de flagrância, devendo-se, a partir de então, efetivar-se a prisão somente munido de mandado judicial (prisão preventiva ou temporária, conforme o caso).

c) Flagrante presumido – art. 302, IV, do CPP

O flagrante presumido ou ficto ocorre quando o agente é encontrado logo depois com arma ou instrumentos do crime.

Aqui a pessoa não é “perseguida”, mas “encontrada” na posse de objetos ou instrumentos do crime, cujo contexto fático permita a conclusão de que o sujeito detido é autor do delito.

Quanto ao alcance da expressão “logo depois”, a jurisprudência tem admitido prisões ocorridas várias horas depois do crime, ou até no dia seguinte ao do crime. Não aceita, no entanto, dias depois ao do crime.

O STF já decidiu que um intervalo de duas horas é considerado “logo depois”.

d) Flagrante esperado

O flagrante esperado ocorre quando a autoridade policial, tomando conhecimento, por fonte segura, de que será praticado um delito, desloca-se até o local indicado, aguarda o início da execução do delito ou, se for o caso, a consumação, e, na sequência, prende em flagrante o agente criminoso.

O flagrante esperado não se confunde com o flagrante provocado, uma vez que, ao contrário deste, naquele não há indução ou instigação da autoridade policial para que o agente dê início à execução do delito.

O flagrante esperado constitui modalidade de flagrante válido, regular e, portanto, legal.

e) Flagrante retardado ou diferido

Caracteriza-se pela possibilidade de retardar o momento da prisão em flagrante, não obstante estar o delito em curso, justamente para buscar maiores informações ou provas contra pessoas envolvidas em organizações criminosas ou tráfico ilícito de entorpecentes.

Há previsão de ação controlada, com destaque ao flagrante retardado ou diferido, no art. 53, II, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), no art. 4º, b, da Lei n. 9.613/98, com redação dada pela Lei n. 12.683/2012 (Lei de Lavagem de Capitais) e art. 8º da Lei n. 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas).

Nos termos do art. 53, II, da Lei n. 11.343/2006, a não atuação policial na prisão imediata em flagrante depende de autorização judicial e manifestação do Ministério Público. Essa autorização judicial está condicionada ao conhecimento do itinerário provável e à identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

Conforme o art. 8º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, o retardamento da intervenção policial não exige prévia autorização judicial, mas mera comunicação ao juiz competente que, se for o caso, fixará os limites da atuação e comunicará ao Ministério Público.

De acordo com o art. 53, II, da Lei de Drogas, a não atuação imediata da autoridade policial exige autorização judicial e manifestação do MP.

Modalidades ilícitas de flagrante

a) Flagrante provocado ou preparado

O flagrante provocado ou preparado ocorre quando uma pessoa, policial ou particular, provoca, induz ou instiga alguém a praticar uma infração penal, somente para poder prendê-la. Nesse caso, não fosse a ação do agente provocador, o sujeito não teria praticado o delito, pelo menos nas circunstâncias pelas quais foi preso.

Trata-se, na verdade, de hipótese de crime impossível, já que, por força da preparação engendrada pelo policial ou terceiro para prendê-lo, jamais o sujeito consumaria o crime. Em síntese, simultaneamente à indução à prática do crime, o agente provocador do flagrante age para evitar a consumação.

É o que diz a Súmula 145 do STF:

Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Trata-se de hipótese de crime impossível, que não é punível nos termos do art. 17 do Código Penal.

Em que pese a súmula mencionar somente o flagrante pela polícia, a ilegalidade também pode decorrer de flagrante preparado por particular.

Ex.: Suspeitando que a empregada doméstica esteja furtando objetos da residência, a dona de casa deixa uma joia na mesa de centro da sala, ficando à espreita. No momento em que a empregada pega a joia, a dona de casa, auxiliada ou não por outras pessoas, detém a empregada, prendendo-a em flagrante. Trata-se de prisão ilegal, já decorrente de flagrante preparado.

Em suma, o flagrante provocado é ilegal, devendo, pois, a prisão ser relaxada.

b) Flagrante forjado

O flagrante forjado se caracteriza pela criação de provas para forjar a prática de um crime inexistente. Aqui, a ação da autoridade policial ou de um particular visa simular um fato típico inexistente, com o objetivo de incriminar falsamente alguém.

Ex.: policial coloca/enxerta droga no interior do veículo de determinada pessoa para prendê-la pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Trata-se de hipótese de flagrante absolutamente nulo, merecendo, pois, ser relaxado. A autoridade policial ou particular que forjou o flagrante responderá por denúncia caluniosa e/ou abuso de autoridade, se for funcionário público no exercício da função.

Procedimento para a lavratura do auto de prisão em flagrante

Auto de prisão em flagrante é o documento elaborado, via de regra, sob a presidência da autoridade policial, contendo as formalidades que revestem a prisão em flagrante, tendo por objetivo precípuo retratar os fatos que ensejaram a restrição de liberdade do agente e, ainda, reunir os primeiros elementos de convicção acerca da infração penal que motivou a prisão.

Uma vez preso em flagrante, por policial ou particular, o acusado deve ser conduzido à presença da autoridade policial. Se a autoridade policial considerar se tratar de situação de flagrância e que o fato constitui crime, determinará a lavratura do auto de prisão, incumbindo-lhe proceder da seguinte forma:

a) Oitiva do condutor

O condutor é a pessoa que levou o preso até a delegacia de polícia e o apresentou à autoridade policial. Pode ser policial ou qualquer pessoa. Embora na maioria das vezes o condutor seja quem procedeu à prisão, não precisa necessariamente ser o responsável pela detenção do suspeito.

Ex.: seguranças de determinada loja prendem em flagrante uma pessoa pela prática do delito de furto e acionam a polícia militar, que conduz o preso à delegacia de polícia. Será um dos policiais, portanto, quem apresenta o preso ao delegado de polícia, figurando, assim, como condutor.

b) Oitiva de testemunhas

Em seguida, devem ser ouvidas as testemunhas que acompanharam o condutor, que, pelos arts. 304, *caput*, e 304, § 1º, do CPP, devem ser, no mínimo, duas (referem-se a “testemunhas”, no plural).

Não há qualquer vedação a que sirvam como testemunhas agentes policiais.

O condutor também pode ser considerado testemunha numerária.

A falta de testemunhas da infração não impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor deverão assinar a peça pelo menos duas pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso à autoridade (art. 304, § 2º, do CPP). Considera-se, portanto, testemunha de apresentação aquelas que presenciaram o momento em que o condutor apresentou o preso à autoridade policial.

c) Interrogatório do preso

As formalidades para o interrogatório devem observar as mesmas regras do interrogatório judicial, previstas nos arts. 185 a 196 do CPP, entre as quais se destaca a advertência ao preso do seu direito constitucional ao silêncio, sem que isso possa ser interpretado em seu desfavor (art. 5º, LXIII, da CF).

O direito à assistência por advogado constitui direito constitucionalmente assegurado ao preso (art. 5º, LXIII, da CF/88). Nesse sentido, à evidência, não cabe à autoridade policial vedar a presença do advogado nos atos que integram a lavratura do auto de prisão em flagrante, podendo o profissional acompanhar a oitiva do condutor, das testemunhas, bem como o interrogatório do flagrado.

d) Nota de culpa

Superadas essas etapas, cumpre à autoridade policial, em até 24 horas após a realização da prisão, encaminhar o auto de prisão em flagrante devidamente instruído ao juiz competente, bem

como entregar ao preso, no mesmo prazo, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Trata-se a nota de culpa de documento por meio do qual a autoridade policial científica o preso dos motivos de sua prisão, do nome do condutor e das testemunhas.

Se não for entregue nota de culpa, o flagrante deve ser relaxado por falta de formalidade essencial.

Garantias legais e constitucionais do preso

a) a comunicação imediata ao juiz competente e ao Ministério Público

De acordo com o art. 306 do CPP, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

O art. 5º, LXII, da CF/88 dispõe que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

A ausência da comunicação imediata da prisão em flagrante ao juiz competente e ao Ministério Público torna a prisão ilegal, devendo, portanto, ser relaxada.

b) a comunicação imediata da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada

Nos termos do art. 306 do CPP e do art. 5º, LXII, da CF/88, cumpre à autoridade policial providenciar a comunicação imediata da prisão em flagrante à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Essa comunicação tem por objetivo certificar familiares acerca da localização do preso, bem como viabilizar ao preso o apoio e a assistência da família.

A comunicação à família ou à pessoa pelo preso indicada constitui direito subjetivo do flagrado. Se não for observada essa formalidade pela autoridade policial, a prisão em flagrante será ilegal, devendo, pois, ser relaxada.

c) a assistência de advogado ao preso

Nos termos do art. 5º, LXIII, parte final, da Constituição Federal, o preso tem direito à assistência da família e de advogado.

Se o flagrado não informar o nome do seu advogado, deverá a autoridade policial encaminhar, em até 24 horas, cópia integral do APF à Defensoria Pública, nos termos do art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal.

Em síntese, a inobservância de qualquer dessas regras gera a ilegalidade da prisão em flagrante, devendo o juiz, ao receber os autos, e verificar que não houve comunicação imediata (ao juiz plantonista, à família do preso, ao advogado e ao Ministério Público), deixar de homologar o auto de prisão em flagrante, determinando o relaxamento da prisão por ilegalidade formal.

Providências judiciais ao receber o auto de prisão em flagrante

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá adotar uma das providências previstas na nova redação do art. 310 do CPP:

Nesse sentido, num primeiro momento, o magistrado deverá analisar o aspecto formal, a legalidade do auto de prisão em flagrante, bem como se há situação de flagrância, conforme as hipóteses do art. 302 do CPP. Se observadas as formalidades, o juiz homologa; na hipótese de alguma ilegalidade, formal ou material, o juiz deverá relaxar a prisão em flagrante.

Num segundo momento, uma vez homologado o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá verificar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança e a eventual imposição de medida cautelar diversa.

Sendo legal a prisão em flagrante, o juiz deve verificar se concederá a liberdade provisória ou se converterá a prisão em flagrante em prisão preventiva.

É importantíssimo ressaltar que a prisão preventiva somente poderá ser decretada em substituição da prisão em flagrante se estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se não for suficiente outra medida diversa da prisão, bem como se presentes as hipóteses do art. 313 do CPP.

Assim, pela leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se que a prisão preventiva é a *ultima ratio* das medidas cautelares. Ela somente deve ser decretada quando todas as demais medidas cautelares se revelarem inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Em outras palavras, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão passou a ser mais um requisito para o cabimento da prisão preventiva.

Além disso, por ser medida de caráter excepcional, o juiz somente poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Em síntese, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva (inciso II, primeira parte), desde que:

- a) a prisão seja legal (inciso I);
- b) as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes (inciso II, parte final);
- c) o agente não tenha praticado o fato ao amparo das causas de exclusão da ilicitude previstas no art. 23 do CP;
- d) estejam presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Caso contrário, será concedida liberdade provisória (com ou sem cautelares).

1.2 PRISÃO TEMPORÁRIA

É prisão cautelar de natureza processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial.

Hipóteses para a decretação

A prisão temporária pode ser decretada em relação aos crimes previstos no art. 1º, III, da Lei n. 7.960/89 e nas seguintes hipóteses:

a) Imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial

Quando a autoridade policial, atualmente, representa pela prisão temporária, é obrigada a dar os motivos dessa necessidade, expondo fundamentos que serão avaliados, caso a caso, pelo magistrado competente.

b) Residência fixa e identidade conhecida

Esses dois elementos permitem a correta qualificação do suspeito, impedindo que outra pessoa seja processada ou investigada em seu lugar, evitando-se, por isso, o indesejado erro judiciário.

Aquele que não tem residência (morada habitual) em lugar determinado ou que não consegue fornecer dados suficientes para o esclarecimento da sua identidade (individualização como pessoa) proporciona insegurança na investigação policial.

Decretação por autoridade judicial

No caso de prisão temporária, não pode o magistrado decretá-la de ofício. Deverá, invariavelmente, de existir requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Prazo

Prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias.

No caso de prisão temporária pela prática de crime hediondo e equiparados, o art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90, estabelece que o prazo de prisão temporária pode atingir 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade.

Procedimento

A prisão temporária pode ser decretada em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Não pode ser decretada de ofício pelo juiz.

No caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, tem de ouvir o Ministério Público.

O juiz tem o prazo de 24 horas, a partir do recebimento da representação ou requerimento, para decidir fundamentadamente sobre a prisão.

O mandado de prisão deve ser expedido em duas vias, uma das quais deve ser entregue ao iniciado, servindo como nota de culpa.

Efetuada a prisão, a autoridade policial deve advertir o preso do direito constitucional de permanecer calado.

Ao decretar a prisão, o juiz poderá (faculdade) determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações da autoridade policial ou submetê-lo a exame de corpo de delito.

O prazo de cinco dias (ou 30 dias) pode ser prorrogado uma vez em caso de comprovada e extrema necessidade.

A nova Lei de Abuso de Autoridade alterou a Lei da Prisão Temporária, acrescentando o § 4º-A que demanda a inserção, no mandado de prisão temporária, o período de duração da prisão (pois nem sempre segue o teto previsto em lei), bem como o dia em que o preso será liberado.

1.3 PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de modalidade de prisão processual decretada exclusivamente por juiz competente quando presentes os pressupostos e as hipóteses previstas em lei (arts. 282, 312 e 313 do CPP).

Possui natureza cautelar, uma vez que visa à tutela da sociedade, da investigação criminal e garantir a aplicação da pena. Por se tratar de medida cautelar, pressupõe a coexistência do *fumus boni iuris* (ou *fumus commissi delicti*) e do *periculum in mora* (ou *periculum libertatis*).

A liberdade é a regra constitucional de nosso Estado Democrático de Direito. Ela só pode ser retirada do indivíduo em casos expressamente previstos no ordenamento jurídico.

Como repercute na esfera da liberdade do acusado, que constitui direito e garantia fundamental do cidadão, a possibilidade de decretação da prisão preventiva encontra embasamento também no art. 5º, especificamente no inciso LXI, da Constituição, que permite a prisão provisória, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que precedida de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Portanto, somente será possível decretar a prisão preventiva “por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente”.

Para a soltura do preso e, por conseguinte, a viabilidade de responder a eventual processo em liberdade, deve-se identificar que os fundamentos que ensejaram a decretação de preventiva deixaram de existir, retirando a necessidade da medida cautelar da prisão preventiva.

Momento da decretação

Atualmente, a decretação da prisão preventiva pode ser verificada em três situações:

a) Na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, do CPP)

Nesse caso, de acordo com o art. 310 do CPP, ao receber a cópia do auto de prisão em flagrante, deverá o juiz relaxar a prisão nos casos em que esta for ilegal, convertê-la em preventiva ou ainda conceder liberdade provisória.

Vale lembrar que o juiz só decretará a preventiva nos casos em que inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

b) Quando não for prisão decorrente de flagrante, mas as circunstâncias do caso revelam a necessidade da decretação da prisão preventiva (art. 311 do CPP)

Nesse caso, o magistrado decreta, durante a investigação criminal ou ação penal, a prisão preventiva, que deve ser cumprida mediante a expedição do respectivo mandado. Em outras palavras, nessa hipótese, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Conforme se extrai do art. 311 do CPP, nesse caso, durante as investigações policiais, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Durante a ação penal, a decretação da prisão preventiva pode ser decretada de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação.

c) Quando o acusado descumprir, injustificadamente, medida cautelar diversa da prisão (art. 282, § 4º, do CPP)

Na hipótese de descumprimento injustificado da medida cautelar anteriormente imposta, o Magistrado poderá substituir por outra, determinar a cumulação com outra e, somente em último caso, decretar a prisão preventiva.

Legitimação

Diante do que dispõe o art. 5º, LXI, da CF/88, no sentido de que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, resta claro que a prisão preventiva somente pode ser decretada por ordem judicial.

Nesse caso, o magistrado decreta, durante a investigação criminal ou ação penal, a prisão preventiva, que deve ser cumprida mediante a expedição do respectivo mandado. A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Conforme se extrai do art. 311 do CPP, durante a investigação policial, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Durante a ação penal, a decretação da prisão preventiva pode ser decretada de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação e, segundo maior parte da doutrina, por representação da autoridade policial.

Pressupostos

Nos termos da parte final do art. 312 do CPP, a prisão preventiva somente é possível, se, no caso concreto, houver:

- a) prova da existência do crime; e
- b) indício suficiente de autoria.

Como o dispositivo se refere expressamente a “crime”, forçoso concluir que não cabe prisão preventiva para os acusados da prática de contravenções penais.

Fundamentos da prisão preventiva

De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

a) Garantia da ordem pública

A prisão preventiva para garantia da ordem pública somente deve ocorrer em hipóteses de crimes que se revestem de especial gravidade no caso concreto, seja pela pena prevista, seja, sobretudo, pelos meios de execução utilizados. Cabe, ainda, prisão preventiva para garantia da ordem pública diante do risco de reiteradas investidas criminosas e quando presente situação de comprovada intranquilidade coletiva no seio social ou de uma determinada comunidade.

A gravidade em abstrato do crime não autoriza a prisão preventiva. O juiz deve analisar a gravidade de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Se não fosse assim, todo crime de homicídio ou de roubo, por serem abstratamente graves, autorizariam a prisão preventiva compulsória.

Em suma: a gravidade em concreto que autoriza a prisão preventiva é aquela revelada não só pela pena abstratamente prevista para o crime, mas também pelos meios de execução, quando a perversidade e o desprezo pelo bem jurídico atingido reclamarem medidas imediatas para assegurar a ordem pública, decretando-se a prisão preventiva.

O clamor público, por si só, não autoriza o decreto da prisão preventiva, servindo como uma referência adicional para o exame da necessidade da custódia cautelar, devendo, portanto, estar acompanhado de situação concreta excepcional, que justifique a prisão processual.

b) Garantia de ordem econômica

Nesse caso, visa-se, com a decretação da prisão preventiva, impedir que o agente, causador de seriíssimo abalo à situação econômico-financeira de uma instituição financeira ou mesmo de órgão do Estado, permaneça em liberdade, demonstrando à sociedade a impunidade reinante nessa área.

Equipara-se o criminoso do colarinho branco aos demais delinquentes comuns, na medida em que o desfalque em uma instituição financeira pode gerar maior repercussão na vida das pessoas, do que um simples roubo contra um indivíduo qualquer.

c) Conveniência da instrução criminal

É empregada quando houver risco efetivo para a instrução criminal, e não meras suspeitas ou presunções. Ou seja, simples receio ou medo da vítima ou testemunha em relação ao acusado não autoriza o decreto da prisão preventiva.

Não cabe prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal quando se pretende interrogar ou compelir o acusado a participar de algum ato probatório (acareação, reconstituição ou reconhecimento), sobretudo pela violação ao direito ao silêncio.

Evidentemente, sendo a custódia decretada unicamente com base no fundamento *in examen*, uma vez esgotada a instrução, não há mais razões para que subsista o decreto, impondo-se, então, a revogação, conforme se infere dos arts. 316 e 282, § 5º, ambos do CPP. Do contrário, passa a preventiva a se constituir uma forma de execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal.

d) Garantia da aplicação da lei penal

Significa assegurar a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da infração penal.

É a prisão para evitar que o agente empreenda fuga, tornando inútil a sentença penal por impossibilidade de aplicação da pena cominada.

Todavia, o risco de fuga não pode ser presumido. Tem de estar fundado em circunstâncias concretas. Logo, não havendo nenhum elemento concreto, mas mera suspeita de fuga, não há motivo suficiente para o decreto da prisão preventiva.

Descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares

Nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 319), conforme o art. 282, § 4º, do CPP.

Nesse caso, é imprescindível que o juiz atente para a proporcionalidade, devendo sempre priorizar a cumulação de medidas cautelares ou adoção de outra mais grave, optando pela prisão preventiva em último caso.

Portanto, o juiz deve priorizar a aplicação de medida cautelar diversa da prisão caso entenda adequada e suficiente diante do caso concreto. Ex.: suponha que o juiz determine a proibição do acusado de estabelecer contato com pessoa determinada (art. 319, III, do CPP) e ele descumpra a medida. Nesse caso, o juiz deve, primeiro, optar por substituir a medida ou aplicar outra em cumulação, para, só então, se persistir o descumprimento, decretar a preventiva, conforme dispõe o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.

Condições de admissibilidade da prisão preventiva

Não se mostra suficiente a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, devendo, além disso, ser decretada somente em determinadas espécies de infração penal ou sob certas circunstâncias. Trata-se das condições de admissibilidade.

a) Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos

Nesses termos, somente é cabível a prisão preventiva para os crimes dolosos com pena máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos. Logo, não cabe, em tese, prisão preventiva por crime culposos.

O limite de quatro anos tem a sua razão de ser, porquanto, se condenado definitivamente, o agente poderá, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, ter substituída sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Nesse sentido, se condenado o agente não irá, a princípio, para prisão, com muito mais razão não poderá ser mantido preso quando incide a seu favor a presunção da inocência.

Além disso, se condenado a pena não superior a quatro anos, o agente poderá cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto, usufruindo dos benefícios inerentes a esse regime carcerário, entre eles a possibilidade de trabalho externo.

São inúmeros os crimes que, em razão desse inciso, não comportam prisão preventiva, tais como furto simples (art. 155 do CP), apropriação indébita (art. 168 do CP), receptação simples (art.

180 do CP), descaminho (art. 334 do CP), entre outros.

No caso de concurso material de crimes, somam-se as penas para fins de prisão preventiva. Nos casos de concurso formal de crimes e crime continuado, considera-se a causa de aumento no máximo e a de diminuição no mínimo. Em qualquer caso, se a pena máxima for superior a quatro anos, poderá, em tese, ser decretada a prisão preventiva.

Tratando-se de causas de aumento de pena e de diminuição da pena, deve-se considerar a quantidade que mais aumente ou que menos diminua, respectivamente, a fim de se chegar à pena máxima cominada ao delito.

Ex.1: Furto noturno, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal a pena é aumentada em 1/3. O furto simples não autoriza o decreto da prisão preventiva, pois a pena máxima cominada é de quatro anos. Todavia, se for praticado durante repouso noturno, a pena é aumentada em 1/3, superando os quatro anos e, por conseguinte, autorizando o decreto da prisão preventiva.

Ex.2: Tentativa de estelionato. Conforme o art. 171 do CP, a pena máxima cominada ao delito de estelionato é de cinco anos. Na hipótese de tentativa de estelionato, essa pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3, conforme dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal. Se aplicada sobre a pena de cinco anos a redução mínima (1/3), a pena resultará em três anos e quatro meses, quantidade, portanto, incompatível com o disposto no art. 313, I, do CPP, o decreto da prisão preventiva.

b) Se o réu ostentar condenação anterior definitiva por outro crime doloso no prazo de cinco anos da reincidência

Trata-se da hipótese do réu reincidente em crime doloso. Nesse sentido, ainda que se trate de crime com pena máxima não superior a quatro anos, poderá ser decretada a prisão preventiva se o réu for reincidente em crime doloso, desde que presente um dos fundamentos do art. 312 do CPP.

Assim, se uma pessoa primária está sendo acusada por crime cuja pena máxima não excede quatro anos, descabe inicialmente a prisão preventiva, ainda que haja provas de que ela, por exemplo, está ameaçando testemunhas, podendo, nesse caso, ser aplicada uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Somente se descumprida a medida cautelar, pode-se aventar a possibilidade de decreto da preventiva, com base no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, do CPP.

c) Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência

Por fim, cabe preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Além das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a nova redação do art. 313 do CPP incluiu os casos de violência doméstica, não só em relação à mulher, mas a criança, adolescente, idoso, enfermo ou qualquer pessoa com deficiência.

Essas medidas protetivas estão previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 43 a 45 do Estatuto do Idoso, e arts. 98 a 101 do ECA.

Convém registrar que, nesse caso, a prisão preventiva será decretada apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, indicando, assim, a necessidade de imposição anterior das cautelares protetivas de urgência.

Algumas hipóteses que não admitem a decretação da prisão preventiva

a) Nas contravenções penais

Não cabe prisão preventiva nas contravenções penais, uma vez que o próprio art. 312 prevê a

possibilidade de prisão preventiva na hipótese de existência de crime, carecendo, assim, previsão legal quando se tratar de contravenção penal.

b) Na hipótese de o agente ter praticado o fato acobertado por uma das causas excludentes de ilicitude

Nos termos do art. 314 do CPP, a decretação da prisão preventiva é vedada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, que o agente praticou o ato sob a égide de uma das causas excludentes de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal).

Sujeito Ativo

Tem como sujeito ativo do delito os magistrados. Logo, estamos diante de um crime próprio.

Sabe-se que a única autoridade com competência para decretar uma prisão é a autoridade judicial.

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao dispor que se constitui crime ‘decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais’, gera insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto e que comportam interpretação, o que poderia comprometer a independência do magistrado ao proferir a decisão pelo receio de criminalização da sua conduta.”

Críticas ao veto presidencial

A equipe governamental, responsável pelo veto em comento, não entendeu a lei em seu todo.

Não está dentro da independência funcional agir da seguinte forma:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Como justificar a privação da liberdade de alguém fora das hipóteses legais e carregado de má-fé, valendo-se de sua função jurisdicional e não ser criminalmente responsabilizado?

O receio da magistratura em ver seus agentes punidos por esse crime expõe a falta de interpretação sistemática da nova lei, pois todos os tipos penais exigem as finalidades específicas aqui demonstradas, não sendo crime, uma prisão aparentemente legal.

Uma das razões de veto é a interferência da lei na independência funcional. Essa garantia jurisdicional está prevista no art. 41 da LOMAN e, além de ser uma garantia, a sua violação já caracteriza conduta antiética:

Lei Complementar n. 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN)

Art. 41 – Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.

Código de Ética da Magistratura Nacional:

Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais.

Art. 5º Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas

influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos.

Art. 6º É dever do magistrado denunciar qualquer interferência que vise limitar sua independência.

A independência funcional, por estarmos tratando de agentes públicos, está limitada pela lei.

Agindo fora da lei por razões culposas, ou boas intenções, não configuraria o tipo penal.

Agindo fora da lei por razões dolosas diversas dos 5 dolos específicos previstos em lei, impedirá, também, a adequação típica com esse crime.

Trata-se de muito barulho e muita preocupação para justificar abusos.

Autoridade policial ou representante do MP

Não poderia a autoridade policial ou o representante do Ministério Público ser sujeito ativo desse delito, pois não detém poderes para decretar a prisão de ninguém, competindo ao primeiro representar pela prisão cautelar e, ao segundo, requerer, sem poderes de decretação.

Também não se poderá falar em concurso de agentes para a prática desse delito, pois a decisão jurisdicional é livre de qualquer interferência externa e tem por base a legalidade.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 10

Art. 10

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

COMENTÁRIOS

Este crime de abuso de autoridade busca evitar o constrangimento causado por condução coercitiva de pessoa sem lastro na lei ou sem ter, previamente, intimado a pessoa, para comparecer em juízo.

Apenas os magistrados decretam a condução coercitiva e é esse o verbo do tipo penal, e não o agente que executa o mandado, pois a decretação não parte dele.

Temos, no Código de Processo Penal, diversos dispositivos que autorizam a condução coercitiva de pessoas, desde a vítima do crime até o réu.

O novo crime tratou apenas de testemunha e do investigado, deixando o ofendido de fora, o que nos causou perplexidade. É uma autorização implícita para a condução coercitiva da vítima sem prévia intimação ou quando manifestamente descabida?

Vítima não é testemunha, e muito menos investigado. E devemos, por respeito aos princípios penais da legalidade, ater-nos à literalidade do dispositivo criminal.

Eis o regramento do Código de Processo Penal:

TÍTULO VII – DA PROVA

CAPÍTULO V – DO OFENDIDO

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade.

CAPÍTULO VI – DA TESTEMUNHAS

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

RITO SUMÁRIO

Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

RITO DO JÚRI

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

(...)

§ 7º Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

Do tipo penal

Decretar - *ordenar, determinar, mandar*.

O verbo do tipo será praticado com a finalidade de forçar o comparecimento do investigado ou testemunha em juízo fora das hipóteses permitidas no Código de Processo Penal.

Objeto material do delito

A condução coercitiva de testemunha ou investigado.

Elemento normativo do tipo

Manifestamente descabida ou sem prévia intimação.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por magistrado que decreta a condução coercitiva de testemunha ou investigado, pois o verbo do tipo penal escolhido foi *decretar*.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que é conduzida coercitivamente e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 4 anos coloca o crime no rito ordinário, se o agente público não possuir foro de prerrogativa de foro.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 11

Art. 11

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 11. (VETADO).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Executar – *Efetivar, cumprir ordem, realizar, acatar, concretizar.*

O tipo penal pune quem prende alguém no Brasil sem que a pessoa esteja em situação de flagrância ou sem ordem escrita da autoridade judiciária.

O próprio crime do art. 11 excepciona o delito de abuso de autoridade para as hipóteses de transgressão militar ou de crime militar próprio. Essa mesma exceção está na CRFB/88, art. 5º, inciso LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

Para a Justiça Castrense (Militar), o conceito de transgressão militar encontra-se no Decreto 4.346/2002, nos arts. 14 e 15, remetendo ao anexo I do mesmo decreto. A lista de transgressões militares está reproduzida em Anexo V deste livro. Qualquer uma das 113 condutas não caracterizará o crime do art. 11 de abuso de autoridade.

Em relação ao crime próprio indicado no tipo penal, teríamos crime militar próprio quando somente um militar poderá praticá-lo, como a deserção.

Em relação ao condenado ou internado foragido, obviamente que não será necessário um mandado de prisão ou a situação de flagrância para recapturá-los, agindo bem o legislador em privar os agentes públicos da adequação típica do artigo em comento. Nessa hipótese, nem o veto seria necessário para continuar a legitimar essas situações.

Objeto material do delito

A prisão do investigado.

Elemento normativo do tipo

Que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária. Seria o crime para punir as prisões ilegais.

Sujeito ativo

Crime próprio, eis que a Carta Magna autoriza qualquer pessoa a dar voz de prisão de flagrante para outra, porém essa lei exige a qualidade de agente público para a prática dos ilícitos de abuso de autoridade.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que é presa ou sofre a busca e apreensão sem flagrante ou mandado de prisão e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

A pena máxima em abstrato de 4 anos seguirá o rito comum ordinário, salvo se o agente público detiver prerrogativa de foro.

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao dispor sobre a criminalização de execução de captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito gera insegurança jurídica, notadamente aos agentes da segurança pública, tendo em vista que há situações que a flagrância pode se alongar no tempo e depende de análise do caso concreto. Ademais, a propositura viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena cominada.”

Críticas ao veto presidencial

Fora das exceções que não caracterizariam crime – casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei; de condenado ou internado fugitivo – não se justifica esse veto.

Para a configuração típica, seria necessário o dolo direto de executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em flagrante ou sem ordem judicial escrita.

Além disso, só existiria o fato típico se presentes um dos 5 dolos específicos do parágrafo único do art. 1º dessa lei:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Quase impossível verificar, no caso concreto, situações tão graves quanto essas comprovadas de plano.

Quanto ao flagrante permanente, a própria prisão, para ser decretada, exige o corpo de delito de situações que se propagam no tempo, como, por exemplo, droga apreendida em depósito ou vítimas em cativeiro. Não se cria situação de flagrante permanente sem o objeto material do delito que acompanhará o agente preso para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Sobre o desrespeito ao princípio da proporcionalidade, o preceito secundário da norma ficou aquém à gravidade da conduta praticada acompanhada de tamanha má-fé e consequências para a pessoa presa injustamente. Seria uma desproporcionalidade inversa. A pena deveria ter sido maior e o artigo não deveria ter sido vetado.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 12

Art. 12

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I - deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

II - deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;

III - deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

IV - prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

COMENTÁRIOS

Crimes omissivos próprios

O tipo penal descreve condutas omissivas em seu *caput* e nos incisos do parágrafo único. O dever de impedir o resultado foi expressamente previsto no tipo penal.

Estamos diante de antigos vícios de formalidade que contaminavam o auto de prisão em flagrante e resultavam no relaxamento da prisão na audiência de custódia. Hoje, tais vícios formais foram selecionados para caracterizar crimes de abuso de autoridade quando praticados de maneira intencional e com um dos dolos específicos do art. 1º da Lei.

Objeto material do delito

A prisão em flagrante e suas formalidades de decretação previstos nos artigos 304 e 306 do CPP.

Elemento normativo do tipo

Injustificadamente.

Sujeito ativo

Para o *caput* e os incisos I a III do parágrafo único, somente a autoridade policial pode praticar, sendo, portanto, crime próprio.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que foi presa sem a devida comunicação para a autoridade competente e indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Vícios de formalidades expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal

O Código de Processo Penal especifica uma série de formalidades para o momento em que alguém é preso em flagrante e conduzido para o Distrito Policial, para a entrega do preso e a lavratura do auto de prisão em flagrante:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Diante do regramento legal, fica evidente a série de formalidades, incluindo prazos, para que os direitos constitucionais do preso sejam respeitados.

O desrespeito às formalidades deixa de ser mero fundamentos processual para relaxar prisões ilegais e se tornam crime de abuso de autoridade.

Condutas típicas praticadas pelo delegado

* ausência de comunicação à prisão em flagrante no prazo de 24 horas a contar do término da

lavratura do auto de prisão em flagrante;

- * deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou.

- * deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;

- * deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas.

Condutas típicas praticadas pela autoridade judiciária

- * Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

Não há motivo previsto em lei para que uma pessoa submetida à pena privativa de liberdade ou medida de segurança fique com a sua liberdade restringida mais tempo do que a legislação permite.

Hoje, com o avanço da tecnologia no âmbito dos processos judiciais e sistemas, não há desculpa para não tomar ciência da data limite de liberação do preso do ou internado na data correta.

Agregue-se a essa não expedição do alvará de soltura com um dos 5 dolos específicos previstos no art. 1º desta lei.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 13

Art. 13

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I - exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

* Inciso III vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

* Artigo retificado no DOU 18.09.2019.

=> Inciso III vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o inciso foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS

Constranger – *sujeitar, intimidar, subjugar, forçar.*

O verbo do tipo está associado à submissão de vontade da vítima aos interesses de quem constrangeu.

Objeto material do delito

A humilhação pública de preso ou detento.

Sujeito ativo

Trata-se de crime próprio pois, para constranger alguém preso, é necessário ter acesso ao detento e poder sobre ele, em razão da função pública desempenhada.

Parece-nos que se trata de um crime próprio, pois somente a pessoa que detém preso sob a sua custódia poderia, em tese, realizar as condutas tipificadas como crime de abuso de autoridade.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa presa e humilhada e, indiretamente, o Poder Público.

Preceito secundário

* a pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

* Por ser punido com detenção, não comporta o regime inicial fechado.

* Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ter sido o delito praticado com violência ou grave ameaça.

Análise do tipo penal

Responderá pelo crime de abuso de autoridade a pessoa que constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

* exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

Trata-se de tutelar penalmente a preservação da intimidade da pessoa presa. A utilização de constrangimento para exhibir o corpo do preso ou detento

* submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

* produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro.

Razões do veto ao inciso III do art. 13

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois o princípio da não produção de prova contra si mesmo não é absoluto como nos casos em que se demanda apenas uma cooperação meramente passiva do investigado. Neste sentido, o dispositivo proposto contraria o sistema jurídico nacional ao criminalizar condutas legítimas, como a identificação criminal por datiloscopia, biometria e submissão obrigatória de perfil genético (DNA) de condenados, nos termos da Lei n. 12.037, de 2009.”

Críticas ao veto presidencial

Vetou-se a criminalização da conduta que desrespeita o *nemo tenetur se detegere* – vedação da produção de prova contra si.

A lei incluiu entre as modalidades típicas o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, que forcem a pessoa a produzir prova para a sua autoincriminação. E essa incriminação foi vetada.

Pífia a argumentação de que a cooperação passiva validaria violência ou grave ameaça para a obtenção de prova contra o agente.

Cooperação passiva significa aceite do agente ou, cumprimento da lei, como nos casos da Lei de Identificação Criminal, mencionada nas razões de veto, em que o próprio STF já se posicionou não ser admitida violência ou grave ameaça para obtenção de material para colheita de perfil genético, devendo ser feita de forma não invasiva e não dolorida. Algo incompatível com a violência ou a grave ameaça.

Agiu mal a equipe do governo federal ao vetar esse dispositivo, pois é extremamente grave compelir uma pessoa, por exemplo, a soprar o etilômetro valendo-se de violência.

Esse inciso não geraria insegurança jurídica, pelo contrário, criaria um ambiente de respeito às normas legais e constitucionais de obtenção de prova com a ameaça da tutela penal.

Importante ressaltar que, além da violência ou grave ameaça, seria necessário, para a configuração típica subjetiva, um dos 5 dolos específicos do art. 1º desta lei:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Inútil vetar esse dispositivo legal, pois, em sua ausência, os agentes públicos responderão pelo crime do art. 322 do Código Penal:

Violência arbitrária

Art. 322 – Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Assim, todas as razões de veto para afastar essa tipicidade serão vazias, pois os agentes que assim procederem irão responder criminalmente e sofrer, pela conexão entre a função pública e o bem jurídico violado, os efeitos da condenação.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 14

Art. 14

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 14. (VETADO).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Fotografar / filmar – *capturar imagem*

Divulgar – *tornar conhecido, difundir, espalhar*

Publicar – *propagar, transmitir, alastrar, popularizar*

Objeto material do delito

Preso, internado, investigado, indiciado ou vítima.

Elemento normativo do tipo

Sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal.

Se o consentimento for viciado (erro, dolo, coação, simulação ou fraude).

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa cuja imagem é exposta e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever como elemento do tipo ‘com o intuito de expor a pessoa a

vexame ou execração pública’, gera insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto e que comporta interpretação, notadamente aos agentes da segurança pública, tendo em vista que não se mostra possível o controle absoluto sobre a captação de imagens de indiciados, presos e detentos e sua divulgação ao público por parte de particulares ou mesma da imprensa, cuja responsabilidade criminal recairia sobre os agentes públicos. Por fim, o registro e a captação da imagem do preso, internado, investigado ou indiciado poderá servir no caso concreto ao interesse da própria persecução criminal, o que restaria prejudicado se subsistisse o dispositivo.”

Críticas ao veto presidencial

Plenamente justificável a preocupação governamental com as seguintes situações práticas:

- impossível controle de captação de imagens por particulares ou imprensa.
- interesse da persecução penal para as investigações.

Entretanto, essas razões de veto não levaram em consideração a intenção do agente público de expor a pessoa a vexame ou execração pública. É isso que caracteriza o abuso de autoridade, e não o interesse público das investigações criminais nem o dever de informar da imprensa.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 15

Art. 15

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

* Parágrafo único vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

I - de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou

II - de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono.

=> Parágrafo único vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS

Constranger

Sujeitar, intimidar, subjugar, forçar.

Objeto material do delito

O depoimento de pessoa que deva guardar sigilo.

Elemento normativo do tipo

Pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público responsável pela colheita de depoimento de pessoa que deva resguardar sigilo.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que é constrangida a depor violando seu dever de sigilo e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

I – de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou

II – de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono.

Razões do veto do parágrafo único do art. 15

“O dispositivo proposto gera insegurança jurídica e contraria o interesse público ao penalizar o agente pelo mero prosseguimento do interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, embora o interrogatório seja oportunidade de defesa, pode ser conveniente à pessoa o conhecimento das perguntas formuladas, bem como exercer o silêncio apenas em algumas questões, respondendo voluntariamente às demais, cuja resposta, a seu exclusivo juízo, lhe favoreçam. Além disso, a falta de assistência por advogado ou defensor público durante o interrogatório não deve ser criminalizada, uma vez que se trata de procedimento administrativo de natureza inquisitiva e não configura falta de defesa ao indivíduo.”

Críticas ao veto presidencial parcial

Discordamos do veto presidencial.

Parece que não foi lido o artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade por quem vetou os dispositivos.

A justificativa para o veto foi a utilidade das questões apresentadas no interrogatório para defesa futura do interrogado que optou por permanecer em silêncio.

Caso isso fosse real, bastaria reduzir as questões que seriam feitas por escrito e entregá-las para o advogado ou defensor, sem constranger o interrogado a continuar sendo interrogado mesmo após exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

E o pior, só existe qualquer crime dessa lei se houver um dos 5 dolos específicos previstos no art. 1º e, se presentes, o tipo penal faz todo o sentido e a punição ao agente público com desvio de finalidade pública seria muito bem-vinda.

O segundo argumento para vetar foi a desnecessidade da presença de advogado ou defensor público para acompanhar o suspeito em seu interrogatório policial. Realmente, não gera nulidade a ausência de defensor, que será validada nas 24 horas seguintes na audiência de custódia.

Com o veto, teremos um vazio normativo após a revogação expressa do crime do art. 350, incisos III ou IV do Código Penal, que já punia essa conduta, e agora teremos a impune dos agentes públicos pelo veto presidencial.

Essa é a redação do artigo em comento:

Exercício arbitrário ou abuso de poder

Art. 350 – Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder:

Pena – detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único – Na mesma pena incorre o funcionário que:

(...)

III – submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

IV – efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.

A legislação garante ao interrogado o direito de permanecer em silêncio na parte do interrogatório que trata dos fatos. Ao optar pelo silêncio, não deve ser constrangido com novos questionamentos, pois não serão respondidos.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 16

Art. 16

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Identificar – qualificar ou nomear.

Objeto material do delito

A identificação do agente público.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público que deixa de se identificar ou se identifica falsamente ao preso.

Dupla subjetividade passiva

É o preso que fica sem conhecer o responsável pela sua captura ou interrogatório e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 6 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 2 anos leva o agente público para o rito comum sumaríssimo, salvo de detiver prerrogativa de foro, situação em que será denunciado, processado e julgado em Tribunal respectivo de competência originária.

Razões de veto

“A propositura legislativa contraria o interesse público pois, embora seja exigível como regra a identificação da autoridade pela prisão, também se mostra de extrema relevância, ainda que em situações excepcionais, a admissão do sigilo da identificação do condutor do flagrante, medida que se faz necessária com vistas à garantia da vida e integridade física dos agentes de segurança e de sua família, que, não raras vezes, têm que investigar crimes de elevada periculosidade, tal como aqueles praticados por organizações criminosas.”

Críticas ao veto presidencial

Optou-se por bem jurídico maior – a vida e integridade física de agentes policiais que enfrentam e dão voz de prisão em flagrante para criminosos de alta periculosidade.

Novamente, ignorou-se a necessidade das finalidades específicas de todos os tipos penais expressas no § 1º do art. 1º desta lei:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Claro que o sigilo das investigações, quando amparado por lei, sujeitará os agentes de segurança à prática de condutas por exercício regular de direito ou, ainda, estrito cumprimento de dever legal.

Necessária se faz uma ponderação de valores entre a identificação dos responsáveis pela prisão e prováveis retaliações, amplamente divulgadas pelos meios de comunicação.

A falta de identificação do agente responsável pela prisão não é constante, pois durante a própria lavratura do flagrante ou recondução ao término do cumprimento de pena, será possível identificar um agente público para, após negativa dessa autoridade coatora, buscar a liberdade usando as ações autônomas de impugnação, como o habeas corpus.

O agente da custódia será identificado para que receba pedido de liberdade provisória, relaxamento ou revogação da prisão.

De qualquer forma, o artigo foi vetado em sua integralidade, tendo como base as situações de exceção, que já estariam amparadas por legislação específica (ex.: os agentes infiltrados da Lei 12.850/2013), mostrando-se equivocado o veto.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 17

Art. 17

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 17. (VETADO).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Submeter – Sujeitar alguém a algo contra sua vontade. Intimidar, subordinar.

O verbo do tipo será praticado quando o ato de algemar alguém não tiver fundamento legal para fazê-lo, além dos dolos específicos do § 1º do art. 1º.

Trata-se da criminalização do desrespeito às hipóteses permissivas para o uso de algemas, desenhado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 11:

Súmula Vinculante 11

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Objeto material do delito

O uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros.

Elemento normativo do tipo

Quando manifestamente não houver hipótese autorizativa.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público responsável pela submissão de preso ao uso de algemas.

Dupla subjetividade passiva

É o preso, internado ou apreendido e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao tratar de forma genérica sobre a matéria, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, há ofensa ao princípio da intervenção mínima, para o qual o Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, além do fato de que o uso de algemas já se encontra devidamente tratado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n. 11, que estabelece parâmetros e a eventual responsabilização do agente público que o descumprir.”

Comentários ao veto

Concordamos parcialmente com o veto deste artigo, pois não se deve utilizar o Direito Penal de forma desnecessária.

A SV n. 11 apresenta as hipóteses em que alguém pode ser algemado no Brasil e, caso alguém seja submetido ao uso de algemas fora daquelas hipóteses, a própria súmula apresenta as consequências: a nulidade da prisão e eventual responsabilidade penal, civil e administrativa dos responsáveis pela prisão.

É possível utilizar algemas:

- resistência;
- fundado receio de fuga;
- perigo à integridade física própria;
- perigo à integridade física alheia;
- por parte do preso ou de terceiros.

Para que o tipo penal do art. 17 fosse praticado, seria necessário estar em um contexto fático diversos das permissões, antes apresentadas no enunciado do STF e agora na lei.

Além das hipóteses previstas em lei, seria necessário praticar o ato com uma das 5 finalidades previstas no art. 1º desta lei:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Em relação ao parágrafo único, a pena seria aplicada em dobro se:

I – o internado tem menos de 18 (dezoito) anos de idade;

II – a presa, internada ou apreendida estiver grávida no momento da prisão, internação ou apreensão, com gravidez demonstrada por evidência ou informação;

III – o fato ocorrer em penitenciária.

Agiu mal a equipe que vetou o parágrafo único desta lei.

Nunca tivemos no Brasil uma lei federal que regulamentasse o uso das algemas por parte da polícia. Justamente por força dessa lacuna é que o Supremo Tribunal Federal foi forçado a

regulamentar, no plano jurisprudencial vinculante, as hipóteses em que algemar alguém seja permitido.

Este artigo foi vetado e ampliava as hipóteses, de forma taxativa, vedando o uso de algemas para menores de 18 anos, grávidas e pessoas dentro de penitenciárias.

[\[...\]](#)

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 18

Art. 18

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

COMENTÁRIOS

Submeter – sujeitar alguém a algo contra sua vontade. Intimidar, subordinar.

Objeto material do tipo penal

Interrogatório policial

Sujeito ativo

Crime próprio, pois só responde a autoridade competente que pode presidir o interrogatório policial.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa presa e, indiretamente, o Poder Público.

Atipicidade formal

Não estão abrangidos no tipo penal, o P.I.C. – Procedimento de Investigação Criminal, feito diretamente pelo Ministério Público; A Comissão Parlamentar de Inquérito e qualquer outra forma de investigação preliminar, uma vez que o legislador foi específico, tendo como objetivo os interrogatórios da polícia. E é vedado, ao intérprete da lei, utilizar a analogia *in malam partem*. Nunca se pode interpretar para punir.

Controvérsia sobre o tema – repouso noturno

A nova Lei de Abuso de Autoridade apresentou um conceito cronológico para o conceito noturno: das 21h às 5h.

Antes dessa lei, tínhamos o seguinte regramento:

- tempo não é fixado em horas, mas em razão dos usos e costumes de uma sociedade;
- repouso noturno não se confunde com noite.

Esta se embasa em critério físico-astronômico (ausência de luz solar), ao passo que aquele tem por fundamento o critério psicossociológico, segundo o qual se trata de período em que as pessoas dormem e que se sujeita aos costumes locais.

Parâmetros jurisprudenciais anteriores

Delito praticado em via pública às 19h – agente condenado por furto praticado durante o período noturno (155, § 1º, do Código Penal). Inadmissibilidade. o horário do delito (19h) não pode ser considerado como repouso noturno, já que, nesse momento, a cidade está longe de entrar em período de repouso. Mais adequado é tomar o horário a partir de 22h para ser considerado como repouso noturno (AgRg no REsp n. 1.251.465/MG, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/2/2014).

No novo tipo penal agora em comento, menciona-se, também, o período de repouso noturno. Essa similaridade normativa fará com que o STJ tenha o mesmo entendimento, ou seja, não será repouso noturno pelo simples fato de ter anoitecido e estar escuro.

Diante da omissão normativa do art. 18, poderíamos utilizar como parâmetro o voto do STJ que, por sua vez, buscou esse conceito no Direito do Trabalho.

Período noturno na Justiça do Trabalho

Existe, em outro diploma normativo, o conceito do que seria o período noturno.

CLT – Art. 73, § 2º

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

Trata-se um parâmetro razoável, mas, nem sempre, compatível com a prática.

No dia a dia forense, não se marca interrogatório de acusado após às 19 horas, por não ser o horário de trabalho normal da maioria dos escrivães, que são os executores do ato, na prática, ficando a autoridade policial gerindo os trabalhos.

Tortura prova e crime de abuso de autoridade

Qual é o conceito de tortura?

A Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, em seu art. 1º, estabelece como conceito de tortura:

“qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.”

Para que exista o crime de tortura, é necessário que o sujeito ativo do delito tenha a intenção de causar sofrimento físico ou mental, que podem ser conceituados com: é o sofrimento desnecessário e cruel do ser humano, que pode se dar em seu corpo (sofrimento físico) ou em sua mente (sofrimento mental), por meio da infligência de tormentos.

A depender do horário do interrogatório e de sua intensidade, o agente público responderá, apenas, pelo crime de tortura.

Se a intenção for diversa, ou seja, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, por mero capricho ou por satisfação pessoal, a utilização dolosa do horário do repouso noturno para interrogar o suspeito, imputará ao agente público o crime aqui comentado (art. 18, da Lei

Dignidade da pessoa humana

A dignidade da pessoa humana é um princípio do Estado Democrático de Direito, que é o Estado que respeita e garante os direitos humanos e os direitos fundamentais dos seus cidadãos. Ele pode ser entendido como um princípio que coloca limites às ações do Estado.

Dessa forma, a dignidade da pessoa humana deve ser usada para basear decisões tomadas pelo Estado, sempre considerando os interesses e o bem-estar dos cidadãos. Isso significa que, além de garantir às pessoas o exercício dos seus direitos fundamentais, o Estado deve agir com cuidado suficiente para que esses direitos não sejam desrespeitados. É uma obrigação do Estado, através dos governos, tomar medidas para garantir direitos e bem-estar dos cidadãos. Da mesma maneira, também é tarefa do Estado cuidar para que os direitos fundamentais não sejam violados.

E, no caso de interrogatório no horário em que as pessoas (até então presumidas inocentes) deveriam estar descansando, viola frontalmente a dignidade da pessoa humana e, por essa razão constitucional, agiu bem o legislador em tipificar essa conduta.

Atipicidade do fato por ausência de elemento subjetivo

O próprio tipo penal excepciona as situações em que não haverá abuso de autoridade:

“salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações”.

Não será abuso se as declarações prestadas no período do repouso noturno forem em decorrência de flagrante ou se este estiver devidamente assistido consentir em prestar esclarecimentos.

Nessas hipóteses, não há dolo em submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, pois ausente o elemento subjetivo de abusar da autoridade e os dolos específicos do art. 1º.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 19

Art. 19

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 19. Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

COMENTÁRIOS

Verbos do tipo penal

Impedir – obstar, enterrar, embaraçar

Retardar – Atrasar, adiar, procrastinar

Objeto material do delito

O pleito de preso.

Elemento normativo do tipo

Injustificadamente.

Conduta vedada ao agente público

Impedir ou retardar, sem nenhuma justificativa legal, o envio de pedido de preso para a autoridade judiciária competente, requerendo que seja analisada a situação de sua prisão para aferir a sua legalidade ou as circunstâncias em que se deu a sua custódia.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agentes públicos que têm contato direto com os presos, recebendo de suas mãos seus pedidos e negando o envio desses pleitos aos magistrados competentes.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que está presa e que tem seu pleito barrado, impedindo o seu contato com a

autoridade judiciária. Indiretamente é o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 4 anos leva esse crime para o rito comum ordinário, salvo se o agente público detiver foro de prerrogativa de função.

Pleito de pessoa presa ao juiz

Imagine uma pessoa presa ilegalmente, trancada em uma cela, sem auxílio profissional de um advogado/defensor público e sem familiares que o apoiem. Está sozinho. Ciente de seu direito de ser levado fisicamente à presença de um juiz competente, após a lavratura de sua prisão, é possível que, em alguns casos, após a audiência de custódia, sofra as consequências da necessidade cautelar de uma prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos dos artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Estando preso cautelarmente ou cumprindo pena, o preso tem o direito de pedir socorro ao juiz para que reavalie a sua situação e, muitas vezes, o faz, *escrevendo uma carta de próprio punho ao juiz* ou, até mesmo, se tiver conhecimento, impetrando um *habeas corpus* de próprio punho.

Após redigir o seu **pleito**, como está trancado em uma cela, esse preso depende da boa vontade de um agente público para que recolha seus pleitos e os direcione ao juiz competente.

Normalmente, esse trabalho é feito pelo advogado ou defensor público, mas, caso dependa do agente penitenciário, do diretor de disciplina ou do diretor do presídio, por exemplo, o atraso injustificado no envio ou o simples ato de impedir a comunicação do preso com o juiz competente caracterizará esse delito, desde que essa conduta seja praticada com uma das cinco finalidades específicas que devem reger a conduta criminosa do agente público, ou não existirá a figura típica em comento:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art .20

Art .20

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Verbo do tipo penal

Impedir – obstar, enterrar, embaraçar.

Objeto material do delito

A entrevista pessoal e reservada de preso com seu advogado.

Elemento normativo do tipo

Sem justa causa.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público que controla o acesso de pessoas ao preso. Ex. diretor de presídio, delegado de polícia, comandante da PM, juiz de direito etc.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que está presa e vê tolhido o seu direito de conversa reservada com advogado ou defensor público e, indiretamente, o Poder Público.,

Benefícios penais

A pena mínima de 6 meses admitiria a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. E a pena máxima de 2 anos levaria, se não tivesse sido vetado, o acusado ao procedimento comum do JECRIM – Lei 9.099/95.

Condutas equiparadas

Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, *por prazo razoável*, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.

Trata-se do mais puro exercício da ampla defesa, em suas vertentes autodefesa e defesa técnica.

É fundamental estar ao lado do cliente durante uma audiência para que ele informe ao advogado, em tempo real, se as declarações da vítima, das testemunhas ou perícias procedem.

Muitas vezes o réu mostra a incoerência ou mentira do depoimento e inverte a situação, saindo absolvido.

Violar o direito à ampla defesa recebeu em bom momento a tipificação criminal desse artigo.

Razões do veto

“O dispositivo proposto, ao criminalizar o impedimento da entrevista pessoal e reservada do preso ou réu com seu advogado, mas de outro lado autorizar que o impedimento se dê mediante justa causa, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, trata-se de direito já assegurado nas Leis n°s 7.210, de 1984 e 8.906, de 1994, sendo desnecessária a criminalização da conduta do agente público, como no âmbito do sistema Penitenciário Federal, destinado a isolar presos de elevada periculosidade.”

Críticas ao veto presidencial

Uma das piores justificativas para veto pode ser encontrada nesse artigo 20.

Em nenhum momento ignora-se a existência do direito de o advogado conversar reservadamente com o seu cliente preso.

Realmente há previsão normativa na Lei de Execução Penal e no Estatuto da OAB.

Porém, o que esqueceram de levar em consideração na razão do veto, é que é JUSTAMENTE o desrespeito a esse direito, atrelado com os dolos específicos do art. 1º da lei que surge o abuso de autoridade que precisa SIM ser punido com a prisão do agente.

Se existe lei federal permitindo a entrada do advogado em qualquer Cadeia, Penitenciária, Carceragem, Cadeia Pública ou Hospital de Custódia, o ato do agente que obsta esse direito por mero capricho, por satisfação pessoal, para benefício próprio ou de terceiro ou, ainda, para prejudicar outrem, está abusando de sua autoridade. Agiu mal a equipe governamental ao vetar esse dispositivo.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 21

Art. 21

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

COMENTÁRIOS AO *CAPUT*

Manter – segurar, conservar

Objeto material do delito

Mistura de gêneros na mesma cela ou no mesmo espaço de confinamento.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por quem coloca, fisicamente, na mesma cela ou espaço de confinamento, homem e mulher.

Dupla subjetividade passiva

São as pessoas submetidas a essa situação vedada por lei e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais:

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 4 anos, caso o agente não possua prerrogativa de foro, seguirá o rito comum ordinário.

COMENTÁRIOS AO PARÁGRAFO ÚNICO

Conduta equiparada

Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nessa figura típica tutela-se o direito de crianças ou adolescentes ficarem separados dos adultos.

Há muitas impropriedades técnicas nesse dispositivo legal.

Em primeiro lugar, crianças, pessoas com até 12 anos de idade incompletos, não praticam sequer ato infracional e jamais poderiam receber medida socioeducativa de internação ou serem apreendidas cautelarmente.

O ato de privar criança de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente caracteriza o crime do art. 230 do ECA.

Há outros crimes no Estatuto, muito parecidos com os desta nova Lei de Abuso de Autoridade que tutelam as mesmas condutas aqui descritas, relacionadas com a liberdade das pessoas, porém praticados contra criança ou adolescente.

São eles:

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.

Ambiente inadequado

Para entender o significado da expressão – ambiente inadequado – será necessário buscar no ECA o que é ambiente adequado para fazer uma análise inversa.

Reza o art. 94 do Estatuto da Criança e Adolescente:

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:

(...)

IV – preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;

Ou seja, o ambiente adequado por lei é aquele que respeita a dignidade do adolescente.

Conhecendo o sistema carcerário, faltaria dignidade ao adolescente e criança presos:

- se não houvesse banheiro;
- se a comida tivesse péssima qualidade;
- se não existisse cama para repouso;
- se a criança ou adolescente fosse exposto a frio ou calor intenso;
- se a mistura com adultos gerasse nos infantes violência física, sexual, moral ou psicológica;
- se fossem torturados por qualquer motivação;
- etc.

Tais ambientes seriam inadequados, viabilizando a adequação típica entre o fato e a norma.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 22

Art. 22

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:

I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;

II - (VETADO);

III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).

§ 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

=> Inciso II vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS

Invadir – penetrar, introduzir-se

Adentrar – embrenhar

Permanecer – demorar-se, subsistir, perdurar

Objeto material do delito

Imóvel alheio.

Elemento normativo do tipo

Fora das hipóteses previstas em lei.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser agente público que desrespeita as regras de ingresso em domicílio alheio.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que tem o seu imóvel violado e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever como elemento do tipo a ‘forma ostensiva e desproporcional’, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Além disso, em operações policiais, o planejamento da logística de bens e pessoas competem às autoridades da segurança pública.”

Críticas ao veto presidencial do art. 22, § 1º, II

Entre todas as figuras típicas do art. 22, optou-se por um único veto:

II – executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional, ou de qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial, para expor o investigado a situação de vexame;

Entendemos a ideia do legislador, porém, na prática, o tipo penal ficou muito aberto, sem limitação do que seria executar mandado de busca e apreensão em imóvel alheio de maneira desproporcional e ostensiva.

Falta taxatividade para o tipo, sendo inconstitucional. Agiu bem a equipe presidencial ao vetar esse dispositivo.

Trata-se do segundo crime vetado que tutelava a exposição de pessoas a vexame em diligências policiais.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 23

Art. 23

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:

I - eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência;

II - omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

COMENTÁRIOS

Fraude processual com abuso de autoridade

O tipo objetivo determina que devem estar presentes:

1. Inovar (verbo nuclear do tipo penal): significa mudar, substituir, alterar
2. Artificiosamente: quer dizer de forma ardil, fraudulenta.

Elemento subjetivo do tipo

Exige-se o dolo específico envolvendo o acordo de vontade, uma vontade relacionada a responsabilidade – eximir-se, agravar a responsabilidade de terceiro ou de responsabilizar, além de um dos 5 dolos específicos do parágrafo único do art. 1º desta lei:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Momento consumativo

Consuma-se o crime com a alteração, a inovação artificiosa, não sendo necessário para a integração da fraude processual que o juiz ou perito sejam levados a erro ou que o processo não tenha chegado a fase de julgamento. Basta a fraude, idônea, que provoque o erro, o engano.

Ocorre que a inovação de estado de lugar, de coisa ou de pessoa deve ocorrer na constância de processo civil ou administrativo em andamento, com a ressalva trazida pelo parágrafo único do tipo, o qual prevê a majoração da pena ao dobro se praticada no âmbito de processo penal.

Conduta típica

Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade.

Mas, como se daria essa responsabilização ou conseguir se eximir? Com a inovação artificiosa, levar a erro alguém responsável pela investigação.

Dessa forma, é cristalino que o art. 23 da Lei de Abuso de Autoridade é muito parecido com o art. 347 do CP, só que algumas diferenças.

Art. 347 – Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único – Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Nota-se que esse delito está previsto no artigo 347 do Código Penal, que é uma lei geral.

No entanto, deve-se atentar para os dispositivos que existirem nesse sentido em lei especial, como é o caso do artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 4 anos sujeitará o agente público ao rito comum ordinário, salvo se possuir prerrogativa de foro.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 24

Art. 24

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

COMENTÁRIOS

Constranger – forçar, obrigar, impor, coagir, impelir.

Mediante violência ou grave ameaça

O constrangimento com violência ou grave ameaça é elementar do tipo penal.

A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima.

A violência é a agressão física causada na vítima.

São elementares do tipo penal em comento.

Sem violência ou grave ameaça, não estará caracterizado o delito de abuso de autoridade. Sequer poderá o agente responder pelo crime residual de constrangimento ilegal do Código Penal (art. 146) pois lá também são elementares típicas a violência e a grave ameaça.

Questiona-se se poderia haver a tipificação desse delito, na ausência de violência ou grave ameaça, no crime de fraude processual, do art. 347 do Código Penal:

Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único – Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

A fraude processual estaria tipificada se, em concurso de agentes, caso seja forjada a morte dentro de hospital, sabendo que a vítima já chegara em óbito, entre a pessoa que levou a vítima até lá e o funcionário do hospital que concordou em informar que a morte ocorrera dentro do leito hospitalar.

Ou, ainda, se o próprio funcionário do hospital levar a vítima já em óbito até o hospital para atestar que a morte ocorrera internamente, afastando a persecução penal da real causa e circunstâncias da morte.

Dupla subjetividade passiva

Sujeito passivo indireto: é o Poder Público.

Sujeito passivo direto próprio: é o funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada.

Objeto material

A pessoa que já está em óbito, cujo local ou circunstâncias da morte se pretende fraudar.

Finalidade especial da norma

Com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração dos fatos da exata forma em que se deram, acrescido de um dos 5 dolos específicos do parágrafo único do art. 1º:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Em relação aos dolos específicos gerais de todos os delitos de abuso de autoridade, eles se evidenciam, pois não há possibilidade de tal constrangimento sem algum tipo de interesse próprio do agente público ou de terceiro, valendo-se, para isso, de sua posição de agente público.

Erro de tipo – Art. 20 do Código Penal

Se o agente público achava que a vítima estava morta e, por essa razão, constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, funcionário de hospital para admitir para tratamento pessoa cujo óbito já teria, em tese, ocorrido, erra sobre as circunstâncias de fato que são elementares típica – pessoa já em óbito.

Isso impede a consumação do delito, pois, mesmo presente a violência ou grave ameaça e a má-fé, faltaria a elementar típica pessoa já morta, e o fato será atípico em relação ao presente delito, podendo responder pelo constrangimento ilegal do Código Penal.

Quando invencível, ou seja, qualquer agente público poderia cometer, exclui-se o dolo e a culpa, resultando na atipicidade de uma conduta sem relevância penal.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 25

Art. 25

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

COMENTÁRIOS

Proceder – continuar, avançar

Objeto material do delito

É a obtenção de prova.

Meios de prova são instrumentos ou atividades pelos quais os elementos de prova são introduzidos no processo. Ex. testemunha, documento, perícia.

Investigação ou fiscalização – admite tanto esfera criminal como administrativa

Meio manifestamente ilícito – art. 5º, LVI, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.

Antes, era inadmissível a obtenção de provas por meio ilícitos, mas isso tinha um reflexo meramente processual, com o advento na nova lei de abuso de autoridade, havendo um dos dolos do artigo 1º, a conduta passa a ser crime!

Obs.: Considera-se inadmissível não apenas a prova obtida por meio ilícito, mas também, por derivação, as provas decorrentes do meio de prova obtido ilicitamente

Parágrafo Único – Utilizar prova que já se sabia ser ilícita

b) prova ilícita: obtida com violação a regras de direito material ou normas constitucionais. Notadamente, as garantias da pessoa, elencadas na Constituição da República, se violadas, gerarão prova ilícita, conforme preceitua o art. 5º, LVI, da própria Constituição. Exemplos: provas obtidas com violação do domicílio, mediante tortura, por meio de interceptação ilegal de comunicação.

* Boa parte da doutrina admite a prova ilícita se for o único meio de provar a inocência do

acusado no processo, pois se estaria privilegiando bem maior do que o protegido pela norma, qual seja, a liberdade de um inocente.

O parágrafo único repete o disposto no art. 1º, uma vez que ele dispõe que incorre na mesma pena quem faz uso de prova “em desfavor do investigado ou fiscalizado” com prévio conhecimento.

Criminaliza-se a intenção.

Para cometer tal crime de abuso de autoridade, necessita-se ter conhecimento prévio.

Não será crime formal, em que apenas a utilização da prova geraria a consumação do crime, mas para que se possa consumá-lo, o agente precisa ter conhecimento prévio e tal prova ser prejudicial.

Não basta a utilização da prova ilícita, o agente publica precisa ter conhecimento prévio que ela era ilícita.

Por exemplo: o agente público tortura o investigado para obter a prova (meio manifestamente ilícito de obtenção de prova) e ainda assim utiliza essa prova, ele já tinha conhecimento prévio que a prova era ilícita, seja porque ele mesmo torturou ou em outra hipótese presenciou. Obviamente, nesse exemplo, as condutas praticadas não seriam apenas de abuso de autoridade, mas também a de tortura. Mas o que se quer demonstrar com esse exemplo é que o agente público já tinha o conhecimento prévio da ilicitude da prova.

Ou outro exemplo um pouco menos exagerado, seria a utilização da prova, de um celular apreendido durante uma investigação. Sem autorização judicial, o agente público extrai todas as trocas de mensagens de WhatsApp ou qualquer outro aplicativo e utiliza para realizar uma prisão ou para justificar determinadas ações em uma investigação.

Sem a autorização judicial ele não poderia utilizar, mexer nas mensagens, mas ainda assim ele o faz, com o interesse de prejudicar aquele investigado. Praticando nesse exemplo os verbos do tipo em meio manifestamente ilícito e tendo prévio conhecimento. Caracterizado sem sombra de dúvida o abuso de autoridade do parágrafo único do artigo 25.

O tipo penal só menciona se for para prejudicar, em desfavor, pois se a prova ainda que ilícita, puder ser utilizada para absolver o réu, será admitida.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa cuja prova foi obtida ilicitamente e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 26

Art. 26

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 26. (VETADO).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Induzir – provocar, impulsionar, incitar

Instigar – incentivar, aguçar, fomentar

Objeto material do delito

A prisão em flagrante preparado.

Elemento normativo do tipo

Fora das hipóteses previstas em lei.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público que induz ou instiga pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que é presa em flagrante após ter sido induzida ou instigada a praticar infração penal e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admitiria, se não tivesse sido vetado o delito, a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica por indeterminação do tipo penal, e por ofensa ao princípio da intervenção mínima, para o qual o Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, tendo em vista que a criminalização da conduta pode afetar

negatividade a atividade investigativa, ante a potencial incerteza de caracterização da conduta prevista no art. 26, pois não raras são as vezes que a constatação da espécie de flagrante, dada a natureza e circunstâncias do ilícito praticado, só é possível quando da análise do caso propriamente dito, conforme se pode inferir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (v.g. HC 105.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T. j. 24/05/2011).”

Críticas ao veto presidencial

O crime foi vetado, basicamente, por duas razões:

- * não se deve utilizar o Direito Penal para punir essa conduta pela intervenção mínima;
- * a constatação da espécie de flagrante, dada a natureza e circunstâncias do ilícito praticado, só é possível quando da análise do caso propriamente dito, o que geraria, no momento da lavratura, insegurança jurídica.

Discordamos do veto presidencial.

O crime está muito bem desenhado na lei e não gera insegurança jurídica.

Percebam que o flagrante preparado, considerado ilícito pelo Supremo Tribunal Federal, em seu enunciado 145, demanda, para a sua configuração, um comportamento ativo do agente policial, *induzindo* (dando uma ideia até então não existente) e *instigando* (reforçando uma ideia criminosa já existente) o agente a praticar uma infração penal.

E não é só. Importante ressaltar que, além do induzimento ou instigação, seria necessário, para a configuração típica subjetiva, um dos 5 dolos específicos do art. 1º desta lei:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Dessa forma, concluímos que a criminalização do flagrante preparado deveria ter sido mantida, diante da permissibilidade legal de todas as demais formas de prisão em flagrante lícitas, tais como o próprio, impróprio, presumido, esperado e retardado (prorrogado, diferido ou ação controlada).

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 27

Art. 27

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

COMENTÁRIOS

Verbo do tipo penal

Requisitar – *demandar, requerer, solicitar, postular.*

Objeto material do delito

Procedimento investigatório de infração penal ou administrativa.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público competente para requisitar procedimento ou instaurá-lo.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que vê contra si instaurado procedimento de investigação e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 6 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 2 anos sujeitará o agente ao rito comum sumaríssimo, caso não seja detentor de foro de prerrogativa de função.

Procedimentos

Como procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, podemos identificar:

Procedimento investigatório infração penal – Inquérito policial, Procedimento de Identificação Criminal, Comissão Parlamentar de Inquérito etc.

Procedimento administrativo – Procedimento administrativo disciplinar, sindicância etc.

Falta de justa causa

O legislador tipificou, como elementar, a injustiça de iniciar a persecução penal mesmo diante da inexistência de qualquer indício.

Como indício, devemos entender por uma prova indireta que, por indução, leva à uma conclusão a respeito da materialidade e da autoria de um ilícito penal.

Inexistência de crime

Para não inviabilizar o trabalho investigativo, agiu corretamente o legislador ao não criminalizar o trabalho procedimental de investigação preliminar sumária ou de mera sindicância administrativa.

Os agentes estatais de investigação poderão continuar apurando a existência de infrações utilizando o procedimento de investigação preliminar sumária ou a mera sindicância administrativa.

Trata da ausência de ilicitude, pois a própria lei permite, expressamente, a instauração de procedimentos em fase embrionária.

Confusão entre autoria e materialidade

Nenhuma investigação se inicia sem um lastro fático, sem um norte.

O artigo visa garantir o que já é previsto na Constituição da República. Ninguém pode ser incomodado pelo Estado, vendo contra si a instauração de um inquérito policial sem ter feito absolutamente nada. A situação de abuso de autoridade é cristalina.

Ou o cidadão é suspeito, diante das situações fáticas concretas que pesam contra ele, ou o cidadão é inocente até que se prove que ele seja culpado ou ainda que exista alguma justificativa para que ele seja investigado. Esse crime representa inversão do princípio da presunção de inocência.

Dolo direito mais elemento subjetivo especial

Para que se configure o crime de abuso de autoridade, além de não ter indício para a instauração precisa ter um dos 5 dolos do artigo 1º. Portanto, ainda que haja algum tipo de confusão em relação ao alcance do que seria um indício, ainda seria necessário restar comprovado o dolo específico do agente público.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 28

Art. 28

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

COMENTÁRIOS

Divulgar – tornar conhecido, difundir, espalhar

Expor – revelar, evidenciar, mostrar

Objeto material do delito

A gravação ou trecho de gravação.

Crime de dano

Expondo concretamente a intimidade ou a vida privada de pessoa determinada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Exige-se a efetiva exposição da intimidade ou da vida privada da pessoa ou, ainda, o atingimento da honra ou imagem do investigado ou acusado. Caberá ao titular da ação penal essa análise quantitativa para decidir se oferece a denúncia ou requer o arquivamento, diante das peças de informação.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que tem a sua intimidade, vida privada, honra ou imagem atingida e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 4 anos leva o processo para o rito comum ordinário, salvo se o agente detiver foro de prerrogativa.

Observações complementares

Sem relação com a prova

O tipo penal limita a tipicidade formal para a gravação que não tem relação com a prova que se pretenda produzir. Fazendo raciocínio inverso, pergunta-se:

Se tiver relação com a prova pode divulgar? Mesmo que exponha a intimidade ou a vida privada ou macule a honra ou a imagem do investigado ou acusado?

Entendemos que não!

Esse novo tipo penal deve ser aplicado de maneira sistemática com a Constituição da República e com a Lei 9.296/96.

O art. 5º, XII, da CRFB apresenta direito fundamental a inviolabilidade das comunicações telefônicas:

é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

O art. 9º da Lei das Interceptações das comunicações assim nos apresenta a mesma situação:

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Há um incidente de inutilização das gravações que não interessarem aos autos. Justamente para impedir que a vida privada, honra, imagem ou intimidade das pessoas não seja exposta de maneira desnecessária. E isso vale para qualquer pessoa que tenha tido as suas conversas gravadas.

Seja a divulgação da gravação ou trecho de gravação com relação ou sem relação com a prova, no caso de expor intimidade, jamais deve ser possível, pois não pode uma lei relativizar um direito fundamental sem justificativa constitucional.

Qual é a diferença, para o processo, da conversa vir a público ou não?

Trabalhamos com magistrados imparciais que só podem julgar com base na evidência dos autos, valorando-as livremente, mas ainda amarrados com as provas.

Justamente, por essa razão, as provas ilícitas deverão ser desentranhadas dos autos, nos termos do CPP:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Se uma prova, por mais robusta que o seja, como uma gravação comprometedora, não poderá ser aproveitada pelo magistrado competente se foi obtida ilicitamente, muito mais grave é a situação da prova obtida de maneira criminoso.

Fez bem o legislador em complementar a tutela penal da intimidade e vida privada das pessoas contra gravações clandestinas, realizadas sem ordem judicial:

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

Se tínhamos o crime do artigo 10 contra o vazamento de informações que quebravam o sigilo das pessoas sem ordem judicial ou com objetivos não autorizados em lei, temos agora, de maneira bem explícita, conduta análoga para a divulgação das gravações que ferem de morte os direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem de quem figurou na gravação e não tem relação com a prova dos autos.

Entendemos que o legislador ficou aquém do que deveria, pois ainda temos lacuna sobre o tema.

A Lei 9.296/96, complementada agora pela nova Lei de Abuso de Autoridade – Lei 13.869/2019, fortaleceram a ideia de sigilo das gravações feitas com ordem judicial.

O segredo de justiça de processos que contenham conversas telefônicas está expresso no art. 1º da Lei 9.296/96:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

O recado da Lei das interceptações é muito claro: será possível a interceptação desde que respeitados todos os requisitos legais, incluindo o sigilo.

Inclusive as provas produzidas, após a sua utilização, deverão ser descartadas.

Sensacionalismo e autopromoção

Se há a divulgação de gravações que não possuem relação com a prova, isso pode recair no dolo de beneficiar-se por conta de autopromoção.

Ainda por si só, divulgar algo que não tem nada a ver com a prova e que deveria ser destruído, conforme previsão legal, seria se valer do sensacionalismo midiático.

Não é de hoje nem novidade que existe o sensacionalismo atrelado às notícias policiais e criminosas. São inúmeros os casos em que a mídia, antes de mesmo de um julgamento formal, já condena informalmente as pessoas, destruindo a reputação de quem foi exposto.

Óbvio que a mídia tem seu direito de veicular conteúdos, mas não estamos falando de censura, pois o próprio tipo penal fala em intimidade, situação vexatória etc.

Dessa forma, a divulgação de algo que expõe o indiciado ou acusado sem relação com a prova é um absurdo e, por essa razão, agiu bem o legislador de tipificá-la e a equipe presidencial de não a vetar.

O tipo penal visa reforçar o que a CF protege (intimidade, vida privada, honra e imagem) e não deixar à margem de interpretação situação que geraria apenas sensacionalismo, ferindo vários princípios, até mesmo o da imparcialidade, caso fosse um júri popular, por exemplo.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art .29

Art .29

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. (VETADO).

=> Parágrafo único vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o parágrafo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS

Prestar – conceder, ofertar, propiciar.

Objeto material do delito

Informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo.

A informação pode falsear a respeito de autoria ou de materialidade, indistintamente.

Não se pode confundir com o crime de falso testemunho:

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei n. 10.268, de 28.8.2001)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 12.850, de 2013) (Vigência)

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

No crime de falso testemunho, é necessário que o agente público tenha sido arrolado pela acusação ou pela defesa, esteja diante de uma autoridade pública, preste compromisso e, dolosamente, preste informação falsa.

Já no crime do art. 29 da Lei de Abuso de Autoridade, também temos o ato de prestar informação falsa, porém, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Trata-se do dolo de

prejudicar, e no art. 342 do CP teremos o dolo de mentir ou omitir informação necessária aos autos, podendo ou não ser praticado por agente público.

Elemento subjetivo do injusto ou dolo específico

Com o fim de prejudicar interesse de investigado.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público que presta informação falsa.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que sofre os impactos da informação falsa e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto ao parágrafo único do art. 29

“A propositura legislativa, ao prever como elemento do tipo ‘informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso’, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Além disso, pode vir a conflitar com a Lei n. 12.527, de 2011, (Lei de Acesso à Informação), tendo em vista que pode conduzir ao entendimento pela possibilidade de divulgação de informações de caráter pessoal, as quais nem sempre são sigilosas, mas são protegidas por aquele normativo.”

Críticas ao veto presidencial

A parte do tipo penal que foi vetada tratava de conduta omissiva.

A lei trouxe como crime por conduta equiparada ao *caput* o ato de quem, com igual finalidade, ou seja, prejudicar interesse de investigado, omitir dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso.

Realmente é um tipo penal aberto que fere a taxatividade, pois pode abranger qualquer dado ou informação, sendo demasiadamente amplo e contrariando o princípio da legalidade administrativa, gerando insegurança jurídica nos agentes públicos.

Como segundo argumento de veto, utilizou-se a Lei de Acesso à Informação, que obriga a publicidade de todas as informações relacionadas a agentes públicos, podendo gerar um conflito na parte que a lei veda a publicidade de informações pessoais, para não colocar em risco os agentes públicos.

Os conceitos da Lei de Acesso à Informação são bem explicados:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

Não concordamos com essa provável confusão utilizada pela razão de veto, pois o tipo penal, nesse ponto, é muito claro:

- fato juridicamente relevante;
- fato não sigiloso.

Se o Direito Penal busca fatos, e não pessoas, o crime vetado tem relação com fatos e é sobre esses fatos que recairia o tipo penal vetado nessa parte.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 30

Art. 30

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o parágrafo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS

Dar – originar, enunciar, entregar.

Objeto material do delito

A persecução penal, civil ou administrativa.

Elemento normativo do tipo

Sem justa causa.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público responsável pelo início da persecução penal, civil ou administrativa.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que é inocente e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto

“A propositura legislativa viola o interesse público, além de gera insegurança jurídica, tendo em vista que põe em risco o instituto da delação anônima (a exemplo do disque-denúncia), em contraposição ao entendimento consolidado no âmbito da Administração Pública e do Poder Judiciário, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal (v.g. INQ. 1.957-7/PR, Dj. 11/11/2005), de que é possível a apuração de denúncia anônima, por intermédio de apuração preliminar, inquérito policial e demais medidas sumárias de verificação do ilícito, e se esta revelar indícios da ocorrência do noticiado na denúncia, promover a formal instauração da ação penal.”

Críticas ao veto presidencial

Não faz sentido esse veto.

Justa causa é a existência de materialidade e autoria comprovadas e inocência é o estado de toda pessoa em relação ao fato criminoso antes de sua condenação definitiva.

Alega-se que a vigência desse tipo penal inviabilizaria as denúncias anônimas, porém esqueceu a equipe presidencial dos 5 dolos específicos do art. 1º:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Sem pelo menos um deles, não existiria o crime e, diante de uma denúncia anônima, surge o interesse público de apurar a existência de infração penal para responsabilizar o agente delitivo e essa intenção está diametralmente oposta aos dolos específicos da Lei de Abuso de Autoridade.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 31

Art. 31

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

COMENTÁRIOS

Estender – prolongar, dilatar

Procrastinar –Adiar, atrasar, demorar.

O verbo do tipo será praticado em prejuízo do investigado ou fiscalizado.

Objeto material do delito

A investigação.

Elemento normativo do tipo

Injustificadamente.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por quem detenha competência para prolongar, estender ou procrastinar investigação.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa investigada e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 6 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 2 anos coloca o tipo penal sob o rito comum sumaríssimo, com todos os seus regramentos despenalizadores, salvo para os agentes

públicos que detenham prerrogativa de foro.

Observações complementares

O art. 31 busca punir o agente público que estender o prazo das investigações, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, sem nenhuma justificativa plausível.

O tipo penal apresenta alguns problemas técnicos para que possa ser corretamente compreendido.

Expressões como – *injustificadamente* ou justificativa *plausível* causam, em primeiro plano, certo temor por parte dos agentes públicos que presidem investigações, tais como delegados de polícia, representantes dos Ministérios Públicos, relatores de Comissão Parlamentar de Inquérito etc.

Porém, ao fazer uma análise mais profunda do tipo, pode-se perceber que a configuração típica é por demasiado complexa para que alguém seja efetivamente punido.

Primeiro porque investigações já possuem prazo determinado em diferentes legislações.

Em segundo lugar, a jurisprudência admite, de maneira pacífica, o pedido de renovação de prazo para investigar a materialidade e a autoria, quantas vezes forem necessárias, com o aval do MP e do magistrado competente.

Como terceira observação, a demora na conclusão da investigação, pois ainda há a busca pelo responsável por crimes não pode se confundir com os dolos específicos do art. 1º desta Lei, quais sejam:

- prejudicar outrem;
- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Sem essas finalidades alternativas específicas, não teremos conduta penalmente relevante apta a caracterizar um fato típico, elemento obrigatório da configuração de crime.

Só abusará de sua autoridade o agente que não estiver agindo em busca do interesse público.

Só abusará da sua autoridade o agente que agir à margem da lei, com finalidade de prejudicar investigado ou fiscalizado com um dos 5 dolos específicos. For a dessa hipótese, é premente a atipicidade da conduta por ausência de adequação típica ou de dolo direito e específico.

Nem mesmo teremos a conduta equiparada para as hipóteses em que a lei foi omissa no tocante à duração máxima da investigação, pois mesmo nesses casos o prejuízo concreto do investigado ou fiscalizado será elementar típica a ser comprovada antes mesmo da denúncia, em conjunto com os elementos subjetivos do tipo (dolos específicos).

Podemos exemplificar uma hipótese em que o prazo da investigação foi renovado por tantas vezes que a punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. E, nessa hipótese, questiona-se: qual foi o prejuízo para o investigado?

Nenhum.

Não há crime sem prejuízo.

Pas de crime sans grief.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 32

Art. 32

[...]

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO TIPO PENAL

Negar – impedir, proibir

Objeto material do delito

O acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa.

Elemento normativo do tipo

Fora das hipóteses legais.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público com poderes para negar o acesso ao interessado, seu defensor ou advogado.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que tem o direito de acesso aos autos negado e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais

requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois o direito de acesso aos autos possui várias nuances e pode ser mitigado, notadamente, em face de atos que, por sua natureza, impõem o sigilo para garantir a eficácia da instrução criminal. Ademais, a matéria já se encontrar parametrizada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n. 14.”

Críticas ao veto presidencial

Agiu mal a equipe do Governo ao vetar esse dispositivo.

O próprio tipo penal já traz a ressalva: *ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível*.

Dessa forma, o crime seria muito útil para evitar o desrespeito de algumas autoridades em negar vista, para o interessado, seu defensor ou seu advogado, de autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa.

A lei não obriga os agentes públicos a juntar aos autos de investigações as diligências em andamento. Sabemos que são juntadas posteriormente justamente para não interferirem nas diligências em andamento. Essa ressalva foi respeitada pelo tipo penal.

Outro argumento ilegal para o veto foi o discurso do sigilo das investigações. É fato notório que o sigilo das investigações **não abrange** a defesa do investigado. Nem poderia. O absurdo kafkaniano de esconder os motivos pelos quais você está sendo investigado beira o absurdo. As pessoas só percebem essa barbárie, resquício da Idade Medieval, quando figuram como investigadas e a elas são negado acesso para se inteirar dos motivos.

Por fim, argumentar que não precisamos de lei quando já existem súmulas atinge de morte noções básicas de Direito.

Súmulas vinculantes vinculam os Poderes Judiciário e Executivo, mas não o Legislativo. Isso causa insegurança jurídica, pois a qualquer momento pode surgir uma lei em sentido contrário e não se poderá argumentar que já tínhamos leis nos protegendo, pois é uma mera súmula, decorrente de Tribunal, cujos membros não foram eleitos pelo povo e nem os representam.

O entendimento jurisprudencial serve como guia de aplicação aos casos concretos que chegam diuturnamente às portas do Judiciário. Diante da anomia do tema, foi necessário regulamentar o acesso dos advogados aos autos de inquérito, para viabilizar, em sua plenitude constitucional, o exercício da ampla defesa, na vertente defesa técnica.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 33

Art. 33

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresse amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

COMENTÁRIOS

Verbo do tipo penal

Exigir – ordenar, impor

Tipo penal aberto

Artigo extremamente aberto e genérico de difícil transporte para casos práticos pela precariedade da taxatividade. Pois não é possível vislumbrar, com a precisão necessária, o início e o fim do tipo penal.

Fala-se em *exigir* informação ou cumprimento de obrigação, mas que informação ou qual obrigação? Determinada por quem, quando em que prazo, qual a finalidade?

Ainda, visa criminalizar a conduta de exigir o dever de fazer ou não fazer, também recai no que foi dito acima.

O que fazer ou não?

É amplo e completamente vago, impossibilitando uma delimitação prática.

Mais curioso é criminalizar a conduta de exigir *informação, obrigação, dever de fazer* ou *não fazer*, sem que haja um norte e ainda mencionar que seria sem o expresse amparo legal.

O tipo penal é aberto que fere o princípio da taxatividade penal, ofendendo o princípio da legalidade expresse no art. 5º, XXXIX, da CF/88.

Insegurança jurídica na atuação

Gera insegurança jurídica na atuação dos agentes públicos que só podem fazer o que a lei determina e, diante de leis como essa, surge a dúvida sobre o seu alcance ou real interpretação.

Ainda, o artigo enfraquece a nova Lei de Abuso de Autoridade, uma vez que se mostra amplo, vago, dispensável, mostrando que a lei não teve uma efetiva preocupação com sua aplicação concreta, deixando à discricionariedade dos agentes da persecução penal tentar descobrir na prática o que esse crime significa.

É deixar à míngua os agentes públicos dispostos nessa lei, pois essa expressão *exigir informação* pode ser tudo e ao mesmo tempo pode ser nada.

Como delimitar que uma solicitação, por exemplo, de um agente público a uma pessoa e ter certeza de que foi apenas uma solicitação, e não uma exigência? Esses parâmetros são imprescindíveis a esse tipo penal. Faltou o legislador explicar o que ele gostaria de atingir, e essa responsabilidade passou, para os sujeitos da persecução penal à Academia.

Abuso de autoridade para se eximir de obrigação legal

Pratica a conduta equiparada do parágrafo único o agente que busca se furtar, se escusar, se eximir de obrigação legal e, para isso, utiliza sua qualidade pessoal de agente público.

Ou, ainda, para obter vantagem ou privilégio indevido valendo-se de sua condição de agente público.

Em ambos os casos, será necessário ao titular da ação penal a comprovação de um dos 5 dolos específicos do art. 1º da lei, sem os quais não existirá fato típico por ausência de conduta penalmente relevante.

Concurso de crimes

Devemos ter cuidado com os verbos exigir e solicitar, nos casos concretos envolvendo esse tipo penal.

Temos, no Código Penal, o delito de concussão, que trata justamente de um ato coercitivo do agente público para obtenção de vantagem indevida.

Concussão.

Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

O crime de concussão tem como pontos de intersecção ser praticado por um agente público (crime funcional) e a conduta coercitiva – exigir. Mas para por aí. A grande diferença entre os dois crimes reside na intenção do agente.

Na concussão, a intenção é patrimonial, enquanto no tipo penal da Lei de Abuso de Autoridade a intenção é prejudicar outrem; beneficiar a si mesmo; beneficiar terceiro; por mero capricho; ou por satisfação pessoal.

Já em relação a uma conduta menos agressiva, mas não menos criminosa, podemos exemplificar com um mero *solicitar* para contextualizar o parágrafo único do presente tipo penal.

A Lei de Abuso de Autoridade diz:

Art. 33. (...) Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

Imaginemos que um agente público, para obter privilégio indevido, utiliza de seu cargo e

solicita vantagem. Estaríamos diante do crime de abuso de autoridade ou do crime de corrupção passiva?

Reza o tipo do Código Penal:

Corrupção passiva.

Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

O ato de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida configura o tipo penal de corrupção passiva, quando praticado por agente público. Trata-se de crime funcional que tem por objetivo a obtenção de vantagem indevida. Em nenhum momento seria possível afirmar que o dolo do crime de corrupção passiva será o mero abuso de autoridade. Não. A finalidade do agente é a obtenção da vantagem indevida, cuja consumação sujeita o agente público a reprimenda penal altíssima de até 12 anos de reclusão.

Já o crime de abuso de autoridade do art. 33, parágrafo único, tem reprimenda leve, punida com detenção e pena máxima de 2 anos, sujeitando o agente sem prerrogativa de foro ao rito comum sumaríssimo do Juizado Especial Criminal.

Parece-nos que são condutas próximas demais para receber tratamento de preceitos secundários tão díspares, ferindo a proporcionalidade da lei penal, no quesito repressão.

Certamente, os agentes processados criminalmente no Brasil por corrupção passiva não economizarão esforços jurídicos para buscar uma desclassificação do crime do art. 317 do Código Penal para o novo delito do art. 33 da Lei de Abuso de Autoridade, cuja punição chega a ser pífia em matéria criminal, saindo de um tipo penal que dificilmente garante ao agente algum benefício e ingressando no vasto campo dos benefícios penais da Lei 9.099/95.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por agente público.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que sofre a exigência ilegal e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 6 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 2 anos levará o agente público para o rito comum sumaríssimo, como todos os institutos despenalizadores, tais como a inexistência de inquérito policial (termo circunstanciado) e a transação penal.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 34

Art. 34

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 34. (VETADO).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Deixar de corrigir – crime omissivo próprio.

O verbo do tipo será praticado com a finalidade de manter erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento, quando era cabível corrigi-lo de ofício.

Objeto material do delito

Erro relevante que sabe existir.

Tema extremante difícil tinha sido relegado para o intérprete decidir o que seria um erro relevante para configurar a adequação típica.

Como proposta doutrinária, sugerimos a seguinte especificação:

a) atos **inexistentes** – erro relevante para fins de tipicidade desse crime;

b) atos **absolutamente nulos** – erro relevante para fins de tipicidade desse crime;

c) atos **relativamente nulos** – erro sem relevância para fins de tipicidade desse crime, pois, se a não alegação em primeira oportunidade tem força para convalidar o ato nulo, não haveria sentido manter a tipicidade formal e material do delito;

d) atos **meramente irregulares** – erro irrelevante para fins de tipicidade desse crime;

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado pelo agente público com competência para sanar vícios processuais ou procedimentais.

Dupla subjetividade passiva

É o particular que sofre as consequências procedimentais ou processuais decorrentes de erro

relevante e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 3 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 6 meses levará o agente público para o rito comum sumaríssimo, como todos os institutos despenalizadores.

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao dispor que ‘erro relevante’ constitui requisito como condição da própria tipicidade, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, o dispositivo proposto contraria o interesse público ao disciplinar hipótese análoga ao crime de prevaricação, já previsto no art. 34 do Código Penal, ao qual é cominado pena de três meses a um ano, e multa, em ofensa ao inciso III do art. 7º da Lei Complementar n. 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, em razão do inadequado tratamento do mesmo assunto em mais de um diploma legislativo.”

Críticas ao veto presidencial

Agiu corretamente a equipe governamental ao vetar esse dispositivo.

Esse bem jurídico já está parcialmente tutelado pelo art. 319 do Código Penal e punido com mais severidade.

Prevaricação

Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 35

Art. 35

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 35. (VETADO).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Coibir – limitar, restringir, moderar.

Dificultar – atrapalhar, intricar, atravancar.

Impedir – obstar, enterrar, embaraçar.

Os verbos do tipo penal estão direcionados para atingir diretamente o direito constitucional de reunião, associação ou agrupamento de pessoas com finalidade pacífica. Trata-se do chamado direito de reunião.

Objeto material do delito

A reunião, a associação ou o agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo.

Elemento normativo do tipo

Sem justa causa. Se houver justa causa, os agentes públicos agirão em estrito cumprimento e dever legal.

Sujeito ativo

Deverá ser praticado por agente público, conceito do art. 2º.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que é impedida de exercer o seu direito de reunião e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 3 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. A pena máxima de 1 ano levará o processo para o rito comum

sumaríssimo, caso o agente público não tenha foro de prerrogativa de função.

Razões do veto

A propositura legislativa gera insegurança jurídica, tendo em vista a generalidade do dispositivo, que já encontra proteção no art. 5º, XVI, da Constituição da República, e que não se traduz em uma salvaguarda ilimitada do seu exercício, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o direito à liberdade de se reunir não se confunde com incitação à prática de delito nem se identifica com apologia de fato criminoso.

Comentários às razões de veto

O tema já possui regramento constitucional – direito de reunião – e a jurisprudência delimitou que o direito de reunião não pode ser exercido para incitar a prática de crimes ou para fazer a apologia a criminosos por fatos praticados.

Reza o Código Penal:

Incitação ao crime

Art. 286 – Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Apologia de crime ou criminoso

Art. 287 – Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:

Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Fora dessas hipóteses, devemos tratar o direito de reunião como um direito individual, constitucional, lícito e permitido, nos termos do art. 5º, XVI, da CRFB/88:

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

O que a equipe governamental que optou pelo veto não entendeu foi o alcance do novo tipo penal.

Percebam que o tipo penal é muito claro e, associado aos 5 dolos específicos do art. 1º, resta clara a necessidade de criminalização dessa conduta, agora vetada.

*Coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, **sem justa causa**, a reunião, a associação ou o agrupamento pacífico de pessoas **para fim legítimo**.*

Ora, se a reunião é para fim legítimo, como pode esse artigo ser vetado pelo fato de as reuniões serem favoráveis à incitação de crime ou apologia ao criminoso? Não faz sentido.

Afastou-se a tutela penal ignorando a própria redação do tipo penal e os dolos específicos: prejudicar outrem; beneficiar a si mesmo; beneficiar terceiro; por mero capricho ou por satisfação pessoal.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 36

Art. 36

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

COMENTÁRIOS

Decretar – deliberar, decidir, cominar

O tipo penal exige que a indisponibilidade de ativos financeiros seja feita em processo judicial, ficando de fora qualquer bloqueio de ativos decretado em fase de investigação preliminar, por respeito à taxatividade da lei penal.

Objeto material do delito

Indisponibilidade de ativos financeiros.

O que são os ativos financeiros expressos no tipo penal?

Os ativos financeiros podem ser definidos como tudo aquilo que é negociado no mercado financeiro.

Os principais tipos de ativos incluem:

- **Ações:** frações do capital de uma determinada empresa;
- **Moeda e câmbio:** negociação de moedas oriundas de diversos países (exemplo: dólar e euro, dólar australiano e iene etc.);
- **Títulos públicos:** ferramenta utilizada pelo governo para captar recursos e financiar a dívida pública;
- **Commodities:** compra e venda de mercadorias diversas realizadas diretamente na bolsa de valores (soja, gado);
- **Títulos privados:** documentos emitidos por empresas privadas para angariar recursos, comercializados por meio de depósito bancário, letra de câmbio e diversas outras formas;

• **Mercado de opções:** pode ser definido como uma espécie de apólice de seguro, que dá ao titular o direito de comprar qualquer tipo de ativo.

Extrapole exacerbadamente o valor da dívida

Extrapolar – exceder, ultrapassar, exorbitar,

Exacerbar– exceder, agravar, aumentar

A utilização do pleonismo, que é uma redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem “*extrapolar exacerbadamente*”, visa enfatizar que somente será crime de abuso de autoridade se houver um exagero intencional após ser informado do excesso.

No entanto, há ausência de taxatividade, pois não foi estipulado um percentual como um parâmetro legal para quantificar o excesso.

Além de se ter a necessidade de extrapolar e esse extrapolar ser exacerbado, a parte deverá demonstrar que houve excesso da medida, e então, somente após a falta de correção, que se poderá falar em crime de abuso de autoridade por omissão própria. A consumação desse delito está condicionada a uma omissão de conduta após a ciência do excesso, ciência essa feita pela parte.

O tipo penal é muito claro em relação à essa condição objetiva de punibilidade: “*e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la*”.

A finalidade do tipo penal, que seria reprimir o abuso consistente em bloquear ativos financeiros, não parece que será atingida, pois a configuração do crime é bastante difícil.

Parece-nos ser o artigo 36 da Lei de Abuso de Autoridade natimorto por sua redação, além de inconstitucional pela ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º da CF).

O Código de Processo Civil e a legislação especial de execução fiscal (Lei n. 6.830/80) estabelecem preferência na penhora, por dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicações em instituições financeiras, para a realização dos créditos em ações de cobrança (execuções por quantia certa, cumprimentos de sentença, execuções de título extrajudicial, execuções fiscais etc.).

Assim, é comum a ocorrência de bloqueio de ativos financeiros no âmbito de tais ações, o que também pode ocorrer em outros tipos de demanda, nas quais deferida tutela de urgência de natureza cautelar para assegurar o resultado útil de processo em tramitação ou determinadas medidas de sequestro de bens, inclusive contra entes públicos, o que ocorre com relativa frequência, por exemplo, em casos de descumprimento de medidas urgentes em ações de medicamentos.

Há demandas outras nas quais também é comum a decretação da medida de indisponibilidade de bens, como nas medidas cautelares fiscais, ações civis públicas de improbidade administrativa, ações de natureza trabalhista e falencial.

Por fim, no âmbito criminal, também é possível a indisponibilização de ativos financeiros para cumprimento de medidas de sequestro e arresto.

O tipo penal da Lei de Abuso de Autoridade exige que o magistrado, após ser cientificado pela parte a respeito do excesso e concorde com tal argumentação deverá, sob pena de responsabilidade criminal, desbloquear a parte em excesso, mantendo o valor justo do bloqueio feito.

Importante ressaltar que, além de bloqueio excessivo, será necessário, para a configuração típica subjetiva, um dos 5 dolos específicos alternativos do art. 1º desta lei:

– prejudicar outrem;

- beneficiar a si mesmo;
- beneficiar terceiro;
- por mero capricho;
- por satisfação pessoal.

Sujeito ativo

Crime próprio que só pode ser praticado por magistrado que decreta o bloqueio excessivo dos ativos financeiros.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que teve seus ativos financeiros bloqueados de maneira exacerbada e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 1 ano admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 37

Art. 37

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

COMENTÁRIOS

Demorar – retardar, lerdar, diferir, postergar.

Trata-se de crime de abuso de autoridade praticado por desembargadores ou ministros de Tribunais que, em sessão de julgamento colegiado, pedem vista com o intuito de procrastinar o andamento ou retardar o julgamento.

Objeto material do delito

O pedido de vista para examinar processo.

Elemento normativo do tipo

Demasiada e injustificadamente.

Sujeito ativo

Trata-se de crime próprio que só poderá ser praticado por magistrado de Tribunal.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que tem o julgamento de seu processo dolosamente atrasado e, indiretamente, o Poder Público.

Benefícios penais

A pena mínima de 6 meses admite a suspensão condicional do processo preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. Com a pena máxima em abstrato de até 2 anos, a competência seria do JECRIM, porém, desembargadores serão julgados originariamente no STJ, e Ministros de Tribunais Superiores no STF.

Dolo específico

O tipo exige a finalidade específica de atrasar o julgamento.

Não se pode descurar do artigo 1º que demanda intenções especiais dos agentes: prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo; beneficiar a terceiro; por mero capricho; ou para satisfação pessoal. Competirá ao Ministério Público comprovar esse dolo geral e os dolos específicos nos casos concretos.

Demora demasiada e injustificada

Agiu mal o legislador na escolha dos advérbios *demasiadamente* e *injustificadamente*. São expressões muito vagas que, dissociadas do dolo direito e do dolo específico, não terão força suficiente à adequação típica da demora com o crime do art. 37 da Lei de Abuso de autoridade.

Há Câmaras ou Turmas com milhares de processos conclusos, o que impediria a alegação de demora injustificada. Se a justificativa do excesso de serviço for aceita, esse artigo cairá em desuso.

Proposta de *lege ferenda*

Em nossa opinião, agiu mal o legislador ao não estipular um prazo para que esse processo seja novamente colocado em mesa para que tenha o seu julgamento concluído, como, por exemplo, no prazo máximo de duas sessões de julgamento, o processo deverá estar em pauta, ou será avocado, obrigatoriamente, pelo Presidente da Sessão de Julgamento e, em caso de omissão, responderá por crime próprio de abuso de autoridade.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VI – DOS CRIMES E DAS PENAS – ARTS. 9º A 38º

Art. 38

Art. 38

[...]

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

[...]

Art. 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Conduta criminosa

Antecipar atribuição de culpa de investigado/denunciado, utilizando os meios de comunicação, inclusive redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook e outros), antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação.

Sujeito ativo do delito

Trata-se de crime próprio, pois somente o responsável pelas investigações pode praticar esse delito.

Dupla subjetividade passiva

É a pessoa que tem o status de culpado exposto publicamente com a atribuição antecipada de culpa divulgada nos meios de comunicação e, indiretamente, o Poder Público.

Críticas ao dispositivo

A utilização da conclusão das apurações ou do oferecimento da denúncia ou queixa, como marco separador da possibilidade de atribuir a alguém culpa, foge ao disposto na Constituição da República.

Apesar da equivocada decisão do Supremo Tribunal Federal de antecipar o momento da execução da pena, violando o dispositivo constitucional da presunção de inocência (ou, como queiram, presunção de não culpabilidade ou estado de inocência), continuamos a ter a definitividade da decisão penal condenatória como o marco divisório entre o juridicamente

inocente e o culpado.

Não pode um dispositivo liberar a possibilidade de imputar culpa a alguém antes do trânsito em julgado.

A execração pública de pessoas investigadas ou denunciadas, por parte do próprio Estado, é contraproducente e inconstitucional.

Não se está aqui censurando o direito ou dever de informar. Pedimos apenas alguns cuidados para que a notícia ou informação seja apresentada ao público.

Verbos no condicional e termos não pejorativos ajudariam a compatibilizar o equilíbrio constitucional necessário entre as duas situações.

Como, por exemplo, o agente supostamente teria praticado tal fato.

Isso é muito diferente da seguinte notícia:

O delinquente cometeu o crime.

Não se trata apenas de jogo de palavras, e sim de um cuidado constitucional.

Razões de veto

“A propositura legislativa viola o princípio constitucional da publicidade previsto no art. 37, que norteia a atuação da Administração Pública, garante a prestação de contas da atuação pública à sociedade, cujos valores da coletividade prevalecem em regra sobre o individual, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a comunicação a respeito de determinados ocorrências, especialmente sexuais ou que violam direitos de crianças e adolescentes, podem facilitar ou importar em resolução de crimes.”

Comentários sobre o veto

Absurdas as razões de veto desse dispositivo.

Alega-se que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual, para justificar a utilização dos meios de comunicação, incluindo as redes sociais, **para antecipar a culpa de alguém**.

Utiliza-se o princípio da publicidade do art. 37 da Constituição da República e **ignora-se, cabalmente**, a cláusula pétrea da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Na ponderação de valores entre a presunção de inocência e a publicidade, por óbvio, ganha a presunção de inocência que todos nós temos contra o arbítrio estatal de destruir as nossas imagens antecipando a publicidade da materialidade e autoria de eventuais delitos.

Sugestão de obtenção de resultados

Tornar público as circunstâncias (tempo, local e *modus operandi*) em busca de possíveis vítimas, quando se tratar de um caso com suspeitas de pluralidade de sujeitos passivos, respeitaria o princípio da publicidade da Administração Pública preservando, como deve ser, a presunção de inocência.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VII – DO PROCEDIMENTO – ART. 39

Art. 39

Art. 39

[...]

CAPÍTULO VII DO PROCEDIMENTO

Art. 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta Lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Antes de qualquer observação a respeito do procedimento a ser seguido, importante lembrar que muitos dos agentes públicos, sujeitos ativos dos crimes de abuso de autoridade, possuem prerrogativa de função. Para essas hipóteses, seguir-se-á, por certo, os procedimentos correspondentes ao rito especial de cada Tribunal competente para julgar as respectivas autoridades.

Fora das hipóteses de prerrogativa de foro, o rito escolhido pelo legislador para investigar, processar e punir os crimes de abuso de autoridade expressos taxativamente nesta lei seguiu a regra geral do rito comum.

Dessa forma, não há etapas procedimentais novas que justifiquem o rótulo de procedimento especial para a nova Lei de Abuso de Autoridade.

Ao remeter o aplicador da lei para o Código de Processo Penal e para a Lei dos Juizados Especiais, devemos nos ater ao conteúdo do artigo 394 do Código de Processo Penal que especifica quando o rito comum será ordinário, sumário e sumaríssimo.

Eis o texto legal do CPP:

LIVRO II – DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE

TÍTULO I – DO PROCESSO COMUM

CAPÍTULO I – DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 394. O procedimento será comum ou especial.

§ 1º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:

I – ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;

II – sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.

(...)

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições

do procedimento ordinário.

Tendo a base normativa para a identificação dos procedimentos, basta agora cruzar a informação da pena máxima em abstrato dos delitos da nova Lei de Abuso de Autoridade com as especificações do art. 394 do CPP e chegamos às seguintes conclusões:

Procedimento comum ordinário

Crimes com pena máxima igual ou superior a 4 (quatro) anos. Seguirão esse rito os crimes dos artigos 9º, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 36 da Lei de Abuso de Autoridade e o crime do art. 10 da Lei das interceptações Telefônicas.

Os processos da competência do juiz singular são monofásicos, porque constituídos de uma única fase formada pela instrução com contraditório e pelo julgamento. Por essa razão, pessoal, conhecemos a sua audiência como de instrução e julgamento.

Podemos conceituar, então, a instrução criminal como sendo o conjunto de atos processuais praticados com o fim de obter a maior proximidade possível com a realidade do fato praticado e, com isso, possibilitar a decisão judicial mais justa e compatível com a verdade processual.

A fase do procedimento começa com a decisão do juiz que recebe a denúncia e determina a citação do réu, para responder à acusação em 10 dias, por escrito.

Não sendo caso de rejeição da denúncia, deve o juiz recebê-la, determinando, a seguir, a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, se não for o caso de suspensão condicional do processo (previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95).

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Com o recebimento da denúncia, considera-se iniciada a ação penal.

Além disso, o recebimento da denúncia constitui causa de interrupção da prescrição (art. 117, I, do CP).

Nesse sentido, se o processo for considerado nulo desde o início, o prazo prescricional não será interrompido, pois, na hipótese, o recebimento da denúncia não gerou nenhum efeito.

Ao receber a denúncia ou queixa, o juiz determina a citação do acusado para apresentar a resposta à acusação.

A resposta à acusação constitui peça obrigatória da defesa, pois, se não apresentada, deverá o juiz nomear defensor público ou advogado conveniado com a Defensoria Pública para oferecê-la, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP.

Assim, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado regularmente, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias.

A ausência de nomeação de defensor pelo juiz para oferecimento da resposta à acusação gerará nulidade absoluta.

A reforma processual penal instituída pelas Leis n. 11.690/2008 e 11.719/2008, ao visar a maior celeridade e o aprimoramento na colheita da prova, primou pelo princípio da oralidade, do qual decorrem vários desdobramentos: (a) concentração dos atos processuais em audiência única; (b) imediatidade; (c) identidade física do juiz.

A Lei procurou concentrar toda a instrução em uma única audiência, permitindo-se a cisão apenas em hipóteses excepcionais. Vejamos:

- 1) remessa do inquérito policial;
- 2) distribuição e vista ao promotor;
- 3) oferecimento da denúncia ou queixa;
- 4) o juiz analisará se não é caso de rejeição liminar (deverá avaliar todos os requisitos do art. 395: condição da ação, possibilidade jurídica do pedido etc.);
- 5) se não for caso de rejeição liminar, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias;
- 6) com a resposta do acusado, analisará o juiz a possibilidade de absolvição sumária. Como já afirmado, trata-se de resposta obrigatória; passado o prazo de dez dias para o seu oferecimento, o juiz obrigatoriamente nomeará um defensor para realizar o ato;
- 7) não sendo hipótese de absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de sessenta dias, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. A audiência será única, por força do princípio da concentração dos atos processuais;
- 8) na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de sessenta dias:
 - (a) tomada de declarações do ofendido.
 - (b) inquirição das testemunhas arroladas pela acusação.

Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas (art. 401, § 1º). A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 do Código (art. 401, § 2º). Cumpre consignar que caberá primeiramente à parte que arrolou a testemunha, e não ao juiz realizar as perguntas. O sistema presidencialista, em que as perguntas das partes eram formuladas por intermédio de um magistrado, restou superado com a nova reforma processual penal. Assim, tal como sempre sucedeu no interrogatório realizado no Plenário do Júri, as partes formularão as perguntas diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida (CPP, art. 212, *caput*). Trata-se do sistema de inquirição direta, chamado de *cross-examination*, de inspiração norte-americana. Caberá, ainda, ao magistrado, complementar a inquirição sobre pontos não esclarecidos (CPP, art. 212, parágrafo único).

- (c) inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código. Aplicam-se os comentários constantes do item b.
- (d) esclarecimentos dos peritos.
- (e) acareações.
- (f) reconhecimento de pessoas e coisas.
- (g) interrogatório, em seguida, do acusado.

(h) requerimento de diligências. Cisão da audiência com a consequente apresentação de alegações finais, por memorial: o requerimento de diligência, antes previsto no art. 499, agora, será realizado na própria audiência de instrução, após a produção das provas. Dessa forma, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Ordenada diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de cinco dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de dez dias, o juiz proferirá a sentença. Trata-se, portanto, de hipótese em que será autorizada a cisão da audiência única.

(i) ausência de requerimento de diligência. Alegações orais e sentença: Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por vinte minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais dez, proferindo o juiz, a seguir, sentença. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos dez minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

(j) complexidade da causa. Cisão da audiência com a consequente apresentação de alegações finais, por memorial: O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de cinco dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de dez dias para proferir a sentença. Cuida-se, aqui, de mais uma hipótese em que se admitirá a cisão da audiência única. Quando do oferecimento das alegações finais, a parte deve arguir as nulidades eventualmente ocorridas no curso da instrução criminal (art. 571, II). Deve também produzir todas as suas alegações quanto ao mérito e às preliminares, sob pena de preclusão.

(k) do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

Mutatio libelli e cisão da audiência: De acordo com a atual redação do art. 384, *caput*, do CPP: “Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.” Trata-se de mais uma hipótese em que ocorrerá a cisão da audiência única do art. 400 do CPP.

Procedimento comum sumaríssimo

Infrações de menor potencial ofensivo, consideradas todas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Seguirão o rito comum sumaríssimo os crimes dos artigos 12, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 da Lei de Abuso de Autoridade.

O rito comum sumaríssimo tem lastro normativo constitucional. Expresso no art. 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

O artigo 98, I, da Constituição Federal autorizou a criação dos Juizados especiais criminais, providos por juízes togados e leigos, que serão competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

Para os crimes de abuso de autoridade que sigam o rito sumaríssimo, a competência será determinada, quando não existir prerrogativa de foro, pelo lugar em que foi praticada a infração penal – TEORIA DA ATIVIDADE.

O rito comum sumaríssimo pode ser apresentado em três momentos diferentes:

- a) fase preliminar – TC;
- b) audiência preliminar – 74, 76, denúncia;
- c) audiência de instrução – defesa, audiência e sentença.

A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança.

Teremos duas audiências nesse rito.

Na audiência preliminar, serão aplicados os institutos despenalizadores da composição civil dos danos, da transação penal e da suspensão condicional do processo (artigos 74, 76 e 89 respectivamente). Não é porque o agente ativo do delito é autoridade que não merecerá a aplicação desses institutos. Essa audiência, caso não tenha sido obtido nenhum benefício despenalizador, terminará com o oferecimento oral da denúncia ou queixa-crime.

A segunda audiência, de instrução e julgamento, inicia com a tentativa da defesa em fazer que a denúncia anteriormente apresentada não seja recebida. Recebida esta, as provas serão produzidas, sempre respeitando os princípios da oralidade e informalidade, até que a sentença final seja proferida. Dessa sentença caberá apelação em 10 dias para a Turma Recursal (art. 82 da Lei 9.099/95).

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS – ARTS. 40 A 45

Art. 40

Art. 40

[...]

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. O art. 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 2º (...)

(...)

§ 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado.

(...)

§ 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.

§ 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária." (NR)

A nova Lei de Abuso de Autoridade alterou a Lei da Prisão Temporária – Lei 7.960, incluindo o § 4º-A, melhorando a redação do § 7º e criando o § 8º atrelando o cômputo do prazo de prisão temporária ao prazo penal, previsto no art. 10 do Código Penal, ou seja, o dia em que o agente é efetivamente preso é computado no exíguo prazo da prisão temporária, mesmo resultando em um primeiro dia do prazo de poucas horas. Ex: o agente é preso, por cumprimento de mandado de prisão temporária, às 22 horas do dia 01.09.2019. Assim, uma prisão temporária de 5 dias terá, no seu primeiro dia, apenas 2 horas (das 22h às 12). Restando apenas 4 dias de prazo de prisão, como saldo a cumprir.

O novo § 4º-A trouxe novidade legislativa importante para o preso e para o agente que tem o preso sob a sua custódia. O mandado de prisão conterá, necessariamente, o período de duração da prisão (por ex: 5 dias ou; 30 dias em caso de crimes hediondos ou equiparados) e o dia exato em que o preso deverá ser libertado.

Com base nesse documento público, o mandado de prisão, será possível instruir eventual habeas corpus com liminar para a soltura de preso com prisão vencida e, concomitantemente, apresentar notícia criminis de abuso de autoridade contra o agente público responsável pela custódia ilegal por excesso de prazo.

Além da alteração do § 4º-A, modificou-se o § 7º do art. 2º da Lei 7.960.

Eis a redação anterior do § 7º:

§ 7º Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.

E a nova redação, aprimorada e mais técnica:

§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.

A nova redação do § 7º não limita, de forma errônea, em 5 dias, o prazo da prisão, visto que poderá ter prazo superior a esse, como os 30 dias da Lei dos Crimes Hediondos.

Outra mudança relevante foi excepcionar a soltura do preso não apenas com a decretação da prisão preventiva, como estava previsto na lei, mas também com a prorrogação da própria prisão temporária já decretada.

Por fim, confirmou-se a tese de que o prazo da prisão temporária, assim como o prazo de qualquer prisão, deve seguir a contagem de tempo do Código Penal, pois interfere diretamente na liberdade, incluindo o dia da prisão como primeiro dia da contagem do prazo, mesmo que sua duração tenha menos de 24 horas.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS – ARTS. 40 A 45

Art. 41

Art. 41

[...]

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

Art. 41. O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei." (NR)

A antiga redação do crime do art. 10 da Lei 9.296/96 nos apresentava as seguintes condutas típicas:

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

O antigo tipo penal podia ser praticado por três diferentes formas:

a) Realização de interceptação sem autorização judicial: Tal conduta se dá com a captação ilegal da comunicação telefônica de outras pessoas, sem a ciência dos comunicadores. Para a sua caracterização é desnecessária a divulgação de informações.

b) Realização de interceptação com objetivos não autorizados em lei: Nessa situação, a interceptação é realizada com a prévia decisão judicial, todavia, a medida visa alcançar outras finalidades, que não a investigação criminal para apurar materialidade e autoria delitivas.

c) Quebra do segredo de justiça: Na espécie, o sujeito ativo não preserva o sigilo da interceptação telefônica consagrado no art. 8º da Lei 9296/96. Cuida-se de crime próprio, porquanto o sujeito ativo necessariamente deve ser alguém que tomou ciência legitimamente do teor de uma interceptação telefônica em decorrência do cargo, função ou profissão.

A nova redação do tipo penal não eliminou nenhuma dessas três possibilidades, ao contrário, criou duas situações típicas a serem estudadas.

Eis a nova redação do tipo penal:

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, **promover escuta ambiental** ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com

objetivos não autorizados em lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput com objetivo não autorizado em lei. (grifos nossos)

A nova redação no artigo 10 trazido pela Lei de Abuso de Autoridade trouxe duas novidades:

** incluiu, no tipo penal, a promoção de escuta ambiental;*

Escuta ambiental: é a captação de uma comunicação, no ambiente dela, feita por terceiro, com o consentimento de um dos comunicadores.

Exemplificamos a hipótese de uma vítima de extorsão que, com o auxílio da autoridade policial, efetue a captação do áudio no exato momento em que o criminoso constrange a vítima a deixar de fazer alguma coisa para obter a vantagem indevida. Nesse caso, não haveria crime, pois o objetivo da escuta ambiental foi o de realizar investigação e lavrar o flagrante.

** criou conduta equiparada ao caput para punir especificamente a autoridade judicial (juízes, desembargadores ou ministros) que determina a execução de interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça com objetivo não autorizado em lei.*

Criou-se figura típica própria de autoridade judicial que determina a execução de interceptação telefônica com outros objetivos que não sejam produzir prova em investigação preliminar ou instruir o processo, para contribuir na realização da materialidade e da autoria.

ATENÇÃO: todos os delitos da nova Lei de Abuso de Autoridade são punidos, de forma cirúrgica, com detenção.

Além da impossibilidade do regime inicial fechado, pela escolha da detenção para todos os crimes, há um importante tópico relacionado com a Lei 9.296/96.

Sabemos que um dos requisitos para a autorização judicial de interceptação das comunicações telefônicas, informáticas e telemáticas é a previsão legal do preceito secundário punido com reclusão (art. 2º da Lei 9.296/96). Assim, nenhum delito novo de abuso de autoridade pode ser investigado com a interceptação telefônica, sob pena de responsabilidade criminal de quem o fizer.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS – ARTS. 40 A 45

Art. 42

Art. 42

[...]

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

Art. 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 227-A:

"Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência.

Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independará da pena aplicada na reincidência."

Esse artigo 42 criou um artigo para o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/90.

No Título VII da lei que trata Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, em seu Capítulo I – Dos Crimes, na Seção I – Disposições Gerais, foi inserido o novo dispositivo legal.

Os comentários a respeito dos efeitos da condenação, já com essa alteração, foram feitos no art. 4º da presente lei, para os crimes de abuso de autoridade dessa lei.

Entretanto, mantendo coerência na tutela penal dos efeitos da condenação, vinculados agora com a reincidência, o legislador promove a inclusão de novo dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 227-A, que demanda uma explicação muito detalhada e atenta.

Em primeiro lugar, o novo dispositivo está relacionado aos crimes do ECA. O trecho “para os crimes previstos nesta Lei” deixa isso bem categorizado.

Na sequência, o ECA condiciona a perda do cargo, função ou mandato à reincidência em crimes do ECA, desde que praticados com abuso de autoridade. Ou seja, há uma mescla interdisciplinar entre a nova Lei de Abuso de Autoridade e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo conduzido pela teleologia legislativa, cabe agora identificarmos quais crime do ECA, praticados contra criança e adolescente, admitem agentes públicos como sujeitos ativos dos delitos específicos valendo-se de sua situação pública e com os dolos específicos expressos no art. 1º dessa nova Lei de Abuso de Autoridade.

Há, no ECA, crimes próprios e crimes comuns. Todos eles podem ser praticados por agentes públicos abusando de sua autoridade e com as finalidades específicas previstas na lei. Alguns mais óbvios que outros, como os crimes dos arts. 231:

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.

E art. 234:

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão.

Entretanto, nada impede o agente público de praticar delitos que podem ser praticados por qualquer pessoa, como o art. 236:

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei. Exemplificamos um policial que impede um agente do Conselho Tutelar de exercer a sua função por mero capricho.

Por força da redação do novo dispositivo, poder-se-á surgir duas interpretações: a) o agente nessas condições só perderá seu cargo, do mandato ou da função em caso de reincidência específica em crimes do ECA praticados com abuso de autoridade em concurso de crimes; b) por escolher redação diversa do artigo 4º da nova Lei de Abuso de Autoridade, a simples ocorrência da reincidência, sem a necessidade de ser específica em crimes do ECA, já teria o condão de gerar o efeito da condenação de perda de cargo, do mandato ou da função. Aguardemos o posicionamento da jurisprudência a respeito desse tema.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS – ARTS. 40 A 45

Art. 43

Art. 43

[...]

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-B:

'Art. 7º-B Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.'

* Artigo vetado pelo Presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional (DOU 27.09.2019, edição extra).

=> Artigo vetado pelo Presidente da República. Caso haja derrubada do veto, o artigo foi comentado normalmente em sua íntegra.

COMENTÁRIOS AO ARTIGO

Excelente a iniciativa de criminalizar as condutas que violam as prerrogativas dos advogados exatamente na Lei de Abuso de Autoridade, eis que as duas questões andam paralelamente.

Foi dada ao advogado a oportunidade de, ficando atento às suas prerrogativas, dar voz de prisão em flagrante para os agentes públicos que abusarem de sua função, cargo ou mandato eletivo com o dolo específico. Mas foi retirada dos advogados essa oportunidade pelo veto. Voltamos ao *status quo*.

Pela dissociação forçada da Defensoria Pública em relação à OAB, apenas os advogados inscritos no Quadros da OAB receberiam a tutela específica contra os atos de abuso de autoridade praticados contra prerrogativas específicas de advogados, não fosse o veto.

No art. 7º da Lei n. 8.906/96, encontramos as prerrogativas dos advogados indicadas, especificamente, neste artigo.

Vamos ao seu conteúdo:

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;

III – comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;

IV – ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB;

V – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar; (*Vide* ADIN 1.127-8)

A Ordem dos Advogados do Brasil luta há muitos anos pela criminalização das prerrogativas dos advogados, diante de tanta violação aos direitos básicos de atuação profissional da advocacia.

Porém, na primeira oportunidade em que houve a criminalização das prerrogativas, aconteceu o veto integral do novo tipo penal.

Independentemente da tentativa de cauda penal legislativa, há um projeto de lei em andamento criminalizando, de forma taxativa, a violação das prerrogativas dos advogados.

Razões de veto:

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois criminaliza condutas reputadas legítimas pelo ordenamento jurídico. Ressalta-se que as prerrogativas de advogados não geram imunidade absoluta, a exemplo do direito à inviolabilidade do escritório de advocacia e a própria Lei nº 8.906, de 1996, com redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008, que permite a limitação desse direito quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, notadamente concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (v.g. INQ. 2424, Rel. Min. Cezar Peluso, p., j. 26/11/2008).”

Críticas ao veto presidencial

Novamente a razão de veto passou longe da compreensão do tipo penal.

O artigo protege as atividades lícitas do exercício da advocacia. Por muitas vezes, os agentes públicos utilizam o poderio do Estado e violam as prerrogativas dos advogados, sem justa causa. As prerrogativas aqui especificadas – apenas os incisos II a V – não demandam interpretação e são muito claras: ou se respeita esses direitos ou praticarão crime de abuso de autoridade. Caso exista justa causa para essa violação, faltará o dolo específico e não responderá o agente público pelo abuso, afastando o medo estatal que gerou o veto.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS – ARTS. 40 A 45

Art. 44

Art. 44

[...]

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

Art. 44. Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o § 2º do art. 150 e o art. 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

A Lei de Abuso de Autoridade antiga foi expressamente revogada por esse artigo.

Com os vetos presidenciais, surgiu um problema de anomia (ausência de tutela penal).

Crimes que estavam em vigor, na Lei 4.898/65 e nos artigos do Código Penal, ao serem expressamente revogados por este artigo, sairão, após a *vacatio legis*, de nosso ordenamento jurídico, justamente por força do novo tratamento jurídico dado para essas condutas na nova Lei de Abuso de Autoridade.

Mas, revogando esses dispositivos e vetando os novos crimes, existirão 4 situações que não receberão mais tratamento penal.

São os seguintes casos:

9º *caput* – artigos 3º e 4º da Lei 4.898/65

9º, I – artigo 4º, d, da Lei 4.898/65

9º, II – artigo 4º, e, da Lei 4.898/65

20 – artigo 3º, j, da Lei 4.898/65

32 – artigo 3º, j, da Lei 4.898/65

35 – artigo 3º, h, da Lei 4.898/65

Além da Lei 4.898/65, dois dispositivos do Código Penal também foram revogados.

Seção II – Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio

Violação de domicílio.

Art. 150 – Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa. (...)

§ 2º – Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder.

Exercício arbitrário ou abuso de poder.

Art. 350 – Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder:

Pena – detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único – Na mesma pena incorre o funcionário que:

I – ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a estabelecimento destinado a execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança;

II – prolonga a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade;

III – submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

IV – efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.

As revogações eram necessárias diante da nova tipificação dos delitos de abuso de autoridade.

A criminalização da invasão de domicílio prevista nessa lei elevou a prática por agentes públicos de mera causa de aumento de pena para delito autônomo.

[...]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS – ARTS. 40 A 45

Art. 45

Art. 45

[...]

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

Art. 45. Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.

* *Vacatio legis* (vacância da lei)

Escolheu-se para a nova Lei de Abuso de Autoridade o período de 120 dias de vacância.

Entendemos correta a opção legislativa pelo período de vacância maior do que os tradicionais 45 dias da LINDB ou a entrada em vigor na data de publicação da lei pelo impacto que poderá ter no dia a dia da atuação dos agentes da persecução penal.

A antiga LICC, hoje LINDB, prevê em seu artigo 1º que a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada, salvo disposição em contrário.

Costuma-se afastar a regra dos 45 dias, na grande maioria das leis, deixando expresso que a entrada em vigor será feita com a publicação da lei.

Não foi o caso da nova Lei de Abuso de Autoridade.

Com acerto, escolheu o Congresso Nacional deixar a lei publicada por 120 dias sem vigência, para que toda a sociedade civil e os agentes públicos pudessem ficar a par das mudanças, da entrada em vigor dos novos tipos penais, das novidades legislativas em outras leis e das revogações expressas.

Desde a criminalização do uso arbitrário das algemas até a violação diária das prerrogativas dos advogados, faz-se necessário um tempo de *vacatio*, após a publicação da lei no Diário Oficial da União para que alguns pontos sejam debatidos com mais exaustão e eventuais dúvidas possam ser identificadas como objeto de atenção para a conduta diária dos agentes públicos, evitando-se uma enxurrada de prisões em flagrante de agentes públicos desavisados.

Por ser uma lei com conteúdo penal, as suas figuras típicas somente passarão a fazer efeito após a vigência da normal, e não após a publicação da lei. Assim, os sujeitos ativos da lei terão tempo para identificar as condutas mais próximas de sua atuação funcional e trabalhar para evitá-las, seja com orientações direta para os funcionários, seja com a criação de procedimentos internos específicos para evitar o enquadramento típico do que normalmente costuma fazer.

Recomenda-se que os órgãos incumbidos do controle da persecução penal, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Magistratura utilizem esse período para informar os

seus agentes públicos, em especial, recebendo as suas dúvidas e buscando soluções com base no ordenamento jurídico, jurisprudência e doutrina pretéritas, para os pontos de convergência com a legislação anterior.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

ANEXO I – TEXTO DA LEI 13.869/2019

ANEXO I

TEXTO DA LEI 13.869/2019

Diário Oficial da União

Publicado em: 05/09/2019 | Edição: 172-A | Seção: 1 – Extra | Página: 1

Órgão: Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

CAPÍTULO II DOS SUJEITOS DO CRIME

Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

I – servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II – membros do Poder Legislativo;

III – membros do Poder Executivo;

IV – membros do Poder Judiciário;

V – membros do Ministério Público;

VI – membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo *caput* deste artigo.

CAPÍTULO III DA AÇÃO PENAL

Art. 3º (VETADO).

CAPÍTULO IV DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

SEÇÃO I DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Art. 4º São efeitos da condenação:

I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II – a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III – a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

SEÇÃO II DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:

I – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

II – suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

III – (VETADO).

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou

cumulativamente.

CAPÍTULO V DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

Art. 6º As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.

Art. 8º Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

CAPÍTULO VI DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 9º (VETADO).

Art. 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 11. (VETADO).

Art. 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I – deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

II – deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;

III – deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

IV – prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I – exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II – submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III – (VETADO).

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

Art. 14. (VETADO).

Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 16. (VETADO).

Art. 17. (VETADO).

Art. 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 19. Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

Art. 20. (VETADO).

Art. 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no *caput* deste artigo, quem:

I – coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;

II – (VETADO);

III – cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).

§ 2º Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:

I – eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência;

II – omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

Art. 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art. 26. (VETADO).

Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

Art. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 30. (VETADO).

Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

Art. 32. (VETADO).

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresse amparo legal:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

Art. 34. (VETADO).

Art. 35. (VETADO).

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 38. (VETADO).

CAPÍTULO VII DO PROCEDIMENTO

Art. 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta Lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. O art. 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º [...]

[...]

§ 4º-A O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no *caput* deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser

libertado.

[...]

§ 7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.

§ 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária.” (NR)

Art. 41. O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no *caput* deste artigo com objetivo não autorizado em lei.” (NR)

Art. 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 227-A:

“Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do *caput* do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência.

Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência.”

Art. 43. (VETADO).

Art. 44. Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o § 2º do art. 150 e o art. 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Art. 45. Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 5 de setembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro

Wagner de Campos Rosário

Jorge Antonio de Oliveira Francisco

André Luiz de Almeida Mendonça

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

ANEXO II – JUSTIFICATIVA DA LEI

ANEXO II – JUSTIFICATIVA DA LEI

A presente sugestão de Projeto de Lei visa a atualizar a legislação em vigor que define os crimes de abuso de autoridade.

Ocorre abuso de autoridade quando o agente público exerce o poder que lhe foi conferido com excesso de poder (o agente atua além de sua competência legal) ou com desvio de finalidade (atua com o objetivo distinto daquele para o qual foi conferido). É sempre ato doloso, portanto.

A partir dessa premissa procurou-se tipificar as condutas praticadas com abuso de autoridade pelos agentes públicos.

O anteprojeto prevê que sejam sujeitos ativos do crime de abuso de autoridades os membros de Poder, os membros do Ministério Público e dos tribunais de contas e agentes da Administração Pública, servidores públicos, civis ou militares, ou a eles equiparados.

O sujeito passivo do abuso de autoridade não é só o cidadão, mas também a Administração Pública. O interesse em reprimir a conduta abusiva transcende a esfera individual do cidadão. Por isso, sugere-se a adoção da ação penal pública incondicionada, para a persecução dos crimes de abuso de autoridade, bem assim a admissão da ação privada subsidiária, nos termos do Código de Processo Penal.

Como efeito da condenação, sugere-se tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, fixando o Juiz na sentença o valor mínimo para a sua reparação; a perda do cargo, mandato ou função pública; inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública.

Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos, nos termos do Código Penal, além da suspensão do exercício do cargo, mandato ou função, sem vencimentos, e a proibição de exercer função de natureza policial no distrito da culpa.

A punição pelo crime de abuso de autoridade não isenta o agente público de responder pelas consequências disciplinares e civis de seu ato. Por isso, a autoridade disciplinar deve ser comunicada do fato, para a devida apuração.

Propõe-se a tipificação da prisão ilegal, do prolongamento ou manutenção indevida da prisão ou da execução da pena e da violação dos direitos do preso.

De modo inovador, propõe-se ainda tipificar a conduta de constranger o preso com o intuito de obter favor ou vantagem sexual; com o objetivo de exposição ou de exibição pública ou aos meios de comunicação ou de produzir provas contra si mesmo. Outrossim, tipifica o uso indevido de algemas.

Sugere-se a tipificação do constrangimento de alguém a prestar depoimento quando não for obrigado, da submissão do preso a interrogatório durante o repouso noturno, da manutenção de presos de sexos opostos no mesmo ambiente prisional.

O exercício do direito de defesa também mereceu atenção do anteprojeto, que sugere tipificar o embaraço ao exercício do direito de petição do preso, ou de entrevistar-se com seu advogado, ou

do réu de comunicar-se com seu defensor durante a investigação criminal ou a instrução processual. Tipificou-se condutas que ofendam à inviolabilidade do domicílio, inclusive mediante cumprimento de mandado judicial em afronta à ordem que o autorizou, bem como a prestação de informações falsas com a finalidade de prejudicar o investigado ou a parte, e a recusa em dar acesso aos autos ao defensor ou decretar abusivamente sigilo dos autos para obstar o acesso do advogado.

A fraude processual com o objetivo de incriminar ou agravar a situação do investigado ou réu, ou de isentar ou atenuar a responsabilidade do agente público que tenha cometido abuso de autoridade também deve passar a ser crime.

O exercício abusivo do poder de dar início a persecução penal contra quem o sabe inocente, o excesso de prazo injustificado para a conclusão da investigação ou da fiscalização, ou sua prorrogação abusiva, com a finalidade de causar constrangimento, sugere-se também sejam tipificados.

Exigir de alguém o cumprimento de obrigação, ou o dever de fazer ou não fazer, sem fundamentação legal, impedir abusivamente o exercício do direito de reunião ou de manifestação, ou deixar de corrigir erro que sabe existir em processo, com o fim de causar constrangimento ao interessado ou exceder-se no cumprimento de ordem legal ou mandado judicial, sem justa causa, também devem ser tipificados.

Por fim, no âmbito da tipificação penal, destacam-se a inclusão de 2 novos crimes:

O primeiro deles, a famosa “carteirada”, que é a utilização do cargo ou função para se eximir do cumprimento de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio.

O segundo, o uso abusivo dos meios de comunicação ou de redes sociais pela autoridade encarregada da investigação que antecipa a atribuição de culpa, antes de concluída a investigação e formalizada a acusação.

O anteprojeto não proíbe a divulgação da investigação, permitindo que o seu encarregado preste contas do que foi feito e porque o foi, como mecanismo de indispensável transparência. Contudo, na divulgação de uma investigação pública, quem a conduz não deve fazer acusações ou adiantar conclusões sobre a culpa do suspeito, porquanto o quebra-cabeças ainda não foi montado, não se sabe qual a imagem vai aparecer ao final e é grande o risco de se cometer injustiças e levandades e causar prejuízos, não só ao indivíduo, mas também ao interesse público.

Por outro lado, o anteprojeto procurou evitar a tipificação da hermenêutica. Isso porque, não se confunde com abuso de autoridade a aplicação da lei pelo agente público e a avaliação de fatos e provas, no exercício de sua independência funcional, com as quais não se concorde ou não se conforme, desde que as faça de modo fundamentado.

A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e das provas deve ser resolvida com os recursos processuais cabíveis, não com a criminalização da hermenêutica ou com atentado às garantias constitucionais próprias dos agentes políticos, que são cláusulas pétreas e pilares do Estado Democrático de Direito.

Evitou-se engessar o juiz ou o membro do Ministério Público, desamarrando-o da necessidade de adotar interpretação de acordo com a jurisprudência atual, ainda que minoritária. Optou-se por manter a permissão para inovar. A capacidade de inovar é que evitou que ainda hoje estivéssemos aplicando os mesmos conceitos e soluções jurídicas do século XIX. As garantias e os direitos que foram reconhecidos pelos tribunais ao longo das últimas décadas, e que tiveram seu início em decisões inéditas, desbravadoras ou pioneiras de juízes de primeiro grau, não existiriam se lhes fosse castrada a possibilidade de inovar.

Também evitou-se colocar camisa de força na autoridade, obrigando-a a adotar apenas a modalidade literal de interpretação da lei. A interpretação gramatical é apenas um dos métodos internacionalmente consagrados de hermenêutica. E nem é a melhor ou mais festejada. Ao seu

lado temos, ainda, a interpretação lógica, a interpretação sistemática, a interpretação histórica, a interpretação sociológica, a interpretação teleológica e a interpretação axiológica. Ao lado da interpretação literal, temos ainda a interpretação restritiva (em geral aplicável às exceções à norma) e a interpretação extensiva.

Se houvéssemos adotado norma penal que punisse qualquer outra interpretação da lei que não a literal, a declaração incidental da inconstitucionalidade da lei, modalidade de controle difuso, por exemplo, estaria vedada. Voltaríamos aos tempos em que juízes eram condenados por abuso de autoridade por recusarem-se a aplicar uma lei ofensiva à Constituição, com a desvantagem de não termos mais Rui Barbosa para defendê-los, como fizera outrora.

Por fim, registre-se que evitou a técnica da elaboração de tipos penais abertos, verdadeiros curingas hermenêuticos, de conteúdo vago e impreciso, que poderia encontrar preenchimento naquilo que o interessado quisesse, o que causaria enorme insegurança jurídica e faria com que as autoridades brasileiras temessem aplicar a lei, sobretudo contra poderosos.

Portanto, são essas as contribuições encaminhadas ao parlamento. O presente texto busca aprimorar o conteúdo de tão importante instrumento legal que visa a combater abusos praticados por agente públicos, sem, contudo, embaraçar a atividade da administração pública, por meio de seus agentes.

Requer-se, assim, o apoio dos Excelentíssimos Senhores e Senhoras membros do Congresso Nacional para a aprovação do texto.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

ANEXO III – VETOS E RAZÕES DE VETO COMPILADAS

ANEXO III

VETOS E RAZÕES DE VETO COMPILADAS

Diário Oficial da União

Publicado em: 05/09/2019 | Edição: 172-A | Seção: 1 – Extra | Página: 2

Órgão: Presidência da República/Despachos do Presidente da República

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 406, de 5 de setembro de 2019.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 7.596, de 2017 (nº 85/17 no Senado Federal), que “Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)”.

Ouvidas, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Justiça e Segurança Pública manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:

ART. 3º

“Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.

§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.”

Razões dos vetos

“A ação penal será sempre pública incondicionada, salvo quando a lei expressamente declarar o contrário, nos termos do art. 100 do Código Penal, logo, é desnecessária a previsão do caput do dispositivo proposto. Ademais, a matéria, quanto à admissão de ação penal privada, já é suficientemente tratada na codificação penal vigente, devendo ser observado o princípio segundo

o qual o mesmo assunto não poderá ser disciplinado em mais de uma lei, nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei Complementar 95, de 1998. Ressalta-se, ainda, que nos crimes que se procedam mediante ação pública incondicionada não há risco de extinção da punibilidade pela decadência prevista no art. 103 cumulada com o inciso IV do art. 107 do CP, conforme precedentes do STF (v.g. STF. RHC 108.382/SC. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. T1, j. 21/06/2011).”

INCISO III DO ART. 5º

“III – proibição de exercer funções de natureza policial ou militar no Município em que tiver sido praticado o crime e naquele em que residir ou trabalhar a vítima, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) anos.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever a proibição apenas àqueles que exercem atividades de natureza policial ou militar no município da prática do crime e na residência ou trabalho da vítima, fere o princípio constitucional da isonomia. Podendo, inclusive, prejudicar as forças de segurança de determinada localidade, a exemplo do Distrito Federal, pela proibição do exercício de natureza policial ou militar.”

ART. 9º

“Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de:

I – relaxar a prisão manifestamente ilegal;

II – substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;

III – deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao dispor que se constitui crime ‘decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais’, gera insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto e que comportam interpretação, o que poderia comprometer a independência do magistrado ao proferir a decisão pelo receio de criminalização da sua conduta.”

ART. 11

“Art. 11. Executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, ou de condenado ou internado fugitivo:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao dispor sobre a criminalização de execução de captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito gera insegurança jurídica, notadamente aos agentes da segurança pública, tendo em vista que há situações que a flagrância pode se alongar no tempo e depende de análise do caso concreto. Ademais, a propositura viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena cominada.”

INCISO III DO ART. 13

“III – produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.”

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois o princípio da não produção de prova contra si mesmo não é absoluto como nos casos em que se demanda apenas uma cooperação meramente passiva do investigado. Neste sentido, o dispositivo proposto contraria o sistema jurídico nacional ao criminalizar condutas legítimas, como a identificação criminal por datiloscopia, biometria e submissão obrigatória de perfil genético (DNA) de condenados, nos termos da Lei nº 12.037, de 2009.”

ART. 14

“Art. 14. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for o de produzir prova em investigação criminal ou processo penal ou o de documentar as condições de estabelecimento penal.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever como elemento do tipo ‘com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública’, gera insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto e que comporta interpretação, notadamente aos agentes da segurança pública, tendo em vista que não se mostra possível o controle absoluto sobre a captação de imagens de indiciados, presos e detentos e sua divulgação ao público por parte de particulares ou mesma da imprensa, cuja responsabilidade criminal recairia sobre os agentes públicos. Por fim, o registro e a captação da imagem do preso, internado, investigado ou indiciado poderá servir no caso concreto ao interesse da própria persecução criminal, o que restaria prejudicado se subsistisse o dispositivo.”

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 15

“Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

I – de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou

II – de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a

presença de seu patrono.”

Razões do veto

“O dispositivo proposto gera insegurança jurídica e contraria o interesse público ao penalizar o agente pelo mero prosseguimento do interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, embora o interrogatório seja oportunidade de defesa, pode ser conveniente à pessoa o conhecimento das perguntas formuladas, bem como exercer o silêncio apenas em algumas questões, respondendo voluntariamente às demais, cuja resposta, a seu exclusivo juízo, lhe favoreçam. Além disso, a falta de assistência por advogado ou defensor público durante o interrogatório não deve ser criminalizada, uma vez que se trata de procedimento administrativo de natureza inquisitiva e não configura falta de defesa ao indivíduo.”

ART. 16

“Art. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função.”

Razões do veto

“A propositura legislativa contraria o interesse público pois, embora seja exigível como regra a identificação da autoridade pela prisão, também se mostra de extrema relevância, ainda que em situações excepcionais, a admissão do sigilo da identificação do condutor do flagrante, medida que se faz necessária com vistas à garantia da vida e integridade física dos agentes de segurança e de sua família, que, não raras vezes, têm que investigar crimes de elevada periculosidade, tal como aqueles praticados por organizações criminosas.”

ART. 17

“Art. 17. Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado ou apreendido, da autoridade ou de terceiro:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aplicada em dobro se:

I – o internado tem menos de 18 (dezoito) anos de idade;

II – a presa, internada ou apreendida estiver grávida no momento da prisão, internação ou apreensão, com gravidez demonstrada por evidência ou informação;

III – o fato ocorrer em penitenciária.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao tratar de forma genérica sobre a matéria, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, há ofensa ao

princípio da intervenção mínima, para o qual o Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, além do fato de que o uso de algemas já se encontra devidamente tratado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 11, que estabelece parâmetros e a eventual responsabilização do agente público que o descumprir.”

ART. 20

“Art. 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.”

Razões do veto

“O dispositivo proposto, ao criminalizar o impedimento da entrevista pessoal e reservada do preso ou réu com seu advogado, mas de outro lado autorizar que o impedimento se dê mediante justa causa, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, trata-se de direito já assegurado nas Leis nºs 7.210, de 1984 e 8.906, de 1994, sendo desnecessária a criminalização da conduta do agente público, como no âmbito do sistema Penitenciário Federal, destinado a isolar presos de elevada periculosidade.”

INCISO II DO § 1º DO ART. 22

“II – executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional, ou de qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial, para expor o investigado a situação de vexame;”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever como elemento do tipo a ‘forma ostensiva e desproporcional’, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Além disso, em operações policiais, o planejamento da logística de bens e pessoas competem às autoridades da segurança pública.”

ART. 26

“Art. 26. Induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (anos) anos, e multa.

§ 1º Se a vítima é capturada em flagrante delito, a pena é de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º Não configuram crime as situações de flagrante esperado, retardado, prorrogado ou diferido.”

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica por indeterminação do tipo penal, e por ofensa ao princípio da intervenção mínima, para o qual o Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, tendo em vista que a criminalização da conduta pode afetar negativamente a atividade investigativa, ante a potencial incerteza de caracterização da conduta prevista no art. 26, pois não raras são as vezes que a constatação da espécie de flagrante, dada a natureza e circunstâncias do ilícito praticado, só é possível quando da análise do caso propriamente dito, conforme se pode inferir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (v.g. HC 105.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T. j. 24/05/2011).”

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 29

“Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, com igual finalidade, omite dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao prever como elemento do tipo ‘informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso’, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Além disso, pode vir a conflitar com a Lei nº 12.527, de 2011, (Lei de Acesso à Informação), tendo em vista que pode conduzir ao entendimento pela possibilidade de divulgação de informações de caráter pessoal, as quais nem sempre são sigilosas, mas são protegidas por aquele normativo.”

ART. 30

“Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Razões do veto

“A propositura legislativa viola o interesse público, além de gera insegurança jurídica, tendo em vista que põe em risco o instituto da delação anônima (a exemplo do disque-denúncia), em contraposição ao entendimento consolidado no âmbito da Administração Pública e do Poder Judiciário, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal (v.g. INQ. 1.957-7/PR, Dj. 11/11/2005), de que é possível a apuração de denúncia anônima, por intermédio de apuração preliminar, inquérito policial e demais medidas sumárias de verificação do ilícito, e se esta revelar indícios da ocorrência do noticiado na denúncia, promover a formal instauração da ação penal.”

ART. 32

“Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois o direito de acesso aos autos possui várias nuances e pode ser mitigado, notadamente, em face de atos que, por sua natureza, impõem o sigilo para garantir a eficácia da instrução criminal. Ademais, a matéria já se encontrar parametrizada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.”

ART. 34

“Art. 34. Deixar de corrigir, de ofício ou mediante provocação, com competência para fazê-lo, erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento:

Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) meses, e multa.”

Razões do veto

“A propositura legislativa, ao dispor que ‘erro relevante’ constitui requisito como condição da própria tipicidade, gera insegurança jurídica por encerrar tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ademais, o dispositivo proposto contraria o interesse público ao disciplinar hipótese análoga ao crime de prevaricação, já previsto no art. 34 do Código Penal, ao qual é cominado pena de três meses a um ano, e multa, em ofensa ao inciso III do art. 7º da Lei Complementar nº 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, em razão do inadequado tratamento do mesmo assunto em mais de um diploma legislativo.”

ART. 35

“Art. 35. Coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a associação ou o agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.”

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, tendo em vista a generalidade do dispositivo, que já encontra proteção no art. 5º, XVI, da Constituição da República, e que não se traduz em uma salvaguarda ilimitada do seu exercício, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o direito à liberdade de se reunir não se confunde com incitação à prática de delito nem se identifica com apologia de fato criminoso.”

ART. 38

“Art. 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Razões do veto

“A propositura legislativa viola o princípio constitucional da publicidade previsto no art. 37, que norteia a atuação da Administração Pública, garante a prestação de contas da atuação pública à sociedade, cujos valores da coletividade prevalecem em regra sobre o individual, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a comunicação a respeito de determinados ocorrências, especialmente sexuais ou que violam direitos de crianças e adolescentes, podem facilitar ou importar em resolução de crimes.”

ART. 43

“Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-B:

‘Art. 7º-B Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.’“

Razões do veto

“A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois criminaliza condutas reputadas legítimas pelo ordenamento jurídico. Ressalta-se que as prerrogativas de advogados não geram imunidade absoluta, a exemplo do direito à inviolabilidade do escritório de advocacia e a própria Lei nº 8.906, de 1996, com redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008, que permite a limitação desse direito quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, notadamente concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (v.g. INQ. 2424, Rel. Min. Cezar Peluso, p., j. 26/11/2008.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020**ANEXO IV – TABELA DO PROJETO DE LEI****ANEXO IV – TABELA DO PROJETO DE LEI**

Confira os crimes tipificados e as penas previstas no Projeto de Lei 7.596/17
Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa
• decretar prisão sem observar as hipóteses legais. A pena é válida também para o juiz que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal; deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar ou por liberdade provisória, quando cabível; ou deixar de deferir liminar ou ordem de <i>habeas corpus</i>, quando cabível;
• decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo;
• executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, ou de condenado ou internado fugitivo;
• constranger o preso ou o detento, com violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; ou produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro;
• constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Vale também para quem prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono;
• impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pedido de preso ao juiz competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Vale também para o juiz que, ciente do impedimento ou da demora, deixar de tomar as providências para resolver o problema ou deixar de enviar o pedido à autoridade competente;

- manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Aplica-se a quem mantiver, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente;

- invadir ou entrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, em imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Sujeita-se à mesma pena quem ameaça alguém para obter acesso; executa mandado de busca e apreensão mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional para expor o investigado a situação de vexame; ou cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h;

- mudar, em diligência, investigação ou processo, o estado das coisas para se eximir de responsabilidade ou deixar de responsabilizar criminalmente alguém ou aumentar-lhe a responsabilidade (mudança de cena de crime, por exemplo). Aplica-se ainda para quem pratica a conduta para se eximir de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado na diligência; ou para omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo;

- constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração;

- obter prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito. Aplica-se também a quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado tendo prévio conhecimento de sua ilicitude;

- divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado;

- dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente;

- decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e não corrigir o erro após demonstração da parte.

Pena – detenção de 6 meses a 2 anos e multa

- deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Aplica-se ainda a quem:

– deixar de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

– deixar de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;

– deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;

– prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal;

• fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública;

Obs.: não haverá crime se a fotografia ou filmagem for produzida para obter prova em investigação criminal ou processo penal ou o de documentar as condições de estabelecimento penal;

• deixar de se identificar ou se identificar falsamente ao preso quando de sua prisão. Aplica-se também para quem, como responsável por interrogatório, deixar de se identificar ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função;

• submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros quando manifestamente não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, da autoridade ou de terceiro;

Obs.: a pena será em dobro se o internado tiver menos de 18 anos de idade; se a presa, internada ou apreendida estiver grávida no momento; ou se o fato ocorrer em penitenciária;

• submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações;

• impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Aplica-se a pena também a quem impedir o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele se comunicar durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência;

• induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei;

- requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém sem qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, exceto quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada;

- prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Aplica-se ainda a quem, com igual finalidade, omite dado ou informação sobre fato juridicamente relevante e não sigiloso;

- estender injustificadamente a investigação em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Aplica-se também a quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, adiá-lo de forma imotivada em prejuízo do investigado ou do fiscalizado;

- negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa; ou impedir a obtenção de cópias;

- exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresse amparo legal. Aplica-se ainda a quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para não cumprir obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido;

- demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento;

- responsável pelas investigações que, por meio de comunicação, inclusive rede social, antecipar atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação.

Pena – detenção de 3 a 6 meses e multa

- deixar de corrigir, de ofício ou a pedido, tendo competência para fazê-lo, erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento.

Pena – detenção de 3 meses a 1 ano e multa

- coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a associação ou o agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo.

Fonte: Agência Senado.

© desta edição [2020]

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020**ANEXO V – RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES MILITARES QUE EXCEPCIONAM O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE DO ARTIGO 11****ANEXO V – RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES MILITARES QUE EXCEPCIONAM O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE DO ARTIGO 11****ANEXO V****RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES MILITARES QUE EXCEPCIONAM O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE DO ARTIGO 11****RELAÇÃO DE TRANSGRESSÕES**

1. Faltar à verdade ou omitir deliberadamente informações que possam conduzir à apuração de uma transgressão disciplinar;
2. Utilizar-se do anonimato;
3. Concorrer para a discórdia ou a desarmonia ou cultivar inimizade entre militares ou seus familiares;
4. Deixar de exercer autoridade compatível com seu posto ou graduação;
5. Deixar de punir o subordinado que cometer transgressão, salvo na ocorrência das circunstâncias de justificação previstas neste Regulamento;
6. Não levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo;
7. Retardar o cumprimento, deixar de cumprir ou de fazer cumprir norma regulamentar na esfera de suas atribuições;
8. Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições, quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito;
9. Deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas no Estatuto dos Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que não haja tipificação como crime ou contravenção penal, cuja violação afete os preceitos da hierarquia e disciplina, a ética militar, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
10. Deixar de instruir, na esfera de suas atribuições, processo que lhe for encaminhado, ressalvado o caso em que não for possível obter elementos para tal;
11. Deixar de encaminhar à autoridade competente, na linha de subordinação e no mais curto prazo, recurso ou documento que receber elaborado de acordo com os preceitos regulamentares, se não for da sua alçada a solução;
12. Desrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou ações de ordem judicial,

administrativa ou policial, ou para isso concorrer;

13. Apresentar parte ou recurso suprimindo instância administrativa, dirigindo para autoridade incompetente, repetindo requerimento já rejeitado pela mesma autoridade ou empregando termos desrespeitosos;

14. Dificultar ao subordinado a apresentação de recurso;

15. Deixar de comunicar, tão logo possível, ao superior a execução de ordem recebida;

16. Aconselhar ou concorrer para que não seja cumprida qualquer ordem de autoridade competente, ou para retardar a sua execução;

17. Deixar de cumprir ou alterar, sem justo motivo, as determinações constantes da missão recebida, ou qualquer outra determinação escrita ou verbal;

18. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de qualquer dever militar;

19. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução;

20. Causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes no serviço ou na instrução, por imperícia, imprudência ou negligência;

21. Disparar arma por imprudência ou negligência;

22. Não zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligência ou desobediência das regras e normas de serviço, material ou animal da União ou documentos oficiais, que estejam ou não sob sua responsabilidade direta, ou concorrer para tal;

23. Não ter pelo preparo próprio, ou pelo de seus comandados, instruendos ou educandos, a dedicação imposta pelo sentimento do dever;

24. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência, medidas contra qualquer irregularidade de que venha a tomar conhecimento;

25. Deixar de participar em tempo, à autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer à OM ou a qualquer ato de serviço para o qual tenha sido escalado ou a que deva assistir;

26. Faltar ou chegar atrasado, sem justo motivo, a qualquer ato, serviço ou instrução de que deva participar ou a que deva assistir;

27. Permutar serviço sem permissão de autoridade competente ou com o objetivo de obtenção de vantagem pecuniária;

28. Ausentar-se, sem a devida autorização, da sede da organização militar onde serve, do local do serviço ou de outro qualquer em que deva encontrar-se por força de disposição legal ou ordem;

29. Deixar de apresentar-se, nos prazos regulamentares, à OM para a qual tenha sido transferido ou classificado e às autoridades competentes, nos casos de comissão ou serviço extraordinário para os quais tenha sido designado;

30. Não se apresentar ao fim de qualquer afastamento do serviço ou, ainda, logo que souber da interrupção;

31. Representar a organização militar ou a corporação, em qualquer ato, sem estar devidamente autorizado;

32. Assumir compromissos, prestar declarações ou divulgar informações, em nome da corporação ou da unidade que comanda ou em que serve, sem autorização;

33. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades, que afete o bom nome da Instituição;
34. Esquivar-se de satisfazer compromissos de ordem moral ou pecuniária que houver assumido, afetando o bom nome da Instituição;
35. Não atender, sem justo motivo, à observação de autoridade superior no sentido de satisfazer débito já reclamado;
36. Não atender à obrigação de dar assistência à sua família ou dependente legalmente constituídos, de que trata o Estatuto dos Militares;
37. Fazer diretamente, ou por intermédio de outrem, transações pecuniárias envolvendo assunto de serviço, bens da União ou material cuja comercialização seja proibida;
38. Realizar ou propor empréstimo de dinheiro a outro militar visando auferir lucro;
39. Ter pouco cuidado com a apresentação pessoal ou com o asseio próprio ou coletivo;
40. Portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura;
41. Deixar de tomar providências cabíveis, com relação ao procedimento de seus dependentes, estabelecidos no Estatuto dos Militares, junto à sociedade, após devidamente admoestado por seu Comandante;
42. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe;
43. Portar a praça armamento militar sem estar de serviço ou sem autorização;
44. Executar toques de clarim ou corneta, realizar tiros de salva, fazer sinais regulamentares, içar ou arriar a Bandeira Nacional ou insígnias, sem ordem para tal;
45. Conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios quando em serviço ou em local sob administração militar;
46. Disseminar boatos no interior de OM ou concorrer para tal;
47. Provocar ou fazer-se causa, voluntariamente, de alarme injustificável;
48. Usar de força desnecessária no ato de efetuar prisão disciplinar ou de conduzir transgressor;
49. Deixar alguém conversar ou entender-se com preso disciplinar, sem autorização de autoridade competente;
50. Conversar com sentinela, vigia, plantão ou preso disciplinar, sem para isso estar autorizado por sua função ou por autoridade competente;
51. Consentir que preso disciplinar conserve em seu poder instrumentos ou objetos não permitidos;
52. Conversar, distrair-se, sentar-se ou fumar, quando exercendo função de sentinela, vigia ou plantão da hora;
53. Consentir, quando de sentinela, vigia ou plantão da hora, a formação de grupo ou a permanência de pessoa junto a seu posto;
54. Fumar em lugar ou ocasião onde seja vedado;
55. Tomar parte em jogos proibidos ou em jogos a dinheiro, em área militar ou sob jurisdição

militar;

56. Tomar parte, em área militar ou sob jurisdição militar, em discussão a respeito de assuntos de natureza político-partidária ou religiosa;

57. Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária;

58. Tomar parte, fardado, em manifestações de natureza político-partidária;

59. Discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado;

60. Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço;

61. Dar conhecimento de atos, documentos, dados ou assuntos militares a quem deles não deva ter ciência ou não tenha atribuições para neles intervir;

62. Publicar ou contribuir para que sejam publicados documentos, fatos ou assuntos militares que possam concorrer para o desprestígio das Forças Armadas ou que firam a disciplina ou a segurança destas;

63. Comparecer o militar da ativa, a qualquer atividade, em traje ou uniforme diferente do determinado;

64. Deixar o superior de determinar a saída imediata de solenidade militar ou civil, de subordinado que a ela compareça em traje ou uniforme diferente do determinado;

65. Apresentar-se, em qualquer situação, sem uniforme, mal uniformizado, com o uniforme alterado ou em trajes em desacordo com as disposições em vigor;

66. Sobrepor ao uniforme insígnia ou medalha não regulamentar, bem como, indevidamente, distintivo ou condecoração;

67. Recusar ou devolver insígnia, medalha ou condecoração que lhe tenha sido outorgada;

68. Usar o militar da ativa, em via pública, uniforme inadequado, contrariando o Regulamento de Uniformes do Exército ou normas a respeito;

69. Transitar o soldado, o cabo ou o taifeiro, pelas ruas ou logradouros públicos, durante o expediente, sem permissão da autoridade competente;

70. Entrar ou sair da OM, ou ainda permanecer no seu interior o cabo ou soldado usando traje civil, sem a devida permissão da autoridade competente;

71. Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o militar, por lugar que não seja para isso designado;

72. Entrar em qualquer OM, ou dela sair, o taifeiro, o cabo ou o soldado, com objeto ou embrulho, sem autorização do comandante da guarda ou de autoridade equivalente;

73. Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, ao entrar em OM onde não sirva, de dar ciência da sua presença ao oficial-de-dia e, em seguida, de procurar o comandante ou o oficial de maior precedência hierárquica, para cumprimentá-lo;

74. Deixar o subtenente, sargento, taifeiro, cabo ou soldado, ao entrar em organização militar onde não sirva, de apresentar-se ao oficial-de-dia ou a seu substituto legal;

75. Deixar o comandante da guarda ou responsável pela segurança correspondente, de cumprir as prescrições regulamentares com respeito à entrada ou permanência na OM de civis ou militares

a ela estranhos;

76. Adentrar o militar, sem permissão ou ordem, em aposentos destinados a superior ou onde este se ache, bem como em qualquer lugar onde a entrada lhe seja vedada;

77. Adentrar ou tentar entrar em alojamento de outra subunidade, depois da revista do recolher, salvo os oficiais ou sargentos que, por suas funções, sejam a isso obrigados;

78. Entrar ou permanecer em dependência da OM onde sua presença não seja permitida;

79. Entrar ou sair de OM com tropa, sem prévio conhecimento, autorização ou ordem da autoridade competente;

80. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdição militar, material, viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem do responsável ou proprietário;

81. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência de organização militar, fora das horas de expediente, desde que não seja o respectivo chefe ou sem a devida ordem e a expressa declaração de motivo, salvo em situações de emergência;

82. Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa;

83. Deixar de portar a identidade militar, estando ou não fardado;

84. Deixar de se identificar quando solicitado por militar das Forças Armadas em serviço ou em cumprimento de missão;

85. Desrespeitar, em público, as convenções sociais;

86. Desconsiderar ou desrespeitar autoridade constituída;

87. Desrespeitar corporação judiciária militar ou qualquer de seus membros;

88. Faltar, por ação ou omissão, com o respeito devido aos símbolos nacionais, estaduais, municipais e militares;

89. Apresentar-se a superior hierárquico ou retirar-se de sua presença, sem obediência às normas regulamentares;

90. Deixar, quando estiver sentado, de demonstrar respeito, consideração e cordialidade ao superior hierárquico, deixando de oferecer-lhe seu lugar, ressalvadas as situações em que houver lugar marcado ou em que as convenções sociais assim não o indiquem;

91. Sentar-se, sem a devida autorização, à mesa em que estiver superior hierárquico;

92. Deixar, deliberadamente, de corresponder a cumprimento de subordinado;

93. Deixar, deliberadamente, de cumprimentar superior hierárquico, uniformizado ou não, neste último caso desde que o conheça, ou de saudá-lo de acordo com as normas regulamentares;

94. Deixar o oficial ou aspirante-a-oficial, diariamente, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao comandante ou ao substituto legal imediato da OM onde serve, para cumprimentá-lo, salvo ordem ou outras normas em contrário;

95. Deixar o subtenente ou sargento, diariamente, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu comandante de subunidade ou chefe imediato, salvo ordem ou outras normas em contrário;

96. Recusar-se a receber vencimento, alimentação, fardamento, equipamento ou material que lhe seja destinado ou deva ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade;

97. Recusar-se a receber equipamento, material ou documento que tenha solicitado oficialmente, para atender a interesse próprio;

98. Desacreditar, dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior hierárquico;

99. Censurar ato de superior hierárquico ou procurar desconsiderá-lo seja entre militares, seja entre civis;

100. Ofender, provocar, desafiar, desconsiderar ou procurar desacreditar outro militar, por atos, gestos ou palavras, mesmo entre civis;

101. Ofender a moral, os costumes ou as instituições nacionais ou do país estrangeiro em que se encontrar, por atos, gestos ou palavras;

102. Promover ou envolver-se em rixa, inclusive luta corporal, com outro militar;

103. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicatório ou político, seja de crítica ou de apoio a ato de superior hierárquico, com exceção das demonstrações íntimas de boa e sã camaradagem e com consentimento do homenageado;

104. Aceitar qualquer manifestação coletiva de seus subordinados, com exceção das demonstrações íntimas de boa e sã camaradagem e com consentimento do homenageado;

105. Autorizar, promover, assinar representações, documentos coletivos ou publicações de qualquer tipo, com finalidade política, de reivindicação coletiva ou de crítica a autoridades constituídas ou às suas atividades;

106. Autorizar, promover ou assinar petição ou memorial, de qualquer natureza, dirigido a autoridade civil, sobre assunto da alçada da administração do Exército;

107. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em área militar ou sob a jurisdição militar, publicações, estampas, filmes ou meios eletrônicos que atentem contra a disciplina ou a moral;

108. Ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou sob a jurisdição militar, armas, explosivos, material inflamável, substâncias ou instrumentos proibidos, sem conhecimento ou permissão da autoridade competente;

109. Fazer uso, ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou sob jurisdição militar, bebida alcoólica ou com efeitos entorpecentes, salvo quando devidamente autorizado;

110. Comparecer a qualquer ato de serviço em estado visível de embriaguez ou nele se embriagar;

111. Falar, habitualmente, língua estrangeira em OM ou em área de estacionamento de tropa, exceto quando o cargo ocupado o exigir;

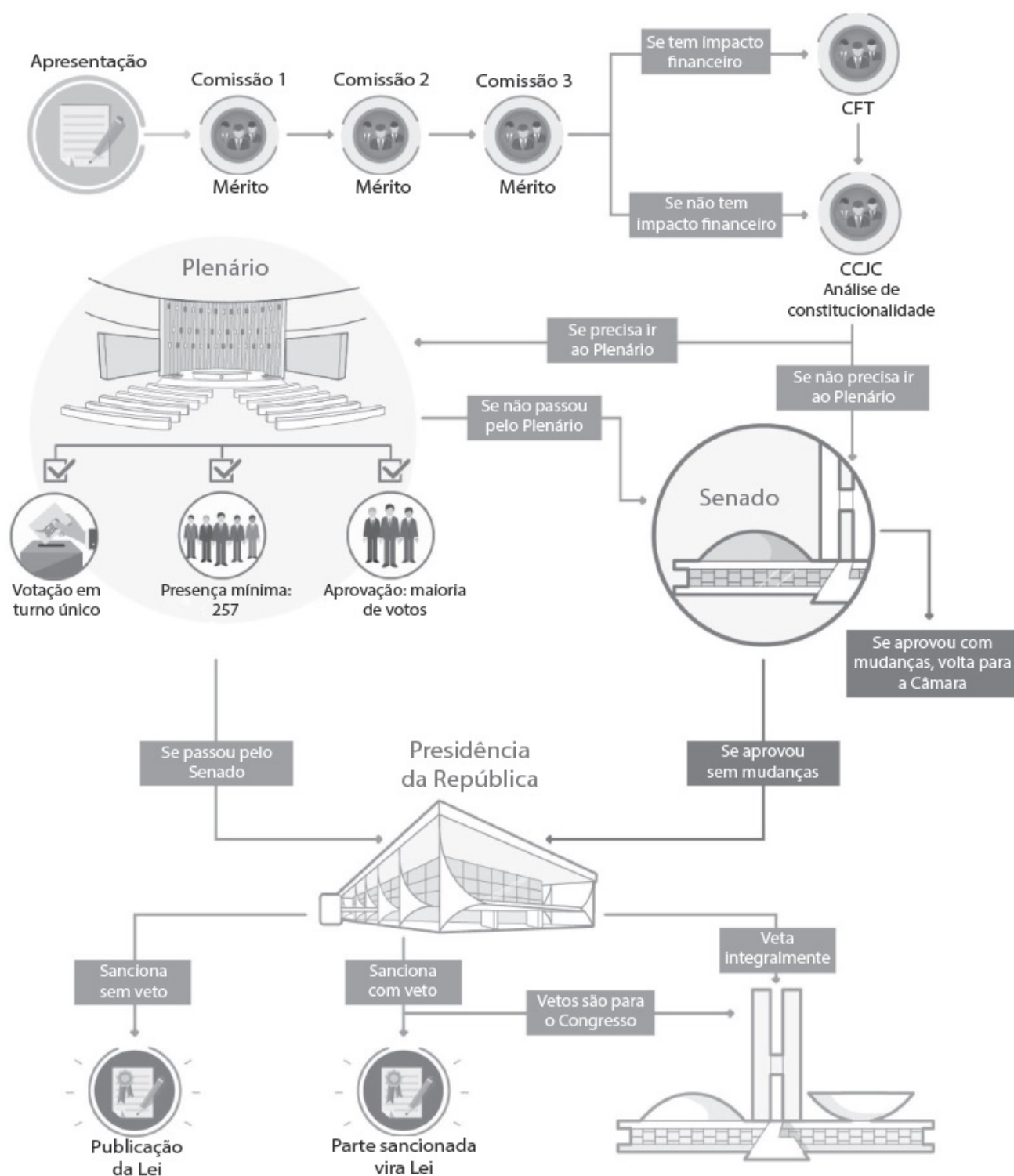
112. Exercer a praça, quando na ativa, qualquer atividade comercial ou industrial, ressalvadas as permitidas pelo Estatuto dos Militares;

113. Induzir ou concorrer intencionalmente para que outrem incida em transgressão disciplinar.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

ANEXO VI – REPRESENTAÇÃO VISUAL DO CAMINHO DA LEI

ANEXO VI – REPRESENTAÇÃO VISUAL DO CAMINHO DA LEI



Fonte: [www.camara.leg.br/entenda-o-processo-legislativo/].

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Ed. 2020

Referências Bibliográficas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, J. Canuto Mendes de. *Princípios Fundamentais do Processo Penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973.

ALMEIDA, J. Canuto Mendes de. *Processo Penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975.

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. *Legislação Penal Especial*. 4. ed. Editora Saraiva, 2008.

ANISTIA INTERNACIONAL. *Tortura e Maus-Tratos no Brasil*. Editora Nova Prova, 2001.

FERNANDES, Antonio Scarance. *Processo Penal Constitucional*. 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

BADARÓ, Gustavo Henrique. *Processo Penal*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

BARROS, Marco Antonio de. *A Busca da Verdade no Processo Penal*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

BITENCOURT, Cezar Roberto. *Direito Penal das Licitações*. Editora Saraiva, 2012.

CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. *Fundamentação Constitucional do Direito Penal*. Sérgio Antonio Fabris Editor, 1992.

CUNHA, Rogério Sanches. *Manual de Direito Penal (Parte Especial)*. 10. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.

DA ROSA, Alexandre Moraes. *A Teoria dos Jogos Aplicada ao Processo Penal*. 1. ed. 2014.

DE BRITO, Alexis Augusto Couto; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. *Processo Penal Brasileiro*. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

DEZEM, Guilherme Madeira. *Curso de Processo Penal*. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

DOTTI, René Ariel. *Curso de Direito Penal – Parte geral*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

FABRETTI, Humberto Barrionuevo. *Segurança Pública*. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

GRECO, Rogério. *Direito Penal do Equilíbrio*. Impetus, 2005.

HABIB, Gabriel. *Leis Penais Especiais – Tomo I*. 7. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015.

JUNQUEIRA, Michelle Asato; PINTO, Felipe Chiarello de Souza. *Teoria da Constituição*. 1. ed. Editora Mackenzie, 2018.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra; PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio; PELÁ, Carlos. *A validade e a eficácia das normas jurídicas*. Manole, 2005.

- MARCÃO, Renato. *Curso de Processo Penal*. 2. ed. Editora Saraiva, 2016.
- MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. *Justa Causa Para a Ação Penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- NUCCI, Guilherme de Souza. *Curso de Direito Penal*. vol. 2. Editora Forense, 2017.
- NUCCI, Guilherme de Souza. *Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
- PELUSO, Vinicius de Toledo Piza. *Introdução às Ciências Criminais*. Salvador: Editora JusPodivm, 2015.
- PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 5. ed. Max Limonad, 2002.
- PONTES DE MIRANDA. *Democracia, Liberdade, Igualdade (Os Três Caminhos)*. 2. ed. Saraiva, 1979.
- PRADO, Luiz Regis. *Bem Jurídico-Penal e Constituição*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
- QUEIROZ, Paulo de Souza. *Do Caráter Subsidiária do Direito Penal*. 2. ed. 2002.
- RANGEL, Paulo. *Direito Processual Penal*. 25. ed. Atlas, 2017.
- RIPOLLÉS, José Luis Díez. *A Racionalidade das Leis Penais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
- RODRIGUES, Cristiano. *Manual de Direito Penal*. Editora Foco, 2019.
- TEBET, Diogo. *Súmula Vinculante em Matéria Criminal*, Ibccrim, 1. ed. 2010.
- TORON, Alberto Zacharias. *Habeas Corpus*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
- TUCCI, Rogério Lauria. *Delitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.